

INFORMATIVOS STF
2014-2018
TESES E FUNDAMENTOS

Organizado por matérias

DIREITO
ADMINISTRATIVO

VOLUME 1

INFORMATIVOS STF
2014-2018
TESES E FUNDAMENTOS

Organizado por matérias

Direito
Administrativo

volume 1

Brasília, 2019



Secretaria-Geral da Presidência

Daiane Nogueira de Lira

Secretaria de Documentação

Naiara Cabeleira de Araújo Pichler

Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência

Andreia Fernandes de Siqueira

Equipe Técnica: Diego Oliveira de Andrade Soares, Fernando Carneiro Rosa Fortes, João de Souza Nascimento Neto, Ricardo Henriques Pontes e Tiago Batista Cardoso

Revisão: Amélia Lopes Dias de Araújo, Camila Lima Canabarro, Juliana Silva Pereira de Souza, Letycia Luiza de Souza, Lilian de Lima Falcão Braga, Márcia Gutierrez Aben-Athar Bemerguy, Rochelle Quito e Rosa Cecília Freire da Rocha

Capa: Patrícia Amador Medeiros

Projeto gráfico: Eduardo Franco Dias

Diagramação: Camila Penha Soares, Eduardo Franco Dias e Neir dos Reis Lima e Silva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Supremo Tribunal Federal – Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal

Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF).

Informativos STF 2014-2018 [recurso eletrônico] : teses e fundamentos : direito administrativo / Supremo Tribunal Federal. -- Brasília : STF, Secretaria de Documentação, 2019.

Organizado por matérias.

Modo de acesso: < <http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF> >.

ISBN: 978-85-54223-18-2

1. Tribunal Supremo, jurisprudência, Brasil. 2. Direito administrativo, jurisprudência. I Título.

CDDir-341.4191

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ministro José Antonio **Dias Toffoli** (23-10-2009), Presidente

Ministro **Luiz Fux** (3-3-2011), Vice-Presidente

Ministro José **Celso de Mello** Filho (17-8-1989), Decano

Ministro **Marco Aurélio** Mendes de Farias Mello (13-6-1990)

Ministro **Gilmar** Ferreira **Mendes** (20-6-2002)

Ministro Enrique **Ricardo Lewandowski** (16-3-2006)

Ministra **Cármén Lúcia** Antunes Rocha (21-6-2006)

Ministra **Rosa** Maria Pires **Weber** (19-12-2011)

Ministro Luís **Roberto Barroso** (26-6-2013)

Ministro Luiz **Edson Fachin** (16-6-2015)

Ministro **Alexandre de Moraes** (22-3-2017)

APRESENTAÇÃO

Tanto nas faculdades de Direito como nos manuais das disciplinas desse ramo do conhecimento, é notável o destaque que vem sendo dado aos posicionamentos judiciais. Na mesma esteira, a atuação dos profissionais do Direito é cada vez mais lastreada em precedentes dos tribunais superiores e, notadamente, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesse contexto, é possível inferir que há crescente interesse por obras que franqueiem, de forma organizada e de fácil consulta, o acesso à jurisprudência emanada pelo STF.

Com o intuito de atender tal demanda, o Tribunal vem publicando, desde 1995, o *Informativo STF*, espécie de “jornal jurídico” que veicula resumos, originalmente semanais, das circunstâncias fáticas e processuais e dos fundamentos proferidos oralmente nas sessões de julgamento.

Conforme consta do cabeçalho de todas as edições do periódico, os boletins são elaborados “a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Turmas e do Plenário”, de modo que contêm “resumos não oficiais de decisões proferidas pelo Tribunal”. Faz-se tal observação para esclarecer ao leitor que, embora o conteúdo não possa ser considerado oficial, baseia-se estritamente em informações públicas.

A obra que ora se apresenta é uma edição especial, que abarca um período de cinco anos – 2014 a 2018. Cada volume contém um ramo do Direito e tem por referência casos que foram noticiados no *Informativo STF*. O acesso aos argumentos de Suas Excelências, na exatidão precisa do vernáculo escrito, permite explorar a riqueza técnica neles contida e estudar com mais rigor a fundamentação das decisões do Tribunal.

É bom ressaltar que o leitor pode acompanhar mensalmente este trabalho ao acessar o *Boletim de Acórdãos Publicados* disponível no *site* do Tribunal (Portal do STF/Jurisprudência/Boletim de Acórdãos Publicados).

Um novo ponto de vista sobre a jurisprudência

É da essência do *Informativo STF* produzir uma síntese de decisões proferidas pela Corte durante as sessões de julgamento, sem avançar em análise abstrata da juris-

prudência do Tribunal. Já o livro *Teses e fundamentos* percorre caminho diverso e se aprofunda nos julgados do STF para oferecer um produto mais complexo.

Desse modo, o livro tem por objetivos:

I – Elaborar teses, redigidas com base no **dispositivo**¹ dos acórdãos e abstraídas das notícias de julgamento; e

II – Analisar a fundamentação adotada pelo Tribunal e, na sequência, esboçar um panorama do entendimento da Corte sobre os ramos do Direito.

A proposta é que as teses apontem como caminho a jurisprudência da Suprema Corte brasileira ao longo dos anos e, ainda, permitam vislumbrar futuros posicionamentos do Tribunal, tendo por referência os processos já julgados. Cumpre destacar que essas teses – com os respectivos fundamentos – não traduzem necessariamente a pacificação da jurisprudência num ou noutro sentido. Elas se prestam simplesmente a fornecer mais um instrumento de estudo da jurisprudência e a complementar a função desempenhada pelo *Informativo STF*.

Tendo isso em vista, os textos que compõem o livro estruturam-se em: **tese jurídica extraída do julgado**² e **resumo da fundamentação**². Pretende-se, com esse padrão, que o destaque dado aos dispositivos dos acórdãos seja complementado por seus respectivos fundamentos.

Os **dados do processo em análise**² são apresentados no cabeçalho de cada resumo e, com o objetivo de garantir acesso rápido ao conteúdo de teses fixadas, no fim da obra foi incluída uma lista de todas as teses contidas no livro.

As decisões acerca da redação e da estrutura do livro foram guiadas também pela busca da otimização do tempo de seu público-alvo. Afinal, a leitura de acórdãos, de votos ou mesmo de ementas demandaria esforço interpretativo e tempo dos quais o estudante ou o operador do Direito muitas vezes não dispõe. Assim, deu-se preferência a formato de redação que destacasse o dispositivo do acórdão e seus fundamentos, ao mesmo tempo que traduzisse de forma sintética o entendimento do STF.

Em busca de mais fluidez e concisão, decidiu-se retirar do texto principal as referências que não fossem essenciais à sua redação. Assim, foram transpostos para **notas de fim**², entre outras informações pertinentes: relatórios de situações fáticas e observações processuais, quando necessários à compreensão do caso; precedentes jurisprudenciais; e transcrições de normativos ou de **doutrina**³.

A mesma objetividade que orientou a estrutura redacional dos resumos norteou a organização dos julgados em disciplinas do Direito e em temas. Estes, por sua vez, foram subdivididos em **assuntos**² específicos. Tal sistematização do conteúdo visa,

mais uma vez, facilitar o trabalho dos estudantes e dos operadores do Direito, que compõem o público-alvo desta obra.

A esse respeito, sob o ângulo dos ramos do Direito, optou-se pela análise vertical dos julgados em cada ano, o que propicia rápida visualização e comparação de matérias semelhantes decididas pelos órgãos do STF. A obra permite, assim, que o leitor verifique, de forma fácil e segura, a evolução jurisprudencial de um dado tema ao longo do tempo.

A ideia foi, em resumo, aliar a objetividade característica do *Informativo STF* com a profundidade e a riqueza técnico-jurídica contida nos acórdãos e nos votos dos ministros. Para cumprir tal finalidade, foi necessário interpretar os acórdãos dos julgamentos.

Todavia, se por um lado é certo que a redação de resumos demanda algum grau de liberdade interpretativa dos documentos originais, por outro a hermenêutica reconhece ser inerente à interpretação jurídica certa dose de subjetividade.

Nessa perspectiva, embora os analistas responsáveis pelo trabalho tenham se esforçado para – acima de tudo – manter fidelidade aos entendimentos do STF, ao mesmo tempo que conciliavam concisão e acuidade na remissão aos fundamentos das decisões, não se deverá perder de vista que os resultados do exame da jurisprudência aqui expostos são fruto de interpretação desses servidores.

Espaço para participação do leitor

Os enunciados aqui publicados tanto podem conter trechos do julgado original – na hipótese de estes sintetizarem a ideia principal – quanto podem ser resultado exclusivo da interpretação dos acórdãos pelos analistas responsáveis pela compilação. Na obra, estão disponíveis os *links* de acesso à íntegra dos acórdãos, o que facilita a conferência da acuidade dessa interpretação. O leitor poderá encaminhar dúvidas, críticas e sugestões para o e-mail: cdju@stf.jus.br.

Ademais, entre as razões que motivaram a edição deste trabalho está justamente o propósito de fomentar a discussão e de contribuir para a difusão do “pensamento” do Tribunal e para a construção do conhecimento jurídico. Com isso, promove-se maior abertura à participação da sociedade no exercício da atividade constitucionalmente atribuída ao STF.

1 Deve-se ter em mente que muitas vezes os dispositivos dos acórdãos se limitam a “dar (ou negar) provimento ao recurso” ou, ainda, “conceder (ou não) a ordem”. Embora esses comandos jurisdicionais efetivamente componham o dispositivo da sentença, do ponto de vista da análise das decisões judiciais – e da jurisprudência – eles significam muito pouco. Por evidente, o objeto deste trabalho é o tema decidido pela Corte, seja ele de direito material, seja de direito processual, e não o mero resultado processual de uma demanda específica. Nesse sentido, talvez seja possível discernir entre o conteúdo formal da decisão, que seria, exemplificativamente, o resultado do recurso (conhecido/não conhecido, provido/não provido) ou da ação (procedência/improcedência), e o conteúdo material da decisão, que efetivamente analisa a questão de direito (material ou processual) debatida e possui relevância para a análise da jurisprudência. Em outras palavras, o conteúdo material da decisão corresponderia aos fragmentos do provimento jurisdicional que têm aptidão para transcender ao processo em análise e constituir o repertório de entendimentos do Tribunal sobre o ordenamento jurídico brasileiro.

2 Ver Infográfico, página 8.

3 Informações entre colchetes não constam do texto original.

Direito Administrativo

• Organização da Administração Pública

• Administração Indireta

• Autarquias – Repercussão Geral

RE 938.837

RG – Tema 877

red. p/ o ac. min. Marco Aurélio

Plenário

DJE de 25-9-2017

Informativo STF 861

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatórios.

O art. 100 da Constituição Federal (CF), que cuida do sistema de precatórios, diz respeito a pagamentos a serem feitos não pelos conselhos, mas pelas Fazendas Públicas.

Os conselhos de fiscalização profissionais são autarquias especiais, possuem personalidade jurídica de direito público e estão submetidos às regras constitucionais, tais como a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e a submissão ao sistema de concurso público para arrematação de pessoal.

Entretanto, esses conselhos não estão submetidos ao Capítulo II do Título VI da CF – que versa sobre finanças públicas (arts. 163 a 169) –, não são órgãos dotados de orçamento e tampouco recebem aportes do Poder Central, que é a União.

Nesse sentido, se não é possível incluir os conselhos no grande todo representado pela Fazenda Pública, não é possível aplicar a eles o art. 100 da CF. Por conseguinte, o débito de conselho fiscalizador profissional não é executável como débito da Fazenda.

[1] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”

INFOGRÁFICO

Direito Administrativo

- » Organização da Administração Pública
 - » Administração Indireta
 - » Autarquias – Repercussão Geral

Assunto

RE 938.837

RG – Tema 877

red. p/ o ac. min. Marco Aurélio

Plenário

DJE de 25-9-2017

Informativo STF 861

Dados do processo em análise

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatórios.

Tese jurídica extraída do julgado

O art. 100 da Constituição Federal (CF)¹, que cuida do sistema de precatórios, diz respeito a pagamentos a serem feitos não pelos conselhos, mas pelas Fazendas Públicas.

Os conselhos de fiscalização profissionais são autarquias especiais, possuem personalidade jurídica de direito público e estão submetidos às regras constitucionais, tais como a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e a submissão ao sistema de concurso público para arrematação de pessoal.

Resumo da fundamentação

- 1 “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”

Nota de fim

SUMÁRIO

Siglas e abreviaturas	10
Siglas de classes e incidentes processuais	11
Agentes públicos	13
Bens públicos	182
Contratos administrativos	184
Controle da Administração Pública	188
Intervenção do Estado na propriedade	191
Organização da Administração Pública	196
Poderes administrativos	207
Princípios da Administração Pública	209
Processo administrativo	214
Serviços públicos.....	223
Responsabilidade civil do Estado.....	228
Ressarcimento ao erário	240
Índice de teses	244

SIGLAS E ABREVIATURAS

ac.	acórdão
1ª T	Primeira Turma
2ª T	Segunda Turma
DJ	Diário da Justiça
DJE	Diário da Justiça Eletrônico
j.	julgamento em
P	Plenário
red. p/ o ac.	redator para o acórdão
rel. min.	relator o ministro
RG	Repercussão Geral
T	Turma

SIGLAS DE CLASSES E INCIDENTES PROCESSUAIS

AC	Ação Cautelar
ACO	Ação Cível Originária
ADC	Ação Declaratória de Constitucionalidade
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADO	Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AgR	Agravo Regimental
AI	Agravo de Instrumento
AO	Ação Originária
AP	Ação Penal
AR	Ação Rescisória
ARE	Recurso Extraordinário com Agravo
CC	Conflito de Competência
ED	Embargos de Declaração
EDv	Embargos de Divergência
EI	Embargos infringentes
EP	Execução Penal
Ext	Extradição
HC	Habeas Corpus
IndCom	Indulto ou Comutação
Inq	Inquérito
MC	Medida Cautelar
MI	Mandado de Injunção
MS	Mandado de Segurança
Pet	Petição
ProgReg	Progressão de Regime
QO	Questão de Ordem
Rcl	Reclamação
RE	Recurso Extraordinário
REF	Referendo
RG	Repercussão Geral
RHC	Recurso em Habeas Corpus
RMS	Recurso em Mandado de Segurança
Rp	Representação
SE	Sentença Estrangeira

DIRITTO AMMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

O reingresso, em casos de anistia¹, aos quadros do Poder Executivo deve observar a situação jurídica originária e não implica necessária submissão ao estatuto dos servidores públicos federais.

A possibilidade de transformação de empregos em cargos públicos², prevista no art. 2º da Lei 8.878/1994³, somente cria o direito subjetivo ao aproveitamento se comprovada a passagem da atividade para o regime estatutário.⁴

Diante disso, o retorno do servidor à prestação de serviços pela Administração Pública faz-se observada a situação jurídica originária, descabendo transmutar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

1 Lei 8.878/1994: “Art. 1º É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido: I – exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal; II – despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa; III – exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.”

2 AI 596.430 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T.

3 Lei 8.878/1994: “Art. 2º O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5º, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos exonerados, demitidos, dispensados ou despedidos dos órgãos ou entidades que tenham sido extintos liquidados ou privatizados, salvo quando as respectivas atividades: a) tenham sido transferidas, absorvidas ou executadas por outro órgão ou entidade da administração pública federal; b) estejam em curso de transferência ou de absorção por outro órgão ou entidade da administração pública federal, hipótese em que o retorno dar-se-á após a efetiva implementação da transferência.”

4 RMS 22.822, rel. min. Marco Aurélio, 2ª T.

- » Agentes públicos
 - » Cargos públicos
 - » Cargo em comissão – Repercussão Geral

Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal (CF)¹, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão.

O referido dispositivo apresenta um nítido recorte: o regramento previdenciário nele previsto aplica-se, via de regra, aos servidores efetivos², os quais, embora tão servidores públicos quanto os comissionados³, com eles não se confundem. Tivesse o dispositivo em questão o intuito de referir-se aos servidores genericamente considerados, não traria na letra da norma delimitação expressa.

A lógica que rege as nomeações para cargos comissionados é distinta daquela que rege as nomeações para os efetivos. Os últimos ingressam no serviço público mediante concurso. Há, ademais, o adicional de possuírem estabilidade e tenderem a manter com o Estado um longo e sólido vínculo, o que torna admissível a expulsória como forma de oxigenação e renovação. Os primeiros, por sua vez, adentram a estrutura estatal para o desempenho de cargos de chefia, direção ou assessoramento, pressupondo-se, como substrato de sua designação, a existência de uma relação de confiança pessoal e de especialidade incomum. O comissionado adentra o serviço público, entre outros motivos, para agregar a esse último uma habilidade não facilmente encontrada, uma formação técnica especializada. Exerce, ao menos na teoria, atribuições diferenciadas, tanto do ponto de vista da rotina e das responsabilidades no local de trabalho como da própria atividade intelectual. Sendo esse o fundamento da nomeação, não há razão para submeter o indivíduo à compulsória quando, além de persistirem a relação de confiança e a especialização técnica e intelectual, o servidor é exonerável a qualquer momento, independentemente, inclusive, de motivação.

Por sua vez, o art. 40, § 13, da CF⁴, ao determinar a aplicação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), evidencia o tratamento dissonante a ser conferido aos

ocupantes de cargo em comissão. Dessa previsão constitucional decorre que a passagem para a inatividade observará o art. 201 da CF⁵ e a Lei 8.213/1990, que arrolam as seguintes espécies de aposentadoria: por invalidez, por idade, por tempo de serviço e especial. Portanto, inexistente, para os indivíduos vinculados ao RGPS, qualquer previsão de compulsoriedade de aposentação, a qual será sempre facultativa.

Além disso, cabe destacar que, se não há idade limite para a inativação e se a legislação de regência não cuidou do tema, também não há idade limite para o ingresso em cargo comissionado. Os motivos que justificam a não incidência da norma do art. 40, § 1º, II, da CF amparam também a impossibilidade de se proibir que o maior de 75 anos seja nomeado para o exercício de cargo de confiança na Administração Pública. Enquanto não houver alteração constitucional ou edição de lei estabelecendo idade máxima – justificada sempre pela natureza das atribuições do cargo –, não há que se falar em observância do marco de 75 anos de idade ou de qualquer outro para fins de escolha e designação para a espécie de função em comento.

Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexistente óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração.

Nessas situações, verifica-se a coexistência de vínculo funcional efetivo e de cargo em comissão sem vínculo efetivo, para o que não se vislumbra vedação, inclusive sob o ponto de vista previdenciário.

O servidor efetivo aposentado compulsoriamente, embora mantenha esse vínculo com a Administração mesmo após sua passagem para a inatividade, ao tomar posse em função de provimento em comissão, inaugura, com essa última, uma segunda e nova relação, agora relativa ao cargo comissionado. Não se trata de forma irregular de continuidade do vínculo efetivo, uma vez que comissionados e efetivos são espécies díspares do gênero servidor público.

¹ CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atua-

rial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (...) II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;”

- 2 Os cargos de provimento efetivo são aqueles “destinados ao provimento em caráter definitivo. A permanência é que identifica a forma de ocupação. ‘É o cargo ocupado por alguém sem transitoriedade ou adequado a uma ocupação permanente’, no preciso dizer de Diógenes Gasparini. Eles devem ser exercidos, obrigatoriamente, por funcionários concursados e de forma permanente, ressalvada a titularidade provisória do funcionário ainda em período probatório”. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Servidores públicos*. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 48.)
- 3 Os cargos de provimento em comissão, por sua vez, consubstanciam aqueles “destinados a livre provimento e exoneração. O sentido literal de ‘comissão’ pode ser expresso como um encargo ou incumbência temporária oferecida pelo comitente. Nesse mesmo sentido, o cargo em comissão pode ser cargo isolado ou permanente, criado por lei, de ocupação transitória e livremente preenchido pelo chefe do Executivo, segundo seu exclusivo critério de confiança. Transitória, portanto, é a permanência do servidor escolhido, não o cargo, que é criado por lei”. (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. *Servidores públicos*. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 38.)
- 4 CF/1988: “Art. 40. (...) § 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”
- 5 CF/1988: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.”

- » Agentes públicos
- » Cargos públicos
- » Cargo em comissão

O cargo em comissão de diretor do Departamento de Gestão da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não privativo de bacharel em Direito, pode ser ocupado por pessoa estranha a esse órgão.

Essa permissão se justifica na medida em que o cargo em questão é de livre nomeação e exoneração [Constituição Federal (CF), art. 37, II¹]. Além disso, a nomeação de auditor fiscal para o cargo encontra respaldo na Lei 11.890/2008, que permite aos integrantes da Auditoria da Receita Federal, servidores de outra carreira, ter exercício na PGFN.

¹ CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

A incompatibilidade da prática referida no Enunciado 13 da Súmula Vinculante¹ não decorre exclusivamente da existência de relação de parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público. Deriva da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa cuja relação de parentesco possa interferir no processo de seleção.

Deve-se perquirir a relação de parentesco com o servidor público que tenha competência para a nomeação a cargo de chefia, direção ou assessoramento pleiteado ou que exerça ascendência hierárquica sobre o nomeante.

Vedar o acesso de qualquer cidadão a cargo público somente em razão da existência de relação de parentesco com servidor público é negar um dos princípios constitucionais a que se pretendeu conferir efetividade com a edição do Enunciado 13 da Súmula Vinculante: o princípio da impessoalidade.

Tal verbete, embora não tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de nepotismo na Administração Pública, instituiu critérios objetivos para a sua conformação, a saber:

- a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada;
- b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante;
- c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e
- d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante.

Em sede reclamatória, com fundamento no Enunciado 13 da Súmula Vinculante, é obrigatória a presença dos elementos de prova ou de direito suficientes à comprovação de favorecimento indevido no ato de nomeação para fins de configuração objetiva de nepotismo na contratação de pessoa com relação de parentesco com ocupante de

cargo de direção, chefia ou assessoramento no mesmo órgão, salvo ajuste mediante designações recíprocas.

- 1 Enunciado 13 da Súmula Vinculante: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

- » Agentes públicos
 - » Cargos públicos
 - » Nepotismo

Não há vedação para que o servidor público – admitido mediante prévia aprovação em concurso público e ocupante de cargo de provimento efetivo – sirva sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil.

A norma antinepotismo deve incidir apenas sobre cargos em comissão, funções gratificadas e cargos de direção e assessoramento. Do contrário, essa proibição poderia inibir o provimento dos cargos de caráter efetivo, situação na qual ocorreria violação ao art. 37, I e II, da Constituição Federal (CF)¹, que garante o livre acesso aos cargos, funções e empregos públicos aos aprovados em concurso público.

No caso, o inciso VI do art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo estabelece ser “vedado ao servidor público servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil”. Tal dispositivo recebeu interpretação conforme à Constituição, no sentido de somente ser válido quando incidir sobre cargos de provimento em comissão, função gratificada e cargos de direção e assessoramento.

¹ CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

O concurso público é requisito inafastável de acesso aos cargos públicos.

Assim dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal (CF)¹, e esse entendimento é exhaustivamente reiterado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.²

Há situações excepcionais³ em que a Corte admite a transfiguração de cargos públicos e o consequente aproveitamento dos seus antigos titulares na nova classificação funcional.

A passagem de servidores de uma carreira em extinção para outra recém-criada pode ser feita como forma de racionalização administrativa, desde que haja substancial correspondência entre as características dos dois cargos, sobretudo a respeito das atribuições incluídas nas esferas de competência de cada uma.

Além disso, esses casos devem revelar um processo de sincretismo funcional, cujo ponto final seria uma previsível fusão.

Ausentes esses pressupostos, há burla ao postulado do concurso público, mediante o favorecimento de agentes públicos alçados por via legislativa a cargo de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram aprovados em concurso.

Por consequência, são inconstitucionais:

- a) a Lei 2.917/2004 do Estado do Amazonas; e
- b) as expressões “e de Comissário de Polícia” constante do inciso V, art. 5º; do parágrafo único do art. 10; da expressão e “Comissário de Polícia” constante do Anexo III; e da parte do Anexo IV que determina a transposição dos servidores do antigo cargo de Comissário de Polícia para o novo cargo de Comissário de Polícia de Classe Única (PC.COM-U), contidos na Lei amazonense 2.875/2004.

No caso, ambos os diplomas impugnados, ao promoverem a reestruturação do quadro de pessoas da Polícia Civil estadual, engendraram uma espécie de ascensão funcional de servidores investidos no cargo de comissário de polícia, içando-os à carreira de delegado de polícia sem concurso público.

- 1 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998) (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998).”
- 2 ADI 951, rel. min. Joaquim Barbosa, P.
- 3 ADI 1.591, rel. min. Octavio Gallotti, P; ADI 2.713, rel. min. Ellen Gracie, P; e ADI 2.335, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P.

- » Agentes públicos
 - » Concurso público
 - » Cláusula de barreira – Repercussão Geral

É constitucional a “cláusula de barreira”, regra que limita o número de candidatos participantes de fase subsequente de concurso, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame.

Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, não ferem o princípio da isonomia. Além disso, há certames em que tais cláusulas são imprescindíveis, em face da delimitação de número específico de candidatos e da exigência constitucional de eficiência.

É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Esses critérios, prescritos na Lei 12.990/2014¹, estão em consonância com o ordenamento constitucional, que rejeita todas as formas de preconceito e discriminação e impõe ao Estado o dever de atuar positivamente no combate ao racismo e na redução das desigualdades sociais [arts. 3º, III², e 5º, *caput* e XLII³, da Constituição Federal (CF)].

A desequiparação promovida por essa política de ação afirmativa condiz com o princípio da isonomia e se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira. Além disso, a lei visa garantir a igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. Dessa forma, a medida favoreceria a obtenção de postos de prestígio por um grupo historicamente alijado na distribuição de recursos e poder na sociedade, a superação dos estereótipos raciais, o aumento de autoestima da população negra, a redução dos preconceitos e da discriminação, a valorização do pluralismo e a promoção da diversidade na administração pública.

Nesse contexto, inexistente violação ao princípio do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não isenta os beneficiários da aprovação no certame para que sejam considerados aptos a exercer, de forma adequada e eficiente, um cargo público. Assim, mantém-se a livre concorrência no acesso ao serviço público, com igualdade de oportunidades para todos os candidatos, e a impessoalidade no processo seletivo.

A incorporação da raça como critério de seleção potencializa o princípio da eficiência ao criar um serviço público representativo, capaz de garantir que as opiniões e os interesses de toda a população sejam considerados nas decisões estatais, além de refletir a realidade da população brasileira.

A existência de uma política de cotas para ingresso de negros em universidades públicas não afeta a reserva de cargos disponíveis nos concursos públicos, tampouco gera vantagem dupla para seus beneficiários. Isso porque nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior e não necessariamente o beneficiário da ação afirmativa no serviço público utilizou-se de cotas para acesso à educação superior. Ademais, outros fatores impedem os negros de competir igualitariamente nos concursos públicos, como a ausência de condições financeiras para aquisição de material didático, para frequentar cursos preparatórios, para dedicar-se exclusivamente ao estudo, além da persistência de preconceitos.

A medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão: é adequada para a promoção do objetivo a que se destina; é necessária, pois não há medida alternativa menos gravosa e igualmente idônea à promoção dos objetivos da Lei 12.990/2014; e é proporcional em sentido estrito, pois o percentual de reserva de 20% das vagas para negros é razoável, visto que uma parcela relevante das vagas ainda continuará destinada à livre concorrência, tendo a lei previsto que a reserva somente será aplicada quando o número de vagas em disputa for igual ou superior a três.⁴ Além disso, a política instituída possui caráter transitório (dez anos), institui modelo de monitoramento anual dos resultados e emprega métodos de identificação do componente étnico-racial compatíveis com o princípio da dignidade humana.

Nesse cenário, é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação como mecanismos de controle de fraudes e de combate a abusos na autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Seriam aplicáveis, portanto, a autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, a exigência de fotos e a formação de comissões com composição plural para entrevista dos candidatos.

Com o objetivo de garantir a efetividade dessa política de ação afirmativa, a Administração Pública deverá aplicar os percentuais de reserva para todas as fases e vagas oferecidas nos concursos (não apenas para as previstas no edital de abertura). Os cargos disponíveis não poderão ser fracionados de acordo com a especialização exigida com o intuito de burlar a ação afirmativa, que só se aplica quando houver mais de duas vagas. Por fim, a ordem classificatória obtida a partir dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deverá produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas, influenciando promoções e remoções.

- 1 Lei 12.990/2014: “Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.”
- 2 CF/1988: Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.”
- 3 CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.”
- 4 Lei 12.990/2014: “Art. 1º (...) § 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três).”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Criação de novos cargos

A criação de novos cargos, ainda que no prazo de validade do concurso público, não gera direito líquido e certo de nomeação para aqueles aprovados fora do número de vagas do edital, por se tratar de ato discricionário e, portanto, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Edição de resolução pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)¹ – a qual determinava que as vagas criadas posteriormente fossem preenchidas com concurso então vigente – retirou do Tribunal Regional Eleitoral a discricionariedade de optar por fazer um novo concurso ou aproveitar os que já estavam concursados.

Reconheceu-se o direito subjetivo à nomeação, devendo ser respeitada a ordem de classificação no concurso público.

¹ Resolução TSE 21.832/2004, expedida em 22-6-2004.

- » Agentes públicos
 - » Concurso público
 - » Exame psicotécnico

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Com esse teor, o Plenário aprovou a edição do Enunciado 44 da Súmula Vinculante, tornando, assim, vinculante o Verbete 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, de mesma redação.

Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.

É inconstitucional a restrição elencada em edital de concurso para ocupação de cargo, emprego ou para o desempenho de função pública, sem expressa previsão legal¹, em observância ao princípio da legalidade e em conformidade com o art. 37, I, da Constituição Federal (CF)².

O legislador não pode escudar-se em pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, dos melhores candidatos. Por sua vez, os requisitos e impedimentos previstos em lei para o exercício de função pública devem ser compatíveis com a natureza e as atribuições das atividades a serem desempenhadas.³ Assim, restrições ofensivas aos direitos fundamentais que violem o princípio da proporcionalidade ou sejam impróprias para o exercício da função pública são inconstitucionais.

É certo que as tatuagens perderam, há algum tempo, o estigma de caráter marginal. Atualmente, são vistas como obra artística e alcançam os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais variadas idades. Considerando que é direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, o Estado não pode desestimular a inserção voluntária de tatuagens no corpo, pois estaria se opondo à livre manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CF, art. 5º, IV⁴ e IX⁵).

Incumbe ao Estado estimular o livre intercâmbio de opiniões em um mercado de ideias, indispensável para a formação da opinião pública, e assegurar que minorias possam se manifestar livremente no meio social, o que inclui a não intromissão e o respeito ao direito de escolha. Por sua vez, a Administração Pública deve exercer a discricionariedade entrincheirada não apenas pela avaliação unilateral a respeito da

conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em ambiente de perene diálogo com a sociedade.

Ademais, com base nos princípios da liberdade e da igualdade, não há justificativa para que a Administração Pública e a sociedade visualizem, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade, inidoneidade ou inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. Portanto, o Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o simples fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. Afinal, isso não macula, por si, a honra pessoal, o profissionalismo e o respeito às instituições, tampouco lhe diminui a competência.

No ordenamento jurídico pátrio, vale destacar a existência de diversas leis sobre o tema no âmbito das Forças Armadas, direcionadas especificamente para a Marinha⁶, a Aeronáutica⁷ e o Exército⁸, e que proíbem, apenas, tatuagens ofensivas a determinados valores institucionais ou que representem ofensa à ordem pública. Quanto à lei específica do Exército, Lei 12.705/2012, nota-se a existência de veto da Presidência da República ao critério proposto de restrição ao ingresso de candidatos portadores de tatuagens que, “pelas suas dimensões ou natureza, prejudiquem a camuflagem e comprometam as operações militares” (art. 2º, VIII, *b*). A justificativa para o veto amparou-se na hodierna orientação de que o *discrímen* só se explica quando acompanhado de parâmetros razoáveis ou de critérios consistentes para sua aplicação.

Nesse contexto, cláusula editalícia que prevê impedimento à participação de candidato em concurso público em análise meramente estética, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse seu afastamento do certame, mercê de não possuir fundamento de validade em lei, revela-se preconceituosa, discriminatória e desprovida de razoabilidade. Além de não encontrar amparo na realidade, essa restrição afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado no art. 3º, IV, da CF⁹, o que impede que as tatuagens sejam inseridas no rol dos critérios para o reconhecimento de uma inaptidão.

Eventual restrição só se justifica excepcionalmente, caso seja necessária à finalidade que ela pretende alcançar e à natureza do cargo público. Destarte, a tatuagem que viole valores institucionais ou constitucionais, ofenda a dignidade humana (como as de incentivo ao ódio), represente obscenidades, expresse ideologias terroristas, extremistas e contrárias às instituições democráticas, incite a violência, a ameaça e a criminalidade, ou incentive a discriminação ou preconceitos de raça e sexo, ou qualquer outra força de intolerância, é incompatível com o exercício de qualquer cargo público.

- 1 RE 593.198 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T; ARE 715.061 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T; RE 558.833 AgR, rel. min. Ellen Gracie, 2ª T; RE 398.567 AgR, rel. min. Eros Grau, 1ª T; e MS 20.973, rel. min. Paulo Brossard, P.
- 2 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.”
- 3 ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P.
- 4 CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.”
- 5 CF/1988: “Art. 5º (...) IX – É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.”
- 6 Lei 11.279/2006: “Art. 11-A. (...) XII – não apresentar tatuagem que, nos termos de detalhamento constante de normas do Comando da Marinha, faça alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, a violência, a criminalidade, a ideia ou ato libidinoso, a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou, ainda, a ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas.”
- 7 Lei 12.464/2011: “Art. 20. (...) XVII – não apresentar tatuagem no corpo com símbolo ou inscrição que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro exigido aos integrantes das Forças Armadas que faça alusão a: a) ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade; b) discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem; c) ideia ou ato libidinoso; e d) ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas ou à sociedade.”
- 8 Lei 12.705/2012: “Art. 2º (...) VIII – não apresentar tatuagens que, nos termos de detalhamento constante de normas do Comando do Exército: a) faça alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, a violência, a criminalidade, a ideia ou ato libidinoso, a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou, ainda, a ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas; b) (VETADO);”
- 9 CF/1988: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da Constituição Federal (CF)¹, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.^{2 e 3}

A controvérsia foi dirimida na ADI 3.460⁴ e não é caso de superação da tese. Portanto, não há que falar em *overruling* ou superação total. Não houve mudanças nos planos fático ou jurídico a indicar que tenha se tornado ou esteja na iminência de se tornar inconstitucional o entendimento acerca da exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do Ministério Público.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao uniformizar a aplicação do Direito, tem como objetivo dar unidade à ordem jurídica e estabilidade aos seus precedentes. A leitura no novo Código de Processo Civil (CPC), relacionada à força dos precedentes, reforça essa conclusão.

Nesse sentido, o *caput* do art. 926 do CPC⁵ traça importante diretriz para o Poder Judiciário. Também há em seus parágrafos duas orientações que reforçam a adoção da teoria do *stare decisis* pelo sistema processual: “(os Tribunais) editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante” (CPC, art. 926, § 1º) e que, ao editá-los, “devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação” (CPC, art. 926, § 2º).

Ademais, após a decisão tomada na ADI 3.460, considerando-se o número de concursos e concursandos para a carreira da magistratura, os poucos recursos sobrestados pela Corte indicam reforço, estabilidade, cognoscibilidade e calculabilidade do precedente. Não está demonstrado, portanto, desgaste.

Logo, em termos de segurança jurídica e de isonomia, eventual alteração no entendimento do STF sobre o termo final do triênio citado traria mais prejuízos do que benefícios.

- 1 CF/1988: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;”
- 2 No caso concreto, entretanto, admitiu-se a posse da recorrida porque, no edital do concurso, não houve especificidade quanto à data para comprovação do período de atividade jurídica e a fase de inscrição definitiva, em relação à candidata, estava sendo discutida judicialmente. Além disso, nesse interim, o triênio de atividade jurídica transcorreu.
- 3 Tese fixada para o Tema 509 da Gestão por Temas da Repercussão geral do portal do STF: “A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.”
- 4 ADI 3.460, rel. min. Teori Zavascki, P.
- 5 CPC: “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Ingresso na carreira

O servidor investido na função de defensor público até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte pode optar pela carreira, independentemente da forma da investidura originária.

Essa faculdade decorre da previsão expressa contida no art. 22 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)¹. Após esse marco, é inconstitucional lei estadual que admita, na função de defensor público, servidores que não ingressaram na carreira mediante concurso, por afronta ao disposto nos arts. 37, II², e 134, § 1º³, da Constituição Federal (CF).

A autonomia de que são dotadas as entidades estatais para organizar seu pessoal e respectivo regime jurídico não afasta as normas gerais de observância obrigatória pela Administração Direta e Indireta estipuladas na CF⁴, em seu art. 25⁵.

1 ADCT: “Art. 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da Constituição.”

2 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

3 CF/1988: “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (...) § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.”

4 ADI 3.819, rel. min. Eros Grau, P.

5 CF/1988: “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Ingresso na carreira

A expressão “três anos de atividade jurídica” contida no art. 129, § 3º, da Constituição Federal (CF)¹ não se limita a atividade privativa de bacharel em Direito.

Em concursos públicos, deve-se viabilizar, tanto quanto possível, o acesso dos cidadãos em geral, descabendo haver distinções sem respaldo constitucional.² Por isso, os “três anos de atividade jurídica” devem ser exigidos no momento da posse (CF, art. 37, I e II) e não correspondem a atividade específica de bacharel.

Cumpre reconhecer que, em certames posteriores ao do caso em tela, o Ministério Público Federal passou a admitir a validade da demonstração do desempenho de atividades de natureza preponderantemente jurídica quando do ingresso no cargo público. A vedação de observância retroativa de nova interpretação de norma administrativa (Lei 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, XIII³) não alcança os casos nos quais o órgão administrativo adotou indevida prática limitadora de direitos.

- 1 CF/1988: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) § 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.”
- 2 “Como fiz ver ao votar na ADI 3.406, relator o ministro Carlos Ayres Britto, a referência a três anos de atividade jurídica, consoante previsão do art. 129, § 3º, da Carta de 1988, deve ser exigida quando da posse – o que decorre dos incisos I e II do art. 37 da Carta da República – e não corresponde a atividade específica que demande o grau de bacharel.” (Trecho do voto do rel. min. Marco Aurélio no presente julgamento.)
- 3 Lei 9.784/1999: “Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Ingresso na carreira

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Com esse teor, o Plenário aprovou a edição do Enunciado 43 da Súmula Vinculante, tornando, assim, vinculante o Verbete 685 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, de mesma redação.

Os serviços sociais autônomos não estão sujeitos à observância da regra de concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal (CF)¹, para contratação de seu pessoal.

As entidades integrantes do chamado Sistema “S”² possuem natureza jurídica de direito privado e, mesmo que desempenhem atividade de interesse público em cooperação com o ente estatal, não integram a Administração Pública. Além disso, esses serviços sociais são vinculados às entidades patronais de grau superior e patrocinados, basicamente, por recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado. Assim, têm inegável autonomia administrativa.

Nada obstante, essa autonomia tem limites no controle finalístico exercido pelo Tribunal de Contas da União quanto à aplicação dos recursos recebidos, sujeição que decorre do art. 183 do Decreto-Lei 200/1967 e do art. 70 da Constituição.³

De qualquer forma, a não obrigatoriedade de submissão das entidades do denominado Sistema “S” aos ditames constitucionais do art. 37, notadamente ao seu inciso II, não as exime de manter um padrão de objetividade e eficiência na contratação e nos gastos com seu pessoal. Essa exigência traduz requisito de legitimidade da aplicação dos recursos arrecadados na manutenção de sua finalidade social, porquanto se trata de entidades de cooperação a desenvolver atividades de interesse coletivo.⁴

¹ CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

² Serviço Social do Transporte (Sest); Serviço Nacional de Aprendizagem no Cooperativismo (Sescoop); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac); Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço de Aprendizado Industrial (Senai); e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

- 3 No caso concreto, tendo em conta que o recorrido era o Sest, mencionou-se que a entidade estaria sujeita às auditorias a cargo do Ministério dos Transportes e à aprovação de seus orçamentos pelo Poder Executivo.
- 4 A Corte enunciou as características básicas desses entes autônomos: a) dedicam-se a atividades privadas de interesse coletivo cuja execução não é atribuída de maneira privativa ao Estado; b) atuam em regime de mera colaboração com o Poder Público; c) possuem patrimônio e receita próprios, constituídos, majoritariamente, pelo produto das contribuições compulsórias que a própria lei de criação institui em seu favor; e d) possuem a prerrogativa de autogerir seus recursos, inclusive no que se refere à elaboração de seus orçamentos, ao estabelecimento de prioridades e à definição de seus quadros de cargos e salários, segundo orientação política própria. Alertou para a necessidade de não se confundirem essas entidades, tampouco equipará-las a outras criadas após a CF/1988, como a Associação dos Pioneiros Sociais (APS), a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), cuja configuração jurídica teria peculiaridades próprias: a) criadas por autorização de lei e implementadas pelo Poder Executivo, não por entidades sindicais; b) não destinadas a prover prestações sociais ou de formação profissional a determinadas categorias de trabalhadores, mas a atuar na prestação de assistência médica qualificada e na promoção de políticas públicas de desenvolvimento setoriais; c) financiadas, majoritariamente, por dotações consignadas no orçamento da União; d) obrigadas a gerir seus recursos de acordo com os critérios, metas e objetivos estabelecidos em contrato de gestão cujos termos seriam definidos pelo próprio Poder Executivo; e e) supervisionadas pelo Poder Executivo, quanto à gestão de seus recursos. Assim, a ausência de imposição normativa de observância obrigatória dos princípios gerais da Administração Pública na contratação de pessoal não se aplica a esses serviços sociais – APS, Apex e ABDI – e outras espécies de entidades colaboradoras com o poder público, cuja disciplina geral impõe a adoção desses princípios. Precedentes citados: ADI 1.864, red. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, P; ARE 683.979, rel. min. Luiz Fux, decisão monocrática; RE 366.168, rel. min. Sepúlveda Pertence, 2ª T; e AI 349.477 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T.

O limite de idade¹, quando regularmente fixado em lei² e em edital de concurso público, deve ser comprovado no momento da inscrição no certame.³

É impossível antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade máxima, uma vez que pode haver demora e desídia da Administração Pública para prosseguir com o certame. Os atrasos no andamento do concurso podem fazer com que o candidato deixe de preencher o requisito de idade máxima.

Entendimento diverso levaria a imediato prejuízo ao candidato, em decorrência da demora da Administração Pública em proceder a todas as fases do concurso. Assim, apenas as pessoas com idade bem inferior ao limite estipulado no edital poderiam se submeter ao certame.

1 Enunciado 683 da Súmula do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

2 Tema 646 da repercussão geral – *leading case*: ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, Plenário Virtual. O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

3 ARE 721.339 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Nomeação – Repercussão Geral

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Não há liame imediato entre a conduta da Administração e o alegado prejuízo. Por se tratar de responsabilidade civil do Estado, a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta.

A promoção ou progressão funcional não se resolve unicamente mediante o cumprimento de requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições previstas em lei. Apenas se pode verificar o atendimento a esses pressupostos após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do cidadão com a Administração.

Somente considerado o desempenho do agente, por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício, é possível alcançar a confirmação no cargo, bem assim a movimentação funcional.

A simples consulta feita ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional às inicialmente previstas em concurso público, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame.

A manifestação do MPOG é autorizativa para a nomeação de candidatos aprovados e não classificados no certame. Se ela não se configurar, inexistirá direito líquido e certo ao provimento do cargo pretendido, porque a vaga nunca existiu.

Ademais, caso demonstrada a ausência do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso público durante o prazo de validade do certame, será inadequada a aplicação do precedente julgado pelo Plenário no RE 837.311 RG (DJE de 18-4-2016)¹.

¹ Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal definiu que, com o surgimento de novas vagas, a preterição de candidato excedente será configurada quando a Administração agir de forma imotivada e arbitrária. Assim, haveria direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público quando: i) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas; ii) houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; e iii) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Ressalvam-se as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Incumbe à Administração, no âmbito de seu espaço de discricionariedade, avaliar, de forma racional e eficiente, a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do certame.

Assim, a despeito de a Administração, ao iniciar um processo seletivo, manifestar evidente intenção e necessidade de preencher determinados cargos públicos, podem existir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a incorrência da nomeação no curto prazo. Desse modo, mesmo a vacância dos cargos e a publicação do novo edital durante a validade do concurso podem obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.

Entretanto, a referida discricionariedade precisa manter coerência com o Direito Administrativo contemporâneo, ou seja, não é livre e irrestrita, mas vinculada a certas premissas. Deve basear-se no dever de boa-fé da Administração Pública, além de pautar-se por incondicional respeito aos direitos fundamentais e aos princípios da eficiência, da impessoalidade, da moralidade e da proteção da confiança, todos inerentes ao Estado de Direito.

Se é verdade que a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público além do número de vagas do edital está sujeita à discricionariedade da Administra-

ção Pública, não menos verdadeiro é o fato de que essa discricionariedade deve ser exercida legitimamente.

Nenhum candidato, esteja ele dentro ou fora do número de vagas do edital, pode ficar refém de condutas que, deliberadamente, deixem escoar, desnecessariamente e, por vezes, de modo reprovável, o prazo de validade do concurso para que sejam nomeados, apenas, os aprovados em novo concurso.

Se a Administração decidir preencher imediatamente determinadas vagas por meio do necessário concurso, e existirem candidatos aprovados em cadastro de reserva de concurso válido, o princípio da boa-fé vincula a discricionariedade da Administração e lhe impõe o necessário preenchimento das vagas pelos aprovados no certame ainda em validade.

Desse modo, quem for aprovado em concurso além das vagas previstas no edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, mesmo que aberto novo edital durante a validade do certame (Constituição Federal, art. 37, IV). Possui, ao revés, mera expectativa de direito, que será convolada em direito adquirido à nomeação apenas na excepcional circunstância de ficar demonstrada, de forma inequívoca, a necessidade de novas nomeações durante a validade do concurso. Dito de outra forma: uma coisa é a mera vacância do cargo; outra, a vacância acompanhada do manifesto comportamento da Administração destinado a prover os cargos durante a validade do certame. Contudo, tal vontade não fica caracterizada pela mera publicação de novo edital de concurso.

Em síntese, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

- a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas estipulado no edital;
- b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e
- c) quando surgirem novas vagas ou, aberto outro concurso durante a validade do certame anterior, ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração nos termos acima.

Os contratos de emprego firmados pela Administração Pública sem prévio concurso público, embora nulos, geram direitos em relação ao recolhimento e levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O direito aos depósitos efetuados na conta do FGTS apresenta caráter compensatório e, sob todos os aspectos, legítimo, em face da Constituição Federal (CF).¹

Deve-se considerar que, embora fundada em ato jurídico formalmente ilegítimo, houve a efetiva prestação do trabalho, da qual a Administração contratante tirou proveito. Assim, tendo em vista que o trabalhador cumpriu a sua parte, a prestação contratual não pôde ser desfeita e, por isso, deve ser considerada de alguma forma, sob pena do comprometimento da relação sinalagmática e do consequente enriquecimento ilícito do tomador à custa do trabalho alheio.

Ademais, a nulidade do contrato, por ausência de concurso, foi causada fundamentalmente pelo contratante, não pelo empregado. Nesse sentido, admitir que as consequências da nulidade devam ser inteiramente atribuídas ao trabalhador, não ao tomador do trabalho, é um pressuposto inadmissível.

Dessa forma, o art. 19-A da Lei 8.036/1990, incluído pela Medida Provisória (MP) 2.164/2001, não afronta o princípio do concurso público contido no art. 37, II e § 2º, da CF, pois não invalida a nulidade das contratações feitas à margem dessa exigência. Afinal, apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais e prestou o serviço devido.

Por outro lado, os preceitos em questão apenas enxergaram com maior sensibilidade a situação de vulnerabilidade a que ficam expostos os trabalhadores afetados pela extinção anômala do seu vínculo empregatício, gerada por efeito de uma irregularidade para a qual eles não contribuíram. Com isso, o FGTS tem ampliado o seu espectro de proteção, passando a compensar não apenas os riscos estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa, mas a cobrir outros eventos socialmente indesejáveis, tais como a própria situação de desemprego.

Por fim, não há interferência na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que não foi criada qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária. Trata-se, apenas, de relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já seria ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados.

São constitucionais, portanto, o art. 19-A e seu parágrafo único² e a expressão “declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do art. 19-A” constante do inciso II do art. 20 da Lei 8.036/1990³, com a redação dada pela MP 2.164-41/2001.

1 O caráter compensatório dessa norma teria sido considerado legítimo pelo Tribunal no julgamento do RE 596.478, red. p/ o ac. min. Dias Toffoli, P, com repercussão geral reconhecida.

2 Lei 8.036/1990: “Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do *caput*, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.”

3 Lei 8.036/1990: “Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: (...) II – extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do artigo 19-A (...);”

- » Agentes públicos
 - » Concurso público
 - » Nulidades – Repercussão Geral

É nula e sem efeitos jurídicos válidos a contratação de pessoal pela Administração Pública sem observância de prévia aprovação em concurso público, além das hipóteses excepcionadas pela própria Constituição, ressalvados os direitos à percepção dos salários e depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Por essa razão – e em decorrência da aplicação do art. 37, § 2º, da Constituição Federal – não constitui dano juridicamente indenizável a negativa de pagamento de verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho. Entretanto, os salários relativos ao período trabalhado e o levantamento dos depósitos de FGTS são devidos, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado à custa dos serviços efetivamente prestados pelo trabalhador.

Em concurso público, reconhece-se violado o princípio da isonomia [Constituição Federal (CF), art. 5º, *caput*] quando é considerado título o mero exercício de cargo ou função pública ou é valorizado excessivamente o desempenho de atividades relacionadas àquelas inerentes aos cargos em disputa no certame.

Nessas hipóteses, cria-se privilégio a determinado grupo de candidatos em detrimento dos demais¹, de forma que a disciplina do assunto pode revelar diferenciação arbitrária.

Deve-se fazer, ainda, distinção entre os concursos de ingresso e os de remoção. Nestes, só não pode ser levado em conta o tempo de serviço notarial anterior ao ingresso na atividade.² Em tais casos, a consideração do tempo de serviço tem como marco inicial a assunção do cargo mediante o concurso, sem que isso implique violação ao princípio da isonomia.

Em virtude disso, declarou-se a inconstitucionalidade do inciso I e da expressão “e apresentação de temas em congressos relacionados com os serviços notariais e registrares” constante do inciso II, ambos do art. 17 da Lei 12.919/1998 do Estado de Minas Gerais³, que dispõe sobre os concursos de ingresso e remoção nos serviços notariais e de registro do Estado-membro.

Por fim, modularam-se os efeitos da decisão, para que a declaração de inconstitucionalidade só tenha efeitos a partir de 8-2-2006, data da concessão da medida acauteladora.

¹ ADI 3.522, rel. min. Marco Aurélio, P; ADI 3.443, rel. min. Carlos Velloso, P; e ADI 2.210 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, P.

² ADI 3.522 ED, rel. min. Marco Aurélio, P.

³ Lei 12.919/1998 do Estado de Minas Gerais: “Art. 17. O candidato não eliminado nas provas de conhecimento poderá apresentar títulos, considerando-se como tais os seguintes: I – tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente em serviço notarial ou de registro; II – trabalhos jurídicos publicados, de autoria única, e apresentação de temas em congressos relacionados com os serviços notariais e registrares;”

Direito Administrativo

- » Agentes públicos
 - » Concurso público
 - » Prova de títulos

MS 31.176

DJE de 6-11-2014

MS 32.074

DJE de 8-11-2014

rel. min. **Luiz Fux**

1ª Turma

Informativo STF 757

As provas de títulos em concurso para provimento de cargos públicos efetivos na Administração Pública, em qualquer um dos Poderes e em qualquer nível federativo, não podem ostentar natureza eliminatória, uma vez que sua finalidade é, unicamente, classificar os candidatos, sem jamais justificar a eliminação do certame.

Ademais, mesmo as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que se insiram no campo administrativo estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança, a ser impetrado diretamente ao Supremo Tribunal Federal, já que a Corte não distingue as situações em que o CNJ adentre, ou não, a matéria de fundo. Afinal, em se tratando de competência recursal, a decisão do órgão *ad quem* substitui a decisão do órgão *a quo*, qual seja, o ato originalmente questionado.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Regramento jurídico

Não compete ao Conselho Nacional de Justiça examinar o conteúdo de questões formuladas em provas de concursos públicos nem avaliar seus critérios de correção.

Não cabe ao Judiciário substituir a comissão de concurso na valoração do conteúdo das questões formuladas e dos critérios de correção.¹ Excepcionalmente, é permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

A ausência de oportunidade de manifestação dos interessados na apuração de supostas irregularidades de concurso público, em sede de controle administrativo, viola o devido processo legal.

Assiste ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanção da garantia constitucional do devido processo legal, independentemente de previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos estatais, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

A abrangência da cláusula constitucional do devido processo legal compreende o direito à prova. Assim, o fato de o poder público considerar suficientes os elementos de informação produzidos no procedimento administrativo não legitima nem autoriza a adoção pelo órgão competente de medidas que, tomadas em detrimento daquele que sofre a persecução administrativa, culminem por frustrar a possibilidade de o próprio interessado produzir as provas que repute indispensáveis à demonstração de suas alegações e que entenda essenciais à condução de sua defesa.²

Não é possível anular concurso público com base em mera presunção de favorecimento a candidatos por parte da banca examinadora.

A decisão que aponta a ocorrência de favorecimento a ensejar a anulação de concurso público deve demonstrar a incidência desse fator. A mera existência de relação de amizade ou afetiva entre integrantes do órgão ou entidade que realiza o certame e participante deste não implica irregularidade, uma vez que a Constituição garante a participação de todos em concursos públicos, direito subjetivo assegurado aos cidadãos, em geral, desde que atendidos os requisitos legais.

1 RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P.

2 RMS 28.517 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Regramento jurídico

As novas resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplicam a concursos em andamento.

A aplicação dessas alterações a concurso em andamento implica abalo à confiança depositada no tocante à observância da versão original do instrumento convocatório, à qual o órgão organizador do certame encontra-se vinculado.

O novel ato normativo, ainda que válido e destinado a afastar incongruência até então existente na disputa, não pode suplantar a estabilidade de certame já iniciado, sob pena de abalar-se o necessário respeito à segurança jurídica.

Por isso, a Resolução 187/2014 do CNJ – que disciplina a contagem de títulos em concursos públicos para outorga de serventias extrajudiciais – não se aplica a concursos já em andamento quando do início de sua vigência.¹

¹ MS 28.375, rel. min. Rosa Weber, P.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Regramento jurídico¹

A estabilidade excepcional, prevista pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)², não dá direito à efetividade ou a qualquer tipo de transposição, tampouco permite que o servidor integre a carreira sem a prévia aprovação em concurso público.

A mencionada estabilidade não se confunde com o provimento efetivo em cargo público, pois esse pressupõe aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme entendimento sintetizado no Enunciado 685 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF)³.

O servidor estável, nos termos do citado preceito constitucional transitório, tem assegurada somente a permanência no cargo para o qual foi arrematado.

Em virtude disso, foi declarada a inconstitucionalidade dos §§ 3º, 4º e 6º do art. 231 da Lei Complementar (LC) 165/1999 do Estado do Rio Grande do Norte⁴, com a redação emprestada pela LC estadual 174/2000, que conferiam o direito de enquadramento definitivo aos auxiliares de cartório que contavam com cinco anos de exercício quando promulgada a Constituição Federal (CF) de 1988.

Por outro lado, foi conferida interpretação conforme à Constituição ao § 2º do art. 231 da LC estadual 165/1999⁵ – que dispõe sobre a possibilidade de os escrivães que acumulam as funções notarial e registral optarem pelo cargo de técnico judiciário –, para que a abrangência da norma se estenda apenas aos escrivães que acumulavam funções notarial e registral além das atinentes a cargo efetivo, alcançado mediante concurso público, considerados os juízos.

¹ O ministro Marco Aurélio assentou que cumpre ao advogado-geral da União – ante a norma imperativa prevista no art. 103, § 3º, da CF – defender o ato impugnado em ação direta de inconstitucionalidade, e não emitir parecer no sentido da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. O ministro Teori Zavascki, por sua vez, manifestou-se em sentido contrário: “(...) quanto à posição do ministro relator em relação à natureza da manifestação da AGU, que a jurisprudência do Supremo é majoritária num sentido diferente, e por isso eu faço essa ressalva.”

- 2 ADCT: “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”
- 3 Enunciado 685 da Súmula do STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
- 4 LC 165/1999 do Estado do Rio Grande do Norte: “Art. 231. Os atuais cargos de Escrivão, Escrevente Substituto e Ajudante de Cartório Oficializado são transformados nos cargos de Técnico Judiciário. (...) § 3º Fica assegurado aos Auxiliares de Cartórios, que se encontravam com cinco (05) anos cumpridos de exercício ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, e que permaneceram vinculados ao serviço, quando da vigência da Lei Complementar n. 165, de 28 de abril de 1999, o direito de optar pelo enquadramento definitivo no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário. § 4º O enquadramento de que trata o parágrafo anterior dar-se-á no cargo de Auxiliar Técnico – Nível AT-1, e far-se-á mediante requerimento do interessado, dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, ficando o requerente obrigado a apresentar documentação comprobatória do ato da designação perante a serventia judicial e do termo de compromisso, bem como da permanência vinculada à Secretaria Judicial. (...) § 6º O disposto no § 3º deste artigo aplica-se aos serviços extrajudiciais que estiverem vagos na data da vigência desta Lei ou os que vierem a vagar no prazo de um ano, desde que preencham os requisitos ali previstos.”
- 5 LC 165/1999 do Estado do Rio Grande do Norte: “Art. 231. (...) § 2º Os escrivães que acumulam as funções notarial e registral podem optar pelo cargo de Técnico Judiciário, contanto que o façam no prazo de dez dias a partir da instalação da Secretaria do respectivo Juízo.”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Regramento jurídico

Eventual desrespeito ao que disciplinado pelo edital consubstancia violação ao princípio da legalidade e autoriza o prejudicado a buscar a correção.

O edital de concurso público rege as relações entre os candidatos e a Administração Pública, de forma que ambos estão igualmente submetidos às suas regras. Nesse contexto, não possui aplicabilidade o art. 70, § 1º, da Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe ser irretratável em sede recursal a nota atribuída na prova oral, haja vista que conclusão diversa redundaria no não cabimento de recurso administrativo quando houvesse, inclusive, eventuais erros manifestos no processamento de concurso público.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Regramento jurídico

Não é obrigatória a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no âmbito da atuação revisional do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça no tocante à legalidade do resultado da prova preambular de concurso público para ingresso na carreira de promotor de justiça.

Tendo em vista que o controle de legalidade por meio de autotutela¹ não constitui fase do concurso público, não há que falar na obrigatoriedade de participação do indicado pela OAB para representá-la no certame na solução do conflito. Nada obstante, mantém-se resguardada a competência da comissão do concurso, integrada por representante da OAB, para decidir acerca do conteúdo da prova e do mérito das questões.

Embora o edital seja a lei do certame e vincule tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não pode preponderar sobre direito previsto em lei, a exemplo da previsão contida na lei orgânica do Ministério Público estadual – a qual compõe e regulamenta o certame –, que admite recurso contra decisão da comissão de concurso que provoque o Conselho Superior do Ministério Público estadual, bem como o Colégio de Procuradores de Justiça.

¹ No caso, a autotutela foi exercida para anular questões em razão de erro grosseiro no enunciado, bem como questões com exigência de conteúdo não previsto no edital.

Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

Não compete ao Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reapreciar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.¹

Apesar disso, exige-se que a banca examinadora atribua tratamento igual a todos os candidatos, aplicando-lhes, indistintamente, a mesma orientação.

Apenas excepcionalmente é permitido ao Judiciário analisar a compatibilidade do conteúdo das questões de concurso com o previsto no edital do certame.

1 Nesse sentido, entre outros precedentes citados no voto do relator: MS 21.176, rel. min. Aldir Pas-sarinho, P; MS 21.408, rel. min. Moreira Alves, P; MS 27.260, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, P; e AO 1.395 ED, rel. min. Dias Toffoli, P.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Revisão judicial das provas

Questões de prova objetiva que apresentem sequência de proposições a serem analisadas individualmente quanto à correção, para posterior marcação no gabarito de uma única alternativa, indicando a somatória correta das que seriam verdadeiras ou falsas¹, não violam as normas regentes do concurso público.² Segundo tais regras, a prova preambular seria de múltipla escolha, constando de questões objetivas, de pronta resposta e apuração padronizada, com a finalidade de selecionar os candidatos a serem admitidos para as provas subsequentes.

Embora as questões impugnadas tenham estrutura objetivamente diversa das demais perguntas, os parâmetros norteadores da elaboração da prova foram atendidos. Assim, não há que falar em vício insanável por violação das normas do concurso. A estrutura adotada para as assertivas não as transforma em questionamentos destituídos de objetividade de modo a descaracterizar o requisito da “pronta resposta”.

Responder a uma questão formulada no modelo impugnado pode ser razoavelmente mais difícil do que responder às demais, assim como recorrer do gabarito pode ser mais exaustivo. Entretanto, graus de dificuldade diversos não justificam a impugnação do modelo mais complexo nem são incompatíveis com o objetivo de concurso destinado a medir conhecimentos de vários tipos – não só jurídicos, mas também lógicos e gramaticais – entre candidatos que almejam cargo público de relevo.

O método de avaliação, em si, não apresenta dificuldade intransponível à impetrante ou a qualquer outro candidato, desde que disponham do conhecimento adequado. Tampouco há completa impossibilidade de recorrer do gabarito. Por isso, não se verificam ilegalidades passíveis de correção pela via do mandado de segurança.

É cabível mandado de segurança quando deduzida pretensão relativa ao estrito controle de legalidade acerca da forma redacional de questões de concurso, sob o parâmetro das normas regulamentares incidentes.

Nessas circunstâncias, a atuação jurisdicional não envolve a revisão do mérito administrativo no âmbito de concurso público. Diz respeito, na verdade, a normas do órgão regulamentador do concurso que disciplinam aspectos formais da redação a ser conferida às questões de múltipla escolha utilizadas para formular as perguntas da fase objetiva do concurso.

Assim, o que se alega é a discrepância entre a atividade administrativa e as normas regulamentares, além da violação dessas regras e de princípios considerados incidentes (legalidade, moralidade, transparência, objetividade, segurança jurídica e isonomia). O exame jurisdicional do tema se limita, portanto, ao controle de legalidade, não avançando na seara do mérito administrativo.

Por fim, destaca-se que esta controvérsia é diferente daquela enfrentada em precedentes da Suprema Corte relativos ao amplo tema “concursos públicos”³, quando o Supremo Tribunal Federal indeferiu a ordem diante da inviabilidade da mera substituição do juízo de mérito administrativo pelo jurisdicional.

1 Nas questões impugnadas, foram propostas alternativas como “existem duas assertivas verdadeiras” e suas variantes, de acordo com o número de proposições oferecidas.

2 Na espécie, arguia-se violação ao art. 29 da Resolução 116/2011 do Conselho Superior do Ministério Público: “Art. 29. Haverá uma prova escrita objetiva, com duração de 5 (cinco) horas, com 120 (cento e vinte) questões de pronta resposta, divididas em 4 (quatro) partes, com 30 (trinta) questões cada, correspondendo cada parte a um dos grupos de disciplinas. § 1º Cada questão terá 4 (quatro) alternativas de resposta, a que se acrescentará, exclusivamente na folha de respostas, uma quinta alternativa, destinada à manifestação do candidato, necessária e obrigatória, de que desconhece a alternativa correta. Não assinalada a quinta alternativa, a questão deixada sem resposta ou marcada com mais de uma opção, incluindo ou não a quinta alternativa, equivalerá a questão com resposta errada para o fim do desconto previsto no parágrafo seguinte. § 2º Na correção da prova objetiva, as questões terão o mesmo valor, descontando-se o valor de uma resposta certa para cada conjunto de 4 (quatro) respostas erradas, em cada parte da prova”; e ao art. 17 da Resolução 14/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público: “Art. 17. As provas escritas serão desdobradas em duas etapas, a saber: I – prova preambular, de múltipla escolha, constando de questões objetivas, de pronta resposta e apuração padronizada, em número estabelecido pelo edital, com a finalidade de selecionar os candidatos a serem admitidos às provas previstas no inciso II deste artigo. § 1º A prova preambular não poderá ser formulada com base em entendimentos doutrinários divergentes ou jurisprudência não consolidada dos tribunais. As opções consideradas corretas deverão ter embasamento na legislação, em súmulas ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.”

3 MS 26.849 AgR, rel. min. Luiz Fux, P; MS 30.860, rel. min. Luiz Fux, 1ª T; MS 30.144 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T; e AI 827.001 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T.

É ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta.

O art. 236, *caput* e § 3º, da Constituição Federal (CF)¹ é autoaplicável, produzindo efeitos mesmo antes da publicação da Lei 8.935/1994². Assim, desde a promulgação da CF, é aplicável a exigência constitucional de prévia realização de concurso público para as hipóteses de ingresso ou remoção na delegação de serventias extrajudiciais. Isso exclui a própria possibilidade de permuta, ainda que os envolvidos tenham ingressado por meio de concurso público.

Essa autoaplicação independe da declaração de inconstitucionalidade de lei estadual com base na qual foi praticado o ato. Nesses casos, descabe invocar o princípio da segurança jurídica, que não se sobrepõe à determinação constitucional expressa.

Ademais, o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei 9.784/1999³ não se aplica em casos de inconstitucionalidade. Em tais hipóteses, não há confiança legítima a ser tutelada, uma vez que se trata de ato que evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional.

Logo, o prazo decadencial é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais realizados após a Constituição de 1988 em desconformidade com as exigências prescritas no art. 236, *caput* e § 3º, da CF, pois o concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta.⁴

Nesse sentido, inexistente ofensa à segurança jurídica e ao direito adquirido, tampouco afronta ao art. 54 da Lei 9.784/1999, em ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, valendo-se de informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça estadual e citando a Resolução CNJ 80/2009⁵, declarou a vacância de serventia extrajudicial provida por permuta realizada sem prévio concurso público, por se tratar de ato nulo.

Por fim, do mesmo modo que é ilícito alguém ocupar determinado cargo por força de titularização inconstitucional, também é ilícito perder o direito ao cargo de origem, para o qual havia ingressado mediante concurso público. Logo, apesar de a

permuta descrita ter se realizado sem o anterior certame, há o direito de retorno ao cargo para o qual houve a nomeação original após aprovação em concurso público.

- 1 MS 28.371 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, P; e MS 28.279, rel. min. Ellen Gracie, P.
- 2 Lei 8.935/1994: “Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro (Lei dos cartórios).”
- 3 Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”
- 4 MS 29.265 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1ª T; MS 28.279, rel. min. Ellen Gracie, P; MS 28.371 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, P; e MS 28.273, rel. min. Ricardo Lewandowski, P.
- 5 Resolução CNJ 80/2009: “Declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público.”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Serventias extrajudiciais

As serventias extrajudiciais vagas¹, embora *sub judice*, devem ser incluídas no edital de concurso para ingresso/remoção referente à atividade notarial e de registro.

A redução da oferta de serventias coloca em xeque a própria atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que editou resolução para incluir no certame as serventias *sub judice*, mesmo que pendentes de pronunciamento judicial definitivo. O cumprimento integral de orientação do CNJ reforça o papel de tal órgão na fiscalização da higidez das instituições do Poder Judiciário.

Além disso, a supressão dessas vagas seria injustificada, traduzindo-se em manifesto prejuízo para os candidatos, que se veem alijados da possibilidade de concorrer a esses locais.

A administração do Tribunal de Justiça deve incluir no edital do concurso público a advertência acerca da condição *sub judice* da delegação ofertada no certame.

Nessa hipótese, o candidato que optar por essas vagas o fará por sua conta e risco, sem direito a qualquer reclamação posterior, caso o resultado da ação judicial correspondente frustre sua escolha e seu exercício.

A entrega da serventia ao aprovado no certame depende do encerramento de todos os processos alusivos à referida delegação.

O princípio da razoabilidade recomenda que não se dê provimento a serventia cuja vacância esteja sendo contestada judicialmente, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão.

- 1 Resolução CNJ 80, de 9 de junho de 2009: “Declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público.”

Direito Administrativo

- » Agentes públicos
 - » Concurso público
 - » Serventias extrajudiciais

MS 29.093 ED-ED-AgR

MS 29.101 ED-ED-AgR

MS 29.128 ED-ED-AgR

MS 29.129 ED-ED-AgR

MS 29.130 ED-ED-AgR

MS 29.146 ED-ED-AgR

MS 29.186 ED-ED-AgR

MS 29.189 ED-ED-AgR

rel. min. Teori Zavascki

2ª Turma

DJE de 4-8-2015

Informativo STF 781

A partir da promulgação da Constituição Federal (CF) (5-10-1988), o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em caso de remoção, observado, nessa última hipótese, o disposto no art. 16 da Lei 8.935/1994, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002.

O art. 236, *caput* e o seu § 3º, da CF são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, antes da Lei 8.935/1994.

Nesse sentido, normas estaduais editadas anteriormente à CF de 1988 que admitem a remoção, na atividade notarial e de registro, independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição. Por isso, não foram recepcionadas pela Lei Maior.

Por outro lado, o prazo decadencial de cinco anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999¹, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236.²

Situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público, não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações da CF.³

Por fim, não é cabível a desistência de mandado de segurança, nas hipóteses em que se discute a exigibilidade de concurso público para delegação de serventias extrajudiciais, quando já houver decisão de mérito, objeto de sucessivos recursos, e as de-

sistências tiverem por finalidade secundária levar a matéria em ação ordinária perante a Justiça comum, a fim de perpetuar a controvérsia.⁴

- 1 Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”
- 2 Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, rel. min. Dias Toffoli, P.
- 3 MS 28.279, rel. min. Ellen Gracie, P.
- 4 Sobre a limitação do teto, prevista no art. 37, XI, da CF/1988, a quem detém interinamente a serventia extrajudicial: MS 30.180 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T; MS 28.815 MC-AgR, rel. min. Luiz Fux, decisão monocrática; e RE 810.590, rel. min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática.

Não se aplica o Estatuto do Idoso¹ como critério de desempate em concurso público de remoção para outorga de delegação notarial e de registro, quando a lei estadual² específica reguladora do certame fixa as regras em caso de empate.

A Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) cuida apenas da admissão em concurso público de maneira geral. Assim, no caso do concurso de remoção, a referida norma não deve ser seguida devido à existência de lei especial (*lex specialis derogat legi generali*).

Cabe aos Estados-membros editar as normas e fixar os critérios de concurso de remoção para outorga de serventia extrajudicial [Constituição Federal (CF), art. 25, § 1º³], como já reconhecido pela legislação federal sobre o tema (Lei 8.935/1994⁴).

A competência da União para legislar sobre registros públicos (CF, art. 22, XXV) alcança apenas as atividades-fim dos notários e registradores. Isso corresponde ao poder de “criar e extinguir requisitos de validade dos atos jurídicos de criação, preservação, modificação, transferência e extinção de direitos e obrigações”⁵.

Tendo em vista a ordem estabelecida nos critérios de desempate pela lei estadual, somente se poderia privilegiar o mais idoso quando os candidatos estivessem empatados também quanto ao tempo de serviço público.

Deve-se considerar ainda que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal⁶, o tempo anterior na titularidade do serviço para o qual se realiza o concurso público não pode ser utilizado como critério de desempate por violar o princípio da razoabilidade.

¹ Lei 10.741/2003: “Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.”

² No caso, Lei 14.594/2004 do Estado do Paraná: “Art. 11. Havendo empate entre os candidatos, a precedência na classificação será decidida de acordo com os seguintes critérios, sucessivamente: I –

o mais antigo na titularidade de serviço notarial ou de registro; II – aquele que contar com maior tempo de serviço público; III – o mais idoso.”

- 3 CF/1988: “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”
- 4 Lei 8.935/1994: “Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção.”
- 5 ADI 2.415, rel. min. Ayres Britto, P.
- 6 ADI 3.522, rel. min. Marco Aurélio, P.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Serventias extrajudiciais

Incumbe ao presidente do Tribunal de Justiça da respectiva unidade da Federação declarar a vacância de serventia extrajudicial.

De acordo com interpretação sistemática dos arts. 14¹, 15² e 39, § 2º³, da Lei 8.935/1994, se o legislador ordinário previu a necessidade de anterior aprovação em concurso público de provas e títulos a cargo do Poder Judiciário para a delegação do exercício das atividades notariais, é de se inferir que a declaração de vacância dessa serventia incumbe ao próprio Judiciário.

É nula de pleno direito a investidura para o exercício dos serviços notariais e de registro que viola a regra do concurso público [Constituição Federal (CF), art. 37, II⁴], após o advento da Constituição vigente.

Consequentemente, não há de se cogitar da instauração de processo administrativo, a fim de oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório àqueles que se encontrem naquela situação, bem como não há de se considerar o lapso temporal em que exercidas as funções, pois o titular da serventia extrajudicial investido irregularmente tem completa ciência da inconstitucionalidade do ato de habilitação.

1 Lei 8.935/1994: “Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: I – habilitação em concurso público de provas e títulos; II – nacionalidade brasileira; III – capacidade civil; IV – quitação com as obrigações eleitorais e militares; V – diploma de bacharel em direito; VI – verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.”

2 Lei 8.935/1994: “Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. § 1º O concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os critérios de desempate. § 2º Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro.”

- 3 Lei 8.935/1994: “Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por: (...) § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.”
- 4 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Serventias extrajudiciais

Tendo em vista que os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas, inexistente direito adquirido à efetivação na titularidade de cartório quando a vacância do cargo ocorrer na vigência da Constituição Federal (CF) de 1988¹.

O art. 236, § 3º, da CF – o qual estatui, entre outras disposições, que “o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos” – é norma constitucional autoaplicável. Nesse sentido, é descabida a tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994, que regulamenta o art. 236 da CF, a norma teria conquistado plena eficácia.

O provimento de serventia extrajudicial sem a observância de concurso público não enseja o transcurso do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

Tal prazo não corre nas hipóteses em que o exercício do direito se fundamenta em inconstitucionalidade flagrante porquanto configurada a má-fé.

¹ Entendimento aplicado também no RE 355.856, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, 1ª T; e no MS 26.860, rel. min. Luiz Fux, P.

É possível a aplicação excepcional da teoria do fato consumado, pela consolidação de uma situação fática em face do decurso do tempo, quando há a concessão de aposentadoria voluntária pela Administração Pública ao servidor que tomou posse e entrou em exercício em cargo público em decorrência de decisão judicial tomada à base de cognição não exauriente.¹

O princípio da segurança jurídica, em sua perspectiva subjetiva, protege a confiança legítima, preserva fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação do direito, bem como resguarda efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se sobretudo a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais.²

A aplicação do princípio da proteção da confiança, portanto, pressupõe a adoção de atos contraditórios pelo Estado que frustrem legítimas expectativas nutridas por indivíduos de boa-fé. Naturalmente, tais expectativas podem ser frustradas não apenas por decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões judiciais dessa natureza.

Em casos de elevado grau de estabilidade da relação jurídica, em especial pela passagem de longo intervalo de tempo, o princípio da proteção da confiança legítima incide com maior intensidade.³

Assim, apesar de, em regra, a posse e o exercício em cargo público em razão de decisão judicial tomada à base de cognição não exauriente não produzirem fato consumado – tal qual assentado no RE 608.482 RG⁴ (rel. min. Teori Zavascki, P, Tema 476) –, a marca da excepcionalidade dos casos concretos autoriza a distinção (*distinguish*⁵).

Com efeito, o *leading case* não abriga a hipótese em que o afastamento da teoria do fato consumado do caso concreto retira a aposentadoria do servidor mantido no cargo por força de decisão precária em processos cuja duração não observa o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (CF)⁶, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

- 1 “Efetivamente, o caso é de todo peculiar. Como destaquei na sessão presencial do dia 14-8-2018, a agravante manteve-se no cargo de auditora fiscal do trabalho ano após ano com provimentos liminares e cautelares cassados e posteriormente renovados nas instâncias *a quo*, e, após 21 anos no exercício desse cargo, dos quais nove deles por conta de liminar obtida no Superior Tribunal de Justiça, mais os acréscimos do tempo pretérito em outras atividades, a agravante acabou se aposentando voluntariamente, sem que o mérito tivesse sido analisado.” (Trecho do voto do rel. min. Alexandre de Moraes no presente julgamento.)
- 2 Fundamentos extraídos do voto do min. Roberto Barroso no presente julgamento.
- 3 Idem.
- 4 “Destaque-se a zelosa observação presente no voto do saudoso ministro Teori Zavascki no indigitado *leading case*, pontuando haver situações estritamente excepcionais sobre as quais esse importante instituto jurídico não se aplica: ‘(...) Por isso mesmo, eventual superveniente constatação da ilegitimidade desse *status* ou dessa vantagem caracteriza, certamente, comprometimento da boa-fé ou da confiança legítima provocada pelo primitivo ato da administração, o que pode autorizar, ainda que em nome do fato consumado, a manutenção do *status quo*, ou, pelo menos, a dispensa de restituição de valores. Isso ocorre, todavia, em casos restritos, marcados pela excepcionalidade’.” (Trecho do voto do rel. min. Alexandre de Moraes no presente julgamento.)
- 5 “A aplicação da sistemática dos precedentes exige que o caso julgado seja o mais próximo possível da hipótese concreta. Em artigo acadêmico no qual tive a oportunidade de enfrentar o tema dos precedentes no Direito Brasileiro, defendi que, nessa análise, devem ser levados em consideração quatro elementos essenciais: (i) os fatos relevantes de cada qual; (ii) os valores e normas que incidem sobre cada conjunto de fatos; (iii) a questão de direito que suscitam; e (iv) os fundamentos que justificaram a decisão do precedente e sua adequação para orientar a decisão do novo caso.” (BARROSO, Luís Roberto; MELO, Patrícia Perrone Campos. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos precedentes no direito brasileiro. *Revista da AGU*, ano 15, n. 3, jul./set., 2017, apud min. Roberto Barroso em seu voto, no presente julgamento.)
- 6 CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Teoria do fato consumado

Não se aplica a teoria do fato consumado ao candidato que toma posse em cargo público por força de decisão judicial precária.

A execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer. Tal circunstância evidencia sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.¹

Assim, o candidato que toma posse em cargo público por força de decisão judicial precária assume o risco de posterior reforma desse julgado, que, em razão do efeito retroativo, inviabiliza a aplicação da teoria do fato consumado.

Ademais, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado em concurso, uma vez que tomou posse apenas em decorrência de provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

É igualmente incabível, em tais casos, invocar o princípio da segurança jurídica, o da proteção da confiança legítima ou o da boa-fé.

¹ RE 608.482, rel. min. Teori Zavascki, P.

- » Agentes públicos
- » Concurso público
- » Teoria do fato consumado – Repercussão Geral

É incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tenha tomado posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais – fundadas em títulos de natureza precária e revogável – dá-se, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, e a sua revogação acarreta efeito *ex tunc*. Essas circunstâncias evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

É igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica, o da proteção da confiança legítima ou o da boa-fé, muito embora, excepcionalmente, esses princípios sejam aplicáveis quando se constate que, por ato de iniciativa da própria Administração, o servidor foi alçado a determinada condição jurídica de modo que essas peculiares circunstâncias provocassem em seu íntimo justificável convicção de que se trataria de um *status* ou de uma vantagem legítima, o que poderia autorizar, ainda que em nome do “fato consumado”, a manutenção do *status quo*, ou, pelo menos, a dispensa de restituição de valores.

- » Agentes públicos
- » Contratação temporária
- » Competência judicial

A Justiça comum é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo entre o poder público e servidores temporários.¹

As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa², e o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas instauradas entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.³

Ademais, nem a alegação de desvirtuamento do vínculo nem a existência de pedidos fundados na Consolidação das Leis do Trabalho ou no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço descaracterizam a competência da Justiça comum.

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para a causa, são nulos todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, consoante disposto no art. 113 do Código de Processo Civil/1973⁴.

¹ “Ementa: Constitucional. Reclamação. Medida liminar na ADI 3.357. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI 3.395 MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense 2.607/2000, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado.” (Rcl 5.381, rel. min. Ayres Britto, P.)

² Rcl 4.872, red. p/ o ac. min. Menezes Direito, P.

³ “Agravo regimental em reclamação. Ofensa à decisão proferida na ADI 3.395/DF. Contratação temporária para o exercício de função pública. Regime jurídico-administrativo. Incompetência da Justiça do Trabalho para examinar eventual nulidade da contratação. Competência da Justiça comum estadual. 1. A Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar causas que envolvam o poder público e servidores a ele vinculados, mesmo que por contrato temporário com prazo excedido,

por se tratar de relação jurídico-administrativa. 2. Ainda que possa ter ocorrido desvirtuamento da contratação temporária para o exercício de função pública, não cabe à Justiça do Trabalho analisar a nulidade desse contrato. 3. Existência de precedentes desta Corte nesse sentido.” (Rcl 7.234, rel. min. Ellen Gracie, P.)

4 Rcl 7.028 AgR, rel. min. Ellen Gracie, P.

- » Agentes públicos
- » Contratação temporária
- » Regramento jurídico

São inconstitucionais a autorização legislativa genérica para contratação temporária e a permissão de prorrogação indefinida do prazo de contratações temporárias.

A Constituição Federal (CF) é intransigente em relação ao princípio do concurso público como requisito para o provimento de cargos públicos (CF, art. 37, II¹). A exceção prevista no art. 37, IX², da CF deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao legislador infraconstitucional a observância dos requisitos da reserva legal, da atualidade do excepcional interesse público justificador da contratação temporária e da temporariedade e precariedade dos vínculos contratuais.³

Diante disso, foi declarado inconstitucional o art. 264, VI e § 1º, parte final⁴, da Lei Complementar (LC) 4/1990 do Estado de Mato Grosso, com a redação conferida pela LC 12/1992, com efeitos *ex nunc*, preservados os contratos em vigor que tenham sido celebrados exclusivamente com fundamento nos referidos dispositivos, por um prazo máximo de até doze meses da publicação da ata de julgamento (31-3-2017).

1 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

2 CF/1988: “Art. 37. (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

3 RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, P, RG, Tema 612.

4 LC 4/1990 do Estado de Mato Grosso: “Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) VI – atender a outras situações motivadamente de urgência. § 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público.”

É compatível com a Constituição Federal (CF) a previsão legal que exija o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.

Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção, ainda que simplificada, observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, *caput*, da CF¹. São eles que justificam a limitação constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/1993.^{2 e 3}

Nesse contexto, o art. 9º, III, da Lei 8.745/1993, que dispõe sobre contratação temporária, evita que função temporária, cuja característica é a transitoriedade, seja transformada em algo ordinário. Dessa forma, o dispositivo legal é necessário e adequado para preservar o princípio da impessoalidade do concurso público.

“É bem verdade que a impossibilidade de recontração dos mesmos profissionais não assegura a observância do art. 37, IX, da CF⁴, pois o preenchimento desses postos de trabalho por meio de contratos temporários, ainda que com pessoas antes não contratadas pela Administração, também frustra o ideal de temporalidade e transitoriedade desse tipo de contratação.”⁵

Dessa forma, “a descontinuidade do vínculo temporário provocada pela vedação do art. 9º, III, da Lei 8.745/1993 evita que se instale na Administração interesse contrário ao provimento efetivo de cargos públicos mediante concurso e retira o administrador público da situação cômoda de reutilizar a mesma mão de obra já recrutada por processo seletivo simplificado”⁶.

Assim, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

- 1 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:”
- 2 Lei 8.745/1993: “Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: (...) III – ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2º desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º desta Lei.”
- 3 ADI 3.210, rel. min. Carlos Velloso, P; e ADI 890, rel. min. Maurício Corrêa, P.
- 4 CF/1988: “Art. 37. (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”
- 5 Trecho do voto do min. Alexandre de Moraes no presente julgamento.
- 6 Idem.

São inconstitucionais dispositivos de lei estadual de iniciativa parlamentar¹ que asseguraram a permanência dos servidores públicos admitidos em caráter temporário sem a prévia aprovação em concurso público.

Os arts. 1º e 2º da Lei 6.697/1994 do Estado do Rio Grande do Norte revelam flagrante vício formal. A Assembleia Legislativa usurpou a prerrogativa constitucionalmente conferida ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos², nos termos do art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal (CF)³.

Essa hipótese configura, ainda, burla ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II⁴), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente sem o prévio certame público.⁵

Ademais, o fato de a lei impugnada abranger temporalmente os servidores cuja admissão operou-se em período pré-constitucional, não elide, quanto a esses, a declaração de inconstitucionalidade, em razão da flagrante violação do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)⁶, que concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos.

Diante disso, foi declarada a inconstitucionalidade dos arts. 1º⁷ e 2º⁸ da Lei 6.697/1994 do Estado do Rio Grande do Norte. A norma assegurava a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN) admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993, sem a prévia aprovação em concurso público, e tornava sem efeitos os atos de direção da Universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal.

Todavia, ante a vigência prolongada da referida lei estadual e a necessidade de se resguardar a segurança jurídica⁹, foi aplicada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999¹⁰, de modo a dar efeitos prospectivos à decisão, a qual somente produzirá efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento. Esse período foi considerado hábil para a

realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na URRN.

Por fim, foram ressalvados dos efeitos dessa decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.¹¹

- 1 Lei 6.697/1994 do Estado do Rio Grande do Norte.
- 2 ADI 4.433 MC, rel. min. Ellen Gracie, P; ADI 4.154, rel. min. Ricardo Lewandowski, P; ADI 2.904, rel. min. Menezes Direito, P; ADI 2.113, rel. min. Cármen Lúcia, P; ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, P; e ADI 3.167, rel. min. Eros Grau, P.
- 3 CF/1988: “Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: (...) II – disponham sobre: (...) c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”
- 4 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”
- 5 ADI 2.687, rel. min. Nelson Jobim, P; ADI 3.609, rel. min. Dias Toffoli, P; e ADI 4.876, rel. min. Dias Toffoli, P.
- 6 ADCT: “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”
- 7 Lei 6.697/1994 do Estado do Rio Grande do Norte: “Art. 1º Aos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, admitidos entre o termo inicial da vigência da Lei n. 5.546, de 8 de janeiro de 1987, que a incorporou à Administração Pública Estadual, e o da Portaria n. 874, de 17 de junho de 1993, do Ministro da Educação e do Desporto, que a reconheceu, e originalmente incluídos no Quadro Suplementar, integrante da estrutura geral de pessoal daquela instituição de ensino superior, é assegurado permanecerem no referido Quadro.”
- 8 Lei 6.697/1994 do Estado do Rio Grande do Norte: “Art. 2º São declarados de nenhum efeito em relação aos servidores na situação de que trata o artigo anterior, os atos de direção da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte que, de qualquer forma, importem sua exclusão do Quadro a que se refere a presente Lei.”

- 9 ADI 3.609, rel. min. Dias Toffoli, P; ADI 3.819, rel. min. Eros Grau, P; ADI 4.125, rel. min. Cármen Lúcia, P; e ADI 4.876, rel. min. Dias Toffoli, P.
- 10 Lei 9.868/1999: “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”
- 11 ADI 4.876, rel. min. Dias Toffoli, P.

As hipóteses genéricas de contratação temporária de profissionais de magistério previstas em lei complementar estadual são inconstitucionais.

O art. 37, IX, da Constituição Federal (CF)¹ exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejem contratações sem concurso.

Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração, o legislador fica sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.²

No caso em tela, a Lei Complementar (LC) 22/2000 do Estado do Ceará autorizou a contratação temporária de professores para as situações de “a) licença para tratamento de saúde; b) licença-gestante; c) licença por motivo de doença de pessoa da família; d) licença para trato de interesses particulares; e) cursos de capacitação; e f) e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária”; e para “fins de implementação de projetos educacionais, com vistas à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense” (art. 3º, parágrafo único). As hipóteses descritas entre as alíneas *a* e indicam ocorrências alheias ao controle da Administração Pública cuja superveniência pode resultar em desaparelhamento transitório do corpo docente, permitindo reconhecer que a emergencialidade está suficientemente demonstrada.

O mesmo não se pode dizer, contudo, da hipótese prevista na alínea *f* do art. 3º da lei atacada, que padece de generalidade manifesta, e cuja declaração de inconstitucionalidade se impõe.

Os projetos educacionais previstos no parágrafo único do art. 3º da LC 22/2000 do Estado do Ceará correspondem a objetivos corriqueiros das políticas públicas de educação praticadas no território nacional.

Diante da continuada imprescindibilidade de ações desse tipo, não podem elas ficar à mercê de projetos de governo casuísticos, implementados por meio de contratos

episódicos, sobretudo quando a lei não tratou de designar qualquer contingência especial a ser atendida.

Por essas razões, foi declarada a inconstitucionalidade da alínea *f* e do parágrafo único do art. 3º da LC 22/2000 do Estado do Ceará, com efeitos modulados para surtir um ano após a data da publicação da ata de julgamento.

- 1 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”
- 2 “(...) cabem alguns cuidados evidentes, tanto no reconhecimento do que seja situação excepcional ensejadora do contrato a ser feito, quanto na caracterização de seus requisitos, sem o que estar-se-ia desconhecendo o sentido da regra interpretada e favorecendo a reintrodução de ‘interinos’, em dissonância com o preceito em causa. Desde logo, não se coadunaria com a sua índole contratar pessoal senão para evitar o declínio do serviço ou para restaurar-lhe o padrão indispensável seriamente deteriorado pela falta de servidores. Vale dizer: tais contratos não podem ser feitos simplesmente em vista de aprimorar o que já existia e tenha qualidade aceitável, compatível com o nível corrente a que está afeita a coletividade a que se destina. Em segundo lugar, cumpre que tal contratação seja indispensável; vale dizer, indubitavelmente não haja meios de supri-la com remanejamento de pessoal ou redobrado esforço dos servidores já existentes. Em terceiro lugar, sempre na mesma linha de raciocínio, não pode ser efetuada para instalação ou realização de serviços novos, salvo, é óbvio, quando a irrupção de situações emergentes os exigiria e já agora por motivos indeclináveis, como os de evitar a periclitacão da ordem, segurança ou saúde.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Regime constitucional dos servidores da administração direta e indireta*. 2. ed. São Paulo: RT, 1991. p. 83.)

É inconstitucional lei que, a pretexto de valer-se do permissivo do art. 37, IX, da Constituição Federal (CF)¹, efetive contratação temporária para atividade previsível, permanente e ordinária ou, ainda, que não estabeleça prazo determinado e não especifique a contingência fática que evidencie a situação emergencial.

A contratação temporária reclama os seguintes requisitos para sua validade:

- i) os casos excepcionais devem estar previstos em lei;
- ii) o prazo de contratação precisa ser predeterminado;
- iii) a necessidade deve ser temporária;
- iv) o interesse público deve ser excepcional;
- v) a necessidade de contratação há de ser indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, sobretudo na ausência de uma necessidade temporária.

Em vista disso, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 17.822/2012 do Estado de Goiás, que – ao instituir o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (SIMVE) na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar goiano – criou uma classe de policiais temporários, cujos integrantes, sem o indispensável concurso público de provas e títulos, passaram a ocupar, após seleção interna, função de natureza policial militar.²

Ademais, afronta o Texto Maior lei estadual que regule fora das peculiaridades locais e de sua competência suplementar. Isso atenta contra as normas gerais de competência da União^{3 e 4} e substitui os critérios mínimos estabelecidos pela norma competente, em manifesta usurpação de competência (CF, arts. 22, XXI, e 24, § 2º).

1 CF/1988: “Art. 37. (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

2 Na espécie, a lei impugnada, a pretexto de ter fundamento de validade na Lei 4.735/1964 (Lei do Serviço Militar), instituiu uma classe de policiais temporários, cujos integrantes, após serem aprovados em seleção e em curso de formação, passariam a ocupar cargo de natureza policial militar. Esses

temporários seriam remunerados por subsídio, estariam sujeitos à legislação militar e às normas específicas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estaduais e teriam o direito de usar os uniformes, insígnias e emblemas utilizados pela corporação, com a designação “SV”. Ao possibilitar que voluntários tivessem função de policiamento preventivo e repressivo, a lei objetivou criar policiais temporários, disfarçados sob a classificação de voluntários, para a execução de atividades militares, em detrimento da exigência constitucional de concurso público. O objetivo seria cortar gastos relacionados com a segurança pública.

- 3 Cf. Lei 8.745/1993: “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.”
- 4 Cf. Lei 10.029/2000: “Estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e dá outras providências.”

É inconstitucional lei que institua hipóteses abrangentes e genéricas de contratações de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e não especifique a contingência fática que evidencie situação de emergência.¹

A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, entre eles os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Assim, a prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público [Constituição Federal (CF), art. 37, II²] impõe que as regras limitadoras do cumprimento desse dispositivo sejam interpretadas restritivamente.

Desse modo, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: **a)** os casos excepcionais estejam previstos em lei; **b)** o prazo de contratação seja predeterminado; **c)** a necessidade seja temporária; **d)** o interesse público seja excepcional; **e)** a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

¹ Entendimento aplicado também no RE 527.109, rel. min. Cármen Lúcia, P.

² CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

A Justiça comum federal ou estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração Direta, das autarquias e das fundações de direito público.

A natureza das atividades efetivamente desempenhadas pela categoria profissional é o elemento preponderante para a definição do regramento aplicável em caso de greve dessa categoria, mesmo na hipótese em que o vínculo com a Administração é regulado pelo Direito do Trabalho.

A essencialidade do serviço público prestado e a necessidade de garantias para a sua continuidade não se relacionam diretamente com a natureza do vínculo existente entre servidores e poder público. A análise do prejuízo decorrente da paralisação das atividades realizadas pelos servidores públicos não será influenciada pelo fato de serem servidores celetistas ou estatutários. Na verdade, a própria extensão das regras do regime celetista aos servidores públicos (estatutários) demonstra que, para efeito de greve, são situações intercambiáveis.

Dessa forma, reconhecida a essencialidade das atividades desempenhadas pelos servidores públicos, não há por que excetuá-los da regra de competência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no MI 670^{1 e 2}, mesmo em se tratando de servidores contratados pelo Estado sob o regime celetista.

1 MI 670, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P.

2 “6. Definição dos parâmetros de competência constitucional para apreciação do tema no âmbito da Justiça federal e da Justiça estadual até a edição da legislação específica pertinente, nos termos do art. 37, VII, da CF. Fixação do prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. Mandado de injunção deferido para determinar a aplicação das Leis n. 7.701/1988 e 7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei n. 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de ‘serviços ou atividades essenciais’ (Lei n. 7.783/1989, arts. 9º a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do

mandado de injunção, aplicação da Lei n. 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da Federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2º, I, *a*, da Lei n. 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6º da Lei n. 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da Federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6º da Lei n. 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7º da Lei n. 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7º da Lei n. 7.783/1989, *in fine*). 6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paretista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis n. 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.” (MI 670, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P.)

A Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público.

No julgamento dos MI 670, 708 e 712, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, até a edição da lei regulamentadora do direito de greve, previsto no art. 37, VII, da Constituição Federal (CF)¹, as Leis 7.701/1988 e 7.783/1989 poderiam ser aplicadas provisoriamente para possibilitar o exercício desse direito pelos servidores públicos, em especial os arts. 1º² ao 9º³, 14⁴, 15⁵ e 17⁶ da Lei 7.783/1989.

Entretanto, esse direito não é absoluto. Conquanto a paralisação seja possível, porque é um direito constitucional, ela tem consequências. O STF já assentou o entendimento de que o desconto dos dias de paralisação é ônus inerente à greve, assim como a paralisação parcial dos serviços públicos imposta à sociedade é consequência natural do movimento.

A aplicação do art. 7º da Lei 7.783/1989⁷ induz ao entendimento de que, em princípio, a deflagração de greve corresponde à suspensão do contrato de trabalho, na qual não há falar em prestação de serviços, tampouco no pagamento de sua contraprestação.

Os grevistas assumem os riscos da empreitada, pois, do contrário, estar-se-ia diante de caso de enriquecimento sem causa, a violar, inclusive, o princípio da indisponibilidade dos bens e do interesse público.

Cabe esclarecer que a ausência de regulamentação do direito de greve não transforma os dias de paralisação do movimento grevista em faltas injustificadas, razão pela qual esse desconto não tem o efeito disciplinar punitivo.^{8 a 10}

Por fim, o desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da Administração ou o empregador tenha contribuído,

mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos.

- 1 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;”
- 2 Lei 7.783/1989: “Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo único. O direito de greve será exercido na forma estabelecida nesta Lei.”
- 3 Lei 7.783/1989: “Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.”
- 4 Lei 7.783/1989: “Art. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que: I – tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição; II – seja motivada pela superveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho.”
- 5 Lei 7.783/1989: “Art. 15. A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da greve, será apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. Parágrafo único. Deverá o Ministério Público, de ofício, requisitar a abertura do competente inquérito e oferecer denúncia quando houver indício da prática de delito.”
- 6 Lei 7.783/1989: “Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (*lockout*). Parágrafo único. A prática referida no *caput* assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período de paralisação.”
- 7 Lei 7.783/1989: “Art. 7º Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14.”
- 8 ADI 3.235, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P.
- 9 RE 226.966, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, 1ª T.
- 10 RE 222.532, rel. min. Sepúlveda Pertence, 1ª T.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.

O dever de motivação imposto à ECT cinge-se à exposição das razões pelas quais se pratica o ato de dispensa, de modo a permitir que haja controle sobre ele, seja por parte do empregado afetado, seja pelos órgãos de fiscalização externa da Administração.

Basta que a ECT indique, por escrito, os motivos que a levaram (i) a dispensar o empregado sem justa causa (*e.g.*, prejuízos operacionais e necessidade de corte de gastos) e, (ii) quando for o caso, a escolher o empregado atingido por sua política interna de redução do quadro funcional (*e.g.*, mais moderno ou menos produtivo).

A ECT não precisa enquadrar seus motivos em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. Ela permanece, tal como os agentes privados, em condições de dispensar seus funcionários sem justa causa, assumidas as consequências trabalhistas atreladas a tanto. O que dela se exige é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório.

Não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório ato administrativo de comandante militar que determine a remessa obrigatória ao Superior Tribunal Militar (STM) do resultado do julgamento realizado pelo Conselho de Justificação.

No âmbito da Justiça Militar, o Conselho de Justificação é o órgão destinado a avaliar, por meio de processo especial, a incapacidade de oficial das Forças Armadas para permanecer na ativa. Por sua vez, compete ao STM julgar o processo administrativo, consoante o disposto nos arts. 13, V, *a*¹, e 14² da Lei 5.836/1972, e observado o art. 15³ da mesma lei.

Além disso, não há previsão legal de recurso contra o referido despacho do comandante, que possui caráter meramente homologatório.

- 1 Lei 5.836/1972: “Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina: (...) V – a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar: a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do art. 2º;”
- 2 Lei 5.836/1972: “Art. 14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar.”
- 3 Lei 5.836/1972: “Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos Ministros, que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar por escrito sobre a decisão do Conselho de Justificação.”

Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em PAD seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada.

Essa situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 18 e 20 da Lei 9.784/1999¹, os quais estabelecem os casos de impedimento ou de suspeição para os integrantes de comissão disciplinar.

Não há falar, assim, em nulidade do PAD em decorrência do impedimento ou suspeição de seus membros, especialmente se o impetrante não demonstrar de que forma os membros teriam agido de forma tendenciosa.²

Não é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações finais após o relatório final de PAD.

Inexiste previsão na Lei 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante.

Além disso, há necessidade de demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não resta demonstrado quando o recorrente exerceu o seu direito de defesa, tendo prestado declarações, juntado documentos e defesa escrita.³

O acusado em PAD não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos.

A teor do art. 156, 1º, da Lei 8.112/1990⁴, “o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos”.

Admite-se o uso de prova emprestada em PAD, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal.

“Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova.”^{5, 6 e 7}

A ausência de transcrição integral de dados obtidos por meio de interceptação telefônica não gera a nulidade da portaria de demissão do servidor.

Mesmo em matéria penal, não é necessária a degravação integral das escutas, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia.⁸

- 1 Lei 9.784/1999: “Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I – tenha interesse direto ou indireto na matéria; II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. (...) Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.”
- 2 RMS 30.881, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T.
- 3 MS 23.268, rel. min. Ellen Gracie, P.
- 4 Lei 8.112/1990: “Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. § 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. § 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.”
- 5 Trecho do voto do rel. min. Cezar Peluso no Inq 2.424 QO-segunda, P.
- 6 “Afastado ou prevenido, nas circunstâncias de cada caso, o risco de fraude à Constituição e à lei, nada obsta ao reconhecimento da validade e da eficácia do uso, em processo não penal, da prova lícitamente colhida na área criminal, até porque, com a colheita legítima, já se rompeu a intimidade que o ordenamento, na forma da lei e da Constituição, tende a resguardar em termos relativos.” (Trecho do voto do rel. min. Cezar Peluso no Inq 2.424 QO-segunda, P.)
- 7 “Mas é possível que, em processo civil, se pretende aproveitar prova emprestada, derivada de interceptação telefônica lícita, colhida em processo penal desenvolvido entre as mesmas partes. (...) Poderá, em casos como esse, ter eficácia a prova emprestada, embora inadmissível sua obtenção no processo

não penal? As opiniões dividem-se, mas, de nossa parte, pensamos ser possível o transporte de prova. O valor constitucionalmente protegido pela vedação das interceptações telefônicas é a intimidade. Rompida esta, lícitamente, em face do permissivo constitucional, nada mais resta a preservar. Seria uma demasia negar-se a recepção da prova assim obtida, sob a alegação de que estaria obliquamente vulnerado o comando constitucional. Ainda aqui, mais uma vez, deve prevalecer a lógica do razoável. (...) Nessa linha de interpretação, cuidados especiais devem ser tomados para evitar que o processo penal sirva exclusivamente como meio oblíquo para legitimar a prova no processo civil. Se o juiz perceber que esse foi o único objetivo da ação penal, não deverá admitir a prova na causa cível. (GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. *As nulidades no processo penal*. 9. ed. São Paulo: RT, 2006. p. 119-120).” (Trecho do voto do rel. min. Cezar Peluso no Inq 2.424 QO-segunda, P.)

- 8 AI 685.878 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T; e ARE 765.440 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T.

- » Agentes públicos
 - » Processo administrativo disciplinar (PAD)
 - » Inquérito

Não há nulidade – por suposto cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório – em PAD do qual resulte demissão de servidor público que, apesar de ter sido defendido por defensor dativo, tenha deixado de praticar os atos de sua defesa, embora regularmente intimado, em razão de suposta enfermidade, não comprovada.

O exame de sanidade mental, nos termos do art. 160 da Lei 8.112/1990¹, só deve ser realizado quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, o que pode ser afastado por laudo de junta médica oficial.

¹ Lei 8.112/1990: “Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.”

Não há vício na instalação de segunda comissão disciplinar, após a primeira ter concluído pela insuficiência de provas, quando houver dúvida razoável a amparar a continuidade das diligências investigativas.

Conforme disposto no art. 168 da Lei 8.112/1990¹, a autoridade julgadora do PAD não se vincula ao relatório da comissão processante.

Assim, também não há que falar em violação ao art. 169 do aludido diploma legal². A autoridade julgadora pode baixar os autos do PAD em diligência a fim de fazer prevalecer o princípio da verdade material.

Caso seja conveniente, o órgão julgador tem discricionariedade para designar novo colegiado. Para isso, deve persistir dúvida razoável, a partir do relatório da primeira conclusão, que justifique a continuidade das diligências investigativas, a fim de coletar outras provas e esclarecer suspeitas.

Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente nulo per se o PAD pelo decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão.³

O art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 dispõe expressamente que o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Logo, não há nulidade pelo descumprimento do prazo constante do art. 167 da Lei 8.112/1990⁴.

A desproporcionalidade da evolução patrimonial implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito.

Na esfera correccional, a variação patrimonial a descoberto é indício de comportamento ímprobo do servidor. Conforme suposição da Lei de Improbidade Administrativa, a renda não justificada do servidor resulta de atos de improbidade aptos a fundamentar punição.

Nos termos do Decreto 5.483, de 30-6-2005, a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio de sindicância patrimonial. O objetivo da investigação é provar a desproporcionalidade desse enriquecimento, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei 8.429/1992.

Nesse caso, há inversão do ônus da prova e cabe ao agente público o dever de demonstrar a origem lícita desses recursos.

Não cabe mandado de segurança para a discussão da proporcionalidade da pena nos casos de demissão por ato doloso de improbidade administrativa.

Por se tratar de improbidade administrativa por ato de enriquecimento ilícito⁵, a análise da proporcionalidade da pena exige reapreciação de aspectos fáticos, vedada na via estreita do *writ*⁶.

Entretanto, admitem-se exceções quando, diante das peculiaridades do caso concreto, a demissão estiver fundada na prática de ato de improbidade de natureza culposa, sem a imputação de locupletamento ilícito do servidor.⁷

1 Lei 8.112/1990: “Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.”

2 Lei 8.112/1990: “Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.”

3 MS 21.494, red. p/ o ac. min. Francisco Rezek, P.

4 Lei 8.112/1990: “Art. 167. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.”

5 Lei 8.429/1992: “Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente: (...) VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;”

6 RMS 31.471, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2ª T; e RMS 30.455, rel. min. Luiz Fux, 1ª T.

7 RMS 24.129, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T.

- » Agentes públicos
 - » Processo administrativo disciplinar (PAD)
 - » Julgamento

É inconstitucional o art. 170 da Lei 8.112/1990, o qual determina o registro do fato investigado em procedimento administrativo disciplinar nos assentamentos individuais do servidor mesmo quando extinta a punibilidade pela prescrição.

A norma viola o princípio da presunção de inocência. Com efeito, o *status* de inocência deixa de ser presumido somente após decisão definitiva na seara administrativa. Logo, não é possível que qualquer consequência desabonadora da conduta do servidor decorra tão só da instauração de procedimento apuratório ou de decisão que reconheça a incidência da prescrição antes de deliberação definitiva de culpabilidade.

- » Agentes públicos
 - » Processo administrativo disciplinar (PAD)
 - » Julgamento

Suspensão por sessenta dias aplicada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal a servidora dos quadros da respectiva Corte padece de vício de nulidade.

Na hipótese, há inobservância do princípio da legalidade e do direito ao duplo grau administrativo consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O inciso I do art. 141 da Lei 8.112/1990 determina que apenas a demissão de servidores públicos será imposta pelo presidente dos tribunais federais, e o inciso II dispõe que a suspensão superior a trinta dias será aplicada pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior.

- » Agentes públicos
- » Regime próprio de previdência social
- » Abono de permanência

A ocupação de novo cargo da magistratura dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício.

“(...) a jurisdição, enquanto manifestação da unidade do poder soberano do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível, é doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo senão por metáforas e metonímias, ‘Judiciários estaduais’ ao lado de um ‘Judiciário federal’. A divisão da estrutura judiciária brasileira, sob tradicional, mas equivocada denominação, em Justiças, é só resultado da repartição nacional do trabalho da mesma natureza entre distintos órgãos jurisdicionais.”¹ Essa linha de raciocínio direciona a concessão do abono de permanência na magistratura, conforme estabelece o art. 40, § 19, da Constituição Federal (CF) de 1988 (incluído pela Emenda Constitucional 41/2003)².

A interpretação do preceito constitucional que rege a concessão do abono não dispensa esse elemento informador, indicativo da ocupação de novo cargo na magistratura, também contido na estrutura do Poder Judiciário. Assim, o respectivo deslocamento não pode resultar em prejuízo para o beneficiado, valendo notar a natureza do abono – incentivo à permanência em atividade por aqueles que já preencheram as condições para a aposentadoria³ previstas no art. 40, § 1º, III, da CF⁴.

1 ADI 3.367, rel. min. Cezar Peluso, P.

2 CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, *a*, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.”

3 MS 33.456, rel. min. Marco Aurélio, 1ª T.

- 4 CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (...) III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.”

- » Agentes públicos
 - » Regime próprio de previdência social
 - » Acumulação de proventos

A coisa julgada não está a salvo da incidência do disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)^{1,2}

Se um direito adquirido por força de decisão judicial transitada em julgado está em desacordo com os preceitos constitucionais que vieram a dar nova disciplina à matéria, ele pode ser reduzido. É inadmissível invocar direito adquirido ou percepção em excesso a qualquer título.

Nesse sentido, perante o art. 17, *caput*, do ADCT, não há opor a existência de coisa julgada material à superveniente proibição constitucional de cumulação de adicionais.

Por outro lado, a questão pode ainda ser vista na perspectiva de relação jurídica de natureza continuativa, ou de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada atua em termos análogos aos da cláusula *rebus sic stantibus*.^{3 e 4}

Caso, após a formação da coisa julgada material, se alterem os fatos elementares da causa de pedir da demanda julgada – os quais compõem a própria coisa, situação ou caso jurídico-material (*res*) julgado (*iudicata*), como na espécie –, situação ou coisa nova pode ser regida de maneira diferente a partir de então.⁵

Cabe destacar que essa natural restrição ao alcance da coisa nas relações jurídicas continuativas em nada fere a ordem constitucional. O que veda o art. 5º, XXXVI, da Constituição da República é só a aplicação retroativa de normas supervenientes à situação, caso ou coisa (*res*) que, julgada (*iudicata*) na sentença, foi recoberta da autoidade da *res judicata*.

Assim, quanto às relações de trato sucessivo, retroatividade só ocorreria se se atinxissem os eventos transcorridos até a data da alteração do estado ou da situação de fato ou de direito. Estes, sim, são intangíveis, enquanto não podem ser objeto doutra norma jurídica, assim abstrata, como concreta.⁶

A partir da modificação do quadro normativo, sobretudo de índole constitucional, os fatos posteriores configuram outra realidade (situação jurídico-material), sujeita à incidência da lei nova.^{7 e 8}

Se tal é o mecanismo da coisa julgada na generalidade das relações de trato sucessivo, há de sê-lo *a fortiori* no caso, em que não apenas a norma substancial superveniente integra a Constituição da República (art. 37, XIV), como é complementada por outra (ADCT, art. 17, *caput*), cujo caráter transitório não lhe turva a explicitude.

Ademais, no que concerne ao modo de operar tal incidência, reputa-se autoaplicável a norma contida no art. 17, *caput*, do ADCT.

Por fim, não é cabível a ação rescisória, uma vez que sua procedência pressupõe a existência de vício na sentença.⁹ Além disso, tal ação implica sua desconstituição desde o momento em que foi publicada, eficácia desconstitutiva e retroativa.

Essa disciplina não se ajusta à hipótese em que os efeitos produzidos da sentença, até o advento da Constituição de 1988, são plenamente válidos, cobertos, que estão, pela *res iudicata*.

As normas do art. 37, XIV, da Carta da República e do art. 17 do ADCT incidem apenas sobre os fatos ocorridos após o início de sua vigência.

Diante do exposto, não há garantia à continuidade de recebimento de adicionais por tempo de serviço em percentual superior àquele previsto em legislação posterior sob o fundamento de direito adquirido.¹⁰

A perpetuação do direito a adicionais, na forma estabelecida em lei revogada, implica a possibilidade de aquisição de direitos com base em regras abstratas decorrentes de sistema remuneratório já não mais em vigor, em clara afronta ao princípio da legalidade.

1 ADCT: “Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.”

2 RE 146.331 EDv, rel. min. Cezar Peluso, P; e RE 600.658, rel. min. Ellen Gracie, Plenário Virtual (processo com repercussão geral reconhecida).

3 “Cuida-se, no caso, do fenômeno processual que alguns denominam de ‘sentenças com a cláusula *rebus sic standibus*’ e que outros chamam de decisões instáveis. Essas decisões se apresentam sobretudo no campo das sentenças que incidem sobre relações continuativas. (...) O juiz, na nova decisão, não altera o julgado anterior, mas tão só o adapta a fatos jurídicos e à vontade da lei. A sentença é submetida a um processo de integração, decorrente de situação superveniente, a que deve o juiz atender, tendo em vista a natureza continuativa da relação jurídica decidida.” (MARQUES, José Frederico. *Instituições de direito processual civil*. Campinas: Millennium, 2000. v. 4, p. 383-384.)

- 4 “Sobre esse tema, há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças *atua rebus sic stantibus*. Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula *rebus sic stantibus*).” (Trecho do voto do red. p/ o ac. min. Teori Zavascki no RE 596.663, P.)
- 5 Conclusão que pode ser extraída diretamente do art. 471, *caput* e inciso I do CPC/1973, segundo o qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”.
- 6 CPC/1973: “Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.”
- 7 Nesse sentido, aliás, são aturadas as manifestações da Corte, como se deduz, por exemplo, ao Enunciado da Súmula 239: “Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.”
- 8 RE 90.518, rel. min. Xavier de Albuquerque, 1ª T; e RE 158.853, rel. min. Moreira Alves, 1ª T.
- 9 MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 5, p. 107-108.
- 10 Na situação dos autos, a partir da vigência da Lei 6.035/1974, é incabível a pretensão de manter a sistemática de aquisição de adicionais por tempo de serviço prevista na Lei 4.097/1962.

- » Regime próprio de previdência social
- » Acumulação de proventos

É legítima a acumulação de proventos civis e militares na hipótese de a reforma do militar ter ocorrido sob a égide da Constituição Federal (CF) de 1967 e o reingresso no serviço público civil ter se dado antes da vigência da Emenda Constitucional (EC) 20/1998, sendo irrelevante o fato de a aposentadoria civil ter acontecido em momento posterior.

A redação dada pela EC 20/1998 ao § 10 do art. 37 da CF¹ – que impede a acumulação de proventos de aposentadoria civis e militares – não se aplica aos servidores que tenham reingressado no serviço público até a data da alteração constitucional.²

Não se trata do recebimento de mais de uma aposentadoria pelo regime previdenciário do art. 40 da CF, o que é vedado pelo art. 11 da EC 20/1998, mas, sim, da percepção de provento civil (regime próprio do art. 40 da CF/1988) cumulado com o militar (regime próprio do art. 42 da CF/1988), situação não abarcada pela proibição da emenda.³

1 CF/1988: “Art. 37. (...) § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 [regime previdenciário dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios] ou dos arts. 42 [dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios] e 142 [das Forças Armadas] com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”

2 EC 20/1998: “Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.”

3 MS 24.997, rel. min. Eros Grau, P.

- » Agentes públicos
 - » Regime próprio de previdência social
 - » Adicional por tempo de serviço

São devidos adicionais por tempo de serviço que, em obediência à Lei 4.047/1961, tenham sido incorporados aos proventos de inativo por decisão transitada em julgado após a Constituição de 1988, de modo que o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não incide na espécie.

O Tribunal de Contas da União (TCU) não pode determinar a supressão de vantagem pecuniária incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público por força de decisão judicial transitada em julgado.¹

Nessas circunstâncias, a situação jurídica somente pode ser modificada pela via da ação rescisória, tendo em vista que a Constituição não outorgou competência ao TCU para impor à autoridade administrativa, sujeita à sua fiscalização, a suspensão do pagamento de vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria do servidor público por força de decisão judicial transitada em julgado.

Por outro lado, o art. 17, *caput*, do ADCT² determinou que as vantagens pecuniárias dos servidores que estivessem sendo percebidas em desacordo com a Constituição fossem imediatamente reduzidas aos limites dela decorrentes, não se admitindo invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.³

Por sua vez, a Constituição vedou, no art. 37, XIV⁴, o denominado “repique”, ou seja, o cálculo de vantagens pessoais uma sobre a outra, em “cascata”. Nada estabeleceu, contudo, acerca dos limites ao critério do cálculo do adicional por tempo de serviço, em termos de percentuais, de forma que coube à legislação infraconstitucional fazê-lo.

Nesse sentido, a gratificação em discussão nos autos deve ser mantida, pois os montantes em disputa estão distantes do teto fixado para os vencimentos dos servidores públicos, bem como não ocorreu o denominado “repique”, uma vez que o adicional objeto do mandado de segurança não foi computado, tampouco acumulado, para fins de concessão de ulteriores acréscimos.

- 1 Sobre a necessária observância da coisa julgada pelo TCU, destacam-se os seguintes precedentes: MS 25.460/DF, rel. min. Carlos Velloso P; RE 475.101 AgR/DF, rel. min. Ayres Britto, 1ª T; MS 25.418 MC/DF, rel. min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática; MS 25.160 MC/DF, rel. min. Ayres Britto, decisão monocrática; e AI 471.430 AgR/DF, rel. min. Eros Grau, 1ª T.
- 2 ADCT: “Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.”
- 3 Sobre a aplicabilidade do art. 17 do ADCT às situações acobertadas pela coisa julgada, conferir RE 146.337 EDv/PR, rel. min. Cezar Peluso, P.
- 4 CF/1988: “Art. 37. (...) XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal (CF) aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos.

O art. 40, § 1º, II, da CF¹ estabelece que a aposentadoria compulsória será aplicada apenas aos servidores titulares de cargo efetivo, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social. Não se aplica a aposentadoria compulsória pelo implemento de idade a titulares de serventias extrajudiciais por algumas razões, entre elas o fato de não serem servidores públicos titulares de cargo efetivo.²

Assim, cabe estender aos titulares de serventia judicial não estatizada remunerados, exclusivamente, por custas e emolumentos o mesmo tratamento conferido aos titulares de foro extrajudicial, tendo em vista a similitude das relações jurídicas. Afinal, ambos exercem atividade privada em colaboração com o poder público.

¹ CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (...) II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar.”

² ADI 2.602, red. p/ o ac. min. Eros Grau, P.

- » Agentes públicos
- » Regime próprio de previdência social
- » Aposentadoria

O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros.

A exigência consta da Lei 3.552/1959 e do Enunciado 96 da Súmula do Tribunal de Contas da União (TCU)¹. O elemento essencial à caracterização do tempo de serviço como aluno-aprendiz não seria a percepção de vantagem direta ou indireta, mas a efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. Como consequência, a declaração emitida por instituição de ensino profissionalizante somente serviria a comprovar o período de trabalho caso registrasse expressamente a participação do educando nas atividades laborativas desenvolvidas para atender aos pedidos feitos às escolas.

Da certidão lavrada pelo centro de ensino, deve constar a declaração da frequência em curso técnico profissionalizante por certo período e referência à participação na produção de quaisquer bens ou serviços solicitados por terceiros. É indispensável a demonstração de retribuição pecuniária à conta do orçamento, salvo casos em que haja situação já consolidada em entendimento anterior.²

A ausência de prova do desempenho concreto de atividades como aluno-aprendiz justifica a glosa da aposentadoria pelo Tribunal de Contas.³

¹ Enunciado 96 da Súmula do TCU: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros."

² RMS 21.185, rel. min. Cármen Lúcia, P.

³ MS 32.859, rel. min. Marco Aurélio, decisão monocrática.

- » Agentes públicos
 - » Regime próprio de previdência social
 - » Aposentadoria

A exposição meramente eventual a situações de risco – a que podem estar sujeitas diversas categorias de servidores públicos – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (CF)^{1, 2}

Diante do caráter aberto da expressão “atividades de risco” e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade for inequivocamente inerente ao ofício.

Portanto, somente se enquadram no conceito de “atividade de risco” as atividades perigosas por sua própria natureza. Apenas em relação a essas atividades é que existe um estado de omissão inconstitucional, salvo no caso das “estritamente policiais”, já contempladas pela Lei Complementar 51/1985.

O Congresso Nacional, quando cumprir o dever de legislar previsto no art. 40, § 4º, II, da CF, poderá prever critérios mais ou menos elásticos para a identificação das “atividades de risco”. Não poderá, contudo, deixar de contemplar as atividades inerentemente perigosas, sob pena de violação ao núcleo essencial do dispositivo.

Assim, embora as atividades de risco possam ser, em tese, previstas na lei a ser editada, a norma depende de escolha política, a ser exercida dentro do espaço próprio de deliberação majoritária, respeitadas as disposições constitucionais.

Quanto aos oficiais de justiça, cujas atribuições estão previstas no art. 143 do Código de Processo Civil (CPC) de 1973³, eles podem estar sujeitos a situações de risco, notadamente quando no exercício de funções em áreas dominadas pela criminalidade ou em locais marcados por conflitos fundiários. Trata-se de risco contingente, e não inerente ao serviço. O perigo na atividade seria eventual, portanto.

Ademais, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade pelos oficiais de justiça, bem como o fato de poderem obter autorização para porte de arma de fogo de uso permitido⁴ não são, por si sós, suficientes para reconhecer-lhes o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.

- 1 CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (...) II – que exerçam atividades de risco;”
- 2 Entendimento aplicado também no MI 844, red. p/ o ac. min. Roberto Barroso, P.
- 3 CPC/1973: “Art. 143. Incumbe ao oficial de justiça: I – fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências próprias do seu ofício, certificando no mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e hora. A diligência, sempre que possível, realizar-se-á na presença de duas testemunhas; II – executar as ordens do juiz a que estiver subordinado; III – entregar, em cartório, o mandado, logo depois de cumprido; IV – estar presente às audiências e coadjuvar o juiz na manutenção da ordem; V – efetuar avaliações.”
- 4 Lei 10.826/2003, art. 10, § 1º, I, c/ c art. 18, § 2º, I, da Instrução Normativa 23/2005-DG-DPF, e art. 68 da Lei 8.112/1990.

- » Agentes públicos
- » Regime próprio de previdência social
- » Aposentadoria

Não há omissão inconstitucional relativa à elaboração de lei complementar estadual sobre os critérios diferenciados para aposentadoria de policiais civis do sexo feminino.

A Lei Complementar (LC) 144/2014¹, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras de Polícia Civil estadual.²

A edição de lei complementar nacional que regule o tempo de contribuição para efeito de aposentadoria é impositiva. A matéria exige regramento uniforme, de caráter geral, mediante edição de lei pela União, a fim de evitar criação de regras distintas pelos Estados-membros para servidores em situações semelhantes. Isso decorre do caráter centralizador da Federação brasileira.

Assim, se a lei complementar federal regulamenta a matéria de forma exaustiva, não pode a lei estadual dispor de modo diverso, sob pena de afrontar as regras de repartição de competência firmadas pela Constituição. Portanto, o pedido de edição de lei estadual para o tema é improcedente e não há omissão inconstitucional.

Não há omissão inconstitucional relativa à elaboração de lei complementar estadual sobre os critérios diferenciados para aposentadoria de policiais militares do sexo feminino.

O art. 40, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal (CF) – parâmetro apontado para o controle de inconstitucionalidade por omissão – não é adequado à pretensão em matéria de aposentadoria especial de policiais militares.

Com o advento das Emendas Constitucionais 18/1998 e 20/1998, os militares foram excluídos do conceito de “servidores públicos” anteriormente concedido pela Constituição. Assim, não haveria vínculo com os servidores civis.³

Dessa forma, de acordo com o § 1º do art. 42 da CF⁴, a regra de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da CF é inaplicável ao policial militar estadual.⁵ Isso

ocorre devido à existência de dois regimes previdenciários distintos: um para os servidores civis e outro para os militares.

Por isso, o art. 40, § 20, da CF só permite a existência de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.

Não há, pois, omissão inconstitucional atribuível a Assembleia Legislativa e a governador de Estado-membro quanto ao art. 40, §§ 1º e 4º, da Constituição da República, porque esses dispositivos constitucionais são inaplicáveis aos militares.⁶

- 1 LC 144/2014: “Atualiza a ementa e altera o art. 1º da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, que ‘Dispõe sobre a aposentadoria do funcionário policial, nos termos do art. 103 da Constituição Federal’, para regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial.”
- 2 “A circunstância de a Lei Complementar n. 144/2014 ser objeto da ADI 5.129/DF, relator o ministro Gilmar Mendes, não obsta a conclusão agora exposta porque até o julgamento final por este Supremo Tribunal Federal sua constitucionalidade é presumida e sua aplicação permanece hígida no ordenamento jurídico brasileiro.” (Trecho do voto da rel. min. Cármen Lúcia no presente julgamento.)
- 3 “A Emenda Constitucional 18/1998 modificou a Seção III do Capítulo VII do Título III da Constituição, que compreende apenas o art. 42. Determinou que a rubrica da Seção, que era ‘Dos Servidores Públicos Militares’, passasse a ser ‘Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’. (...) A intenção confessada foi a de tirar dos militares o conceito de ‘servidores públicos’ que a Constituição lhes dava, visando com isso a fugir ao vínculo com os servidores civis, que esta lhes impunha. Sua organização e seu regime jurídico [dos militares], desde a forma de investidura até as formas de inatividade, diferem fundamentalmente do regime dos servidores civis. (...) Este artigo relaciona-se com o art. 144, V, §§ 5º e 6º, que têm a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militar como forças públicas destinadas à execução dos serviços de segurança pública.” (SILVA, José Afonso. *Comentário contextual à Constituição*. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 377-378.)
- 4 “O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.” (Trecho da ementa do presente julgado.)
- 5 ARE 824.832 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T; RE 785.239 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T; ARE 781.359 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T; e Rcl 18.758 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T.
- 6 ARE 824.832 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T; RE 785.239 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T; ARE 781.359 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T; e Rcl 18.758 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T.

- » Agentes públicos
- » Regime próprio de previdência social
- » Aposentadoria

Não se exigem, quanto à tramitação do processo de aposentadoria, a bilateralidade, o contraditório e a audição do servidor envolvido.

A aposentadoria reclama atos sequenciais¹, consoante disposto no Enunciado 3 da Súmula Vinculante².

Por outro lado, a controvérsia sobre a suspensão do pagamento da Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF) – recebida cumulativamente com parcela relativa a décimos e quintos – a aposentados e pensionistas filiados da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal (ADPF) não envolve incorporação, mas, sim, ausência do direito à cumulatividade, o que torna irrelevante a incorporação anteriormente versada no art. 193 da Lei 8.112/1990³.

No tocante à devolução das parcelas recebidas, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, o qual estabelece que somente podem ser satisfeitos valores quando previstos em lei.

¹ RE 195.861, rel. min. Marco Aurélio, 2ª T.

² Enunciado 3 da Súmula Vinculante: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assecuram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”

³ Lei 8.112/1990: “Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos. § 1º Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos. § 2º A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção.”

- » Agentes públicos
- » Regime próprio de previdência social
- » Aposentadoria

Apesar de não possuírem direito adquirido a regime de remuneração, os servidores públicos detêm direito líquido e certo de não receber a menor, a despeito do advento de nova forma de composição de seus proventos, uma vez que a irredutibilidade de vencimentos é garantia fundamental^{1 e 2} e, portanto, inelidível por emenda à Constituição.

Procurador da República aposentado tem o direito de, a partir da data da impetração do mandado de segurança, continuar a receber, sem redução, o montante bruto que percebia anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, até a total absorção pelas novas formas de composição de seus proventos.

Entretanto, nos termos dos Enunciados 269³ e 271⁴ da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração.

1 CF/1988: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;”

2 CF/1988: “Art. 37. (...) XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

3 Enunciado 269 da Súmula do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

4 Enunciado 271 da Súmula do STF: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

- » Agentes públicos
 - » Regime próprio de previdência social
 - » Aposentadoria

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.”

Com esse teor, o Plenário aprovou a edição do Enunciado 33 da Súmula Vinculante.

Possui natureza taxativa o rol de doenças incapacitantes que autorizam – nos termos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal (CF)¹ – a concessão de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, aos servidores públicos acometidos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

A Constituição exige, expressamente, que a doença incapacitante esteja especificada em lei, de modo que afronta a norma constitucional decisão que conceda o benefício com inobservância das hipóteses legais.²

1 CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”

2 RE 175.980, rel. min. Carlos Velloso, 2ª T; RE 678.148 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T.

- » Agentes públicos
 - » Regime próprio de previdência social
 - » Custeio

É inconstitucional o parágrafo único do art. 110 da Lei 915/2005 do Estado do Amapá¹, que – acrescido ao art. 110 do texto original por meio de emenda parlamentar – estabelece que a Amapá Previdência assumirá o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão que tenham sido concedidos pelos Poderes do Estado, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas durante o período de vigência do Decreto 87/1991.

A transferência da responsabilidade a fundo previdenciário pelo pagamento das aposentadorias e pensões a beneficiários de regime próprio de previdência social sem que haja contrapartida dos segurados ou do próprio ente federado acarreta grave ofensa à regra de equilíbrio financeiro e atuarial do sistema próprio de previdência [Constituição Federal (CF), art. 40, *caput*²].

Inicialmente, a CF regravava de forma deficiente a natureza contributiva do regime de previdência pública no âmbito estadual, distrital e municipal, apenas facultando a possibilidade de cobrança de contribuição.

Todavia, após a Emenda Constitucional (EC) 41/2003, a CF passou a impor, de forma expressa, a contribuição aos servidores, em prol da manutenção do sistema previdenciário. Nesses termos, o § 1º do art. 149, na redação conferida pela EC 41/2003, passou a exigir que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituissem “contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União”.

Essa disposição está em consonância com a nova redação do art. 40, *caput*, da CF, após a modificação da EC 41/2003, que assegurou, de modo expresse, o caráter necessariamente contributivo e solidário do regime próprio de previdência, além de ter determinado que se preservasse seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Dentro desse contexto, passou a ser imprescindível a incessante busca do equilíbrio financeiro e atuarial, requisito que é desde sempre elementar a todo sistema previdenciário, estatal ou privado. Esse equilíbrio destina-se à preservação da suficiência,

presente e futura, do fundo de previdência, tendo em vista o sopesamento entre as receitas e as despesas com benefícios, o qual estaria prejudicado com a assunção de obrigação desprovida de qualquer contraprestação pecuniária.

- 1 Lei 915/2005 do Estado do Amapá: “Art. 110. O Estado responderá subsidiariamente pelo pagamento das aposentadorias e pensões concedidas na forma desta Lei, na hipótese de extinção, insolvência ou eventuais insuficiências financeiras do Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Parágrafo único. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta Lei, a Amapá Previdência, desde que provocada pelo Órgão interessado, assumirá o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão que tenham sido concedidos por qualquer dos Poderes do Estado, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas durante o período de vigência do Decreto n. 0087, de 6 de junho de 1991, e que, nesta data, estejam sendo suportados exclusiva e integralmente pelo Tesouro Estadual.”
- 2 CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.”

Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional (EC) 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º¹), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005². Não têm, contudo, direito à integralidade [Constituição Federal (CF), art. 40, § 7º, I].

A aposentadoria, em regra, é regida pela legislação vigente na época em que o servidor implemtou as condições para obtê-la. A pensão igualmente observa o princípio do *tempus regit actum* e regula-se pela lei vigente na ocasião do falecimento do segurado instituidor.

A EC 41/2003 pôs fim à denominada “paridade”, ou seja, à garantia ao reajuste dos proventos de aposentadoria e das pensões sempre que houvesse correção dos vencimentos dos servidores da ativa. Logo, pensionistas de servidor falecido após a promulgação da referida emenda não teriam direito à paridade.

Entretanto, a EC 47/2005 excepcionou essa regra. Garantiu o direito à paridade às pensões derivadas de óbito de servidores que tivessem ingressado no serviço público até 16-12-1998 (art. 3º) e que, além disso, preenchessem os demais requisitos nela consignados.

Assim, a EC 47/2005 somente estendeu aos pensionistas o direito à paridade, e não à integralidade.

¹ EC 41/2003: “Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

- 2 EC 47/2005: “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do *caput* deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”

- » Agentes públicos
- » Regime próprio de previdência social
- » Pensão por morte

O reconhecimento judicial de união estável não constitui requisito legal para concessão de pensão por morte à companheira, mesmo que o casamento anterior ainda esteja formalmente vigente.

A união estável e a separação de fato dispensam reconhecimento judicial para produzirem efeitos. Nesse sentido, segundo o Código Civil (CC) (art. 1.723, § 1^o), não há impedimento ao reconhecimento de união estável se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente.

Ao tratar da pensão por morte de servidor público em favor de companheiro dependente, o art. 217, I, c, da Lei 8.112/1990² não exige que a prova da união estável seja feita mediante decisão judicial.

Assim, não se pode negar a concessão de pensão por morte à companheira sob o fundamento único de que a união estável deve ser declarada judicialmente. Cabe à Administração Pública averiguar, no âmbito administrativo, se existem provas da separação de fato, bem como da união estável.

1 CC: “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.”

2 Lei 8.112/1990: “Art. 217. São beneficiários das pensões: I – vitalícia: (...) c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar;” (Redação original.) Com as alterações promovidas pela Lei 13.135/2015, o dispositivo agora consta do inciso III do art. 217 da Lei 8.112/1990, com a seguinte redação: “Art. 217. São beneficiários das pensões: (...) III – o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar;”

- » Agentes públicos
- » Regime próprio de previdência social
- » Pensão por morte

Menor sob a guarda de servidor público tem, nos termos do art. 217, b, da Lei 8.112/1990, direito à pensão por morte até completar 21 anos de idade.¹

O art. 5º da Lei 9.717/1998 – que veda a concessão, pelo Regime Próprio de Previdência Social, de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) – não derogou os benefícios previstos no art. 217, II, *a, b, c e d*², da Lei 8.112/1990³, que estabelece os destinatários das pensões civis estatutárias.

Além disso, a previsão do benefício da pensão por morte ao dependente do segurado na Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991, art. 18, II, *a*) seria suficiente para autorizar a concessão do mesmo benefício nos regimes próprios dos servidores públicos, sendo indiferente, juridicamente, a discrepância entre as listas de beneficiários da pensão.

As reformas constitucionais ocorridas em matéria previdenciária não tiveram o condão de extirpar dos entes federados a competência para criar e dispor sobre regime próprio para os seus servidores, com a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como das normas gerais estabelecidas pela União. Sob essa perspectiva, interpretação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que admita a vinculação dos critérios de concessão de benefícios nos regimes próprios àqueles estipulados no Regime Geral de Previdência Social ofende o art. 24, XII, da Constituição Federal (CF).

Ademais, inexistente lacuna legislativa apta a autorizar a aplicação subsidiária do RGPS no que se refere aos benefícios previstos no regime próprio de previdência dos servidores federais. A Lei 8.112/1990 apresenta disciplina exaustiva sobre a pensão por morte, em cumprimento ao disposto no § 5º da norma originária do art. 40 da CF, hoje § 7º.

Assim, considerada a diversidade da natureza das normas previdenciárias em discussão, não se pode falar em revogação expressa de uma lei pela outra, tampouco em derrogação tácita das alíneas do inciso II do art. 217 da Lei 8.112/1990 (regime próprio) pelo § 2º do art. 16 da Lei 8.213/1991 (regime geral).

Além do mais, as normas dos sistemas de proteção social são fundadas na ideia de abrigo aos menos favorecidos, quando colocados em situação de desamparo pela ocorrência de risco social. Entre as situações constitucionalmente inseridas na previdência social brasileira está a morte de segurado que seja provedor econômico de determinada pessoa.

Nesse aspecto, a preocupação com os indivíduos em relação a eventos que lhes possam causar dificuldade ou até mesmo impossibilidade de subsistência estaria na gênese da proteção social almejada pelo Estado contemporâneo.

Posto isso, a interpretação conferida ao art. 5º da Lei 9.717/1998 pelo Tribunal de Contas da União que exclua da ordem dos beneficiários tradicionalmente consagrados pela previdência social pessoa em comprovada situação de dependência econômica do segurado se divorciaria do sistema de proteção formatado na Constituição e afrontaria, ainda, os princípios da vedação do retrocesso social e da proteção ao hipossuficiente.

1 Entendimento aplicado também no MS 31.687 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T.

2 Lei 8.112/1990: “Art. 217. São beneficiários das pensões: (...) II – temporária: a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade; c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor; d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez.”

3 Artigo alterado pela Lei 13.135/2015, cujo teor passa a ser o seguinte: “Art. 217. São beneficiários das pensões: I – o cônjuge; II – o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente; III – o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar; IV – o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; b) seja inválido; c) tenha deficiência grave; ou d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento; V – a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e VI – o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.”

O cargo de agente administrativo – com exigência de escolaridade de nível médio – não se enquadra no conceito constitucional de cargo de natureza técnica, de sorte que não se subsume à excepcional hipótese de permissão de acúmulo de cargo público, contida no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal (CF)¹.

A natureza técnica apenas se configura nos cargos que exijam, no desempenho de suas atribuições, a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber. Excluem-se, assim, cargos que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e cujo exercício não exija formação específica.

Tendo isso em conta, o prazo para a Administração anular os atos de nomeação nos cargos que ensejaram a acumulação indevida é de cinco anos, nos termos fixados no art. 54 da Lei 9.784/1999², cujo termo inicial é o conhecimento da ilegalidade pela Administração.

Entretanto, nas hipóteses em que a ciência da Administração ocorra antes da vigência da referida Lei 9.784/1999, o prazo decadencial somente tem início a partir do advento dessa norma (29-1-1999). Assim, não há que falar em deflagração em momento anterior.

Além disso, a omissão em declarar a ocupação de um dos cargos no ato da posse em um outro, bem como o silêncio no momento de optar por um deles, quando convocado a esse fim, afastam a boa-fé e a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.

¹ CF/1988: “Art. 37. (...) XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;”

² Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

- » Agentes públicos
- » Servidores públicos
- » Cessão

O ônus remuneratório decorrente da cessão de servidor público para exercício de cargo em comissão ou função de confiança deve ser suportado pelo órgão cessionário, seja quando a cessão ocorrer do âmbito federal para o estadual, distrital ou municipal, seja quando seguir a situação inversa, tal qual disposto no art. 93, I e § 1º, da Lei 8.112/1990^{1, 2}

O § 5º do art. 93³ (com a redação dada pela Lei federal 9.527/1997) é mera explicação da regra geral, segundo a qual, em caso de cessão de servidor público, o ônus da remuneração deve recair sobre o órgão ou a entidade requisitante, qualquer que seja a esfera da Federação. Afinal, o cessionário é o único beneficiário do trabalho do servidor cedido.

A Constituição já comportava interpretação no sentido da possibilidade de custeio, pela União, dos ônus remuneratórios de servidor a ela cedido, mesmo antes do advento de norma federal que previsse tal responsabilidade. O reconhecimento desse ônus financeiro ocorreu com a edição da Medida Provisória 1.573-9/1997, convertida na Lei 9.527/1997, que acrescentou o referido § 5º ao art. 93 da Lei 8.112/1990.

Sendo a cessão de servidores parte do arco maior da cooperação federativa, cabe à União, como regra de isonomia, ressarcir os valores desembolsados pelo Distrito Federal com o servidor cedido. Não há razão para admitir que a União tenha esse privilégio em detrimento dos demais entes da Federação.

Além disso, não se trata de aplicação retroativa da lei de 1997, mas de interpretação que harmoniza o preceito original com o texto maior, consideradas as modificações legislativas posteriores como simples confirmação da necessidade dessa compatibilização.

¹ Redação do dispositivo legal à época dos fatos: “Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses: I – para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; (...) § 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária.”

- 2 Embora a Corte tenha assentado entendimento no sentido da inexistência de conflito federativo em lides que versam sobre pretensões de cunho meramente patrimonial, a competência para o julgamento desta ação civil originária (ACO 555) foi definida em questão de ordem suscitada pelo antigo relator do processo, ministro Sepúlveda Pertence. A questão de ordem foi julgada em 4-8-2005 e publicada no *DJ* de 16-9-2005.
- 3 Lei 8.112/1990: “Art. 93. (...) § 5º Aplicam-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as regras previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, conforme dispuser o regulamento, exceto quando se tratar de empresas públicas ou sociedades de economia mista que recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal. (Incluído pela Lei 9.527, de 10-12-1997).”

O pedido de desligamento, uma vez completado o período de Escola Naval, gera para o Estado o direito à indenização, nos termos da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares)¹.

Em que pese a expressa referência ao oficialato, a disciplina do inciso II do art. 116 do Estatuto dos Militares não impede o reconhecimento da ocorrência de enriquecimento ilícito, sem que isso represente ofensa ao art. 206, IV, da Constituição Federal (CF)².

Não cabe extrair do Estatuto dos Militares preceitos a liberar os praças especiais do ressarcimento à Fazenda Pública, o que implicaria indesejado incentivo à evasão. O art. 116, II, da Lei 6.880/1980 disciplina a contagem do prazo dentro do qual a indenização deverá ser exigida daqueles que, após o término da graduação militar, procurem outros rumos profissionais.

A segurança jurídica, um dos pilares axiológicos do Estado Democrático de Direito, obriga não só a Administração Pública mas também aqueles que com ela travem relações jurídicas a atuar com lealdade e a não frustrar as legítimas expectativas criadas a partir de condutas.

1 Lei 6.880/1980: “Art. 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado: (...) II – com indenização das despesas feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco) anos de oficialato.”

2 CF/1988: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;”

É inconstitucional a concessão de sessenta dias de férias aos servidores da Justiça estadual como decorrência da associação entre esse direito e o período de férias coletivas concedidas nos tribunais.¹

A Emenda Constitucional (EC) 45/2004, “ao vedar as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, revogou os atos normativos inferiores que a elas se referiam”². Nesse sentido, se a Constituição veda a concessão de férias coletivas aos magistrados, com vista a garantir que a atividade jurisdicional seja ininterrupta³, seria também inadmissível o gozo coletivo de férias pelos servidores de tribunal de justiça local.⁴

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) possui competência constitucional para anular a fixação de férias em sessenta dias para servidores de segunda instância da Justiça estadual.

A disciplina das férias de serventuários da Justiça de qualquer dos Estados-membros da Federação, entre outras matérias, constitui função cominada ao CNJ pela Constituição Federal (CF), em seu art. 103-B⁵, no qual se prescreve a competência do CNJ para “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário” (§ 4º), “zelando pela observância do art. 37 e apreciando, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário” (inciso II).

¹ “1. A insurgência no sentido de reconhecer o direito adquirido de servidores do TJMG a férias de sessenta dias configura mera pretensão de reabrir a discussão de matéria já decidida pelo Plenário da Corte, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração. 2. O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento. Precedentes. 3. Ausência de omissão quanto à definição dos efeitos do acórdão. O resultado do julgado embargado não foi a declaração de inconstitucionalidade da norma local que assegurou sessenta dias de férias a servidores, apreciação realizada apenas para reconhecer

a constitucionalidade do ato do CNJ que determinou a suspensão dessa forma de gozo do direito.” (Ementa do MS 26.739 ED, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T.)

- 2 “1. A EC 45/2004, ao vedar as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, revogou os atos normativos inferiores que a elas se referiam, sendo pacífico o entendimento, desta Corte, no sentido de não ser cabível a ação direta contra ato revogado. 2. Pedido de declaração de inconstitucionalidade prejudicado.” (Ementa da ADI 3.085, rel. min. Eros Grau, P.)
- 3 CF/1988: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XII – a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente;”
- 4 No caso, a conclusão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, das férias coletivas nos tribunais, aplica-se aos servidores do TJMG, cujo direito às férias de sessenta dias estabeleceu-se em normativos fundamentados nas férias forenses coletivas.
- 5 CF/1988: “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (...) § 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. § 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. § 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correccional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; VI – laborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.”

Os procuradores federais têm direito a férias de trinta dias (Lei 9.527/1997, art. 5º) e não de sessenta dias.

O art. 1º da Lei 2.123/1953 – que garante aos procuradores das autarquias federais as mesmas prerrogativas dos membros do Ministério Público da União – e o art. 17, parágrafo único, da Lei 4.069/1962 – que fixa vencimentos, gratificações e vantagens aos demais membros do serviço jurídico da União – foram recepcionados pela nova ordem constitucional com *status* de lei ordinária e não com natureza complementar. Por essa razão, foram posteriormente revogados pelo art. 18 da Lei 9.527/1997.

A controvérsia envolve a interpretação do art. 131, *caput*, da Constituição Federal (CF)¹ e sua aplicação aos procuradores federais. O dispositivo não trata da Procuradoria-Geral Federal ou dos procuradores federais. Em outras palavras, esse preceito não disciplina a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas (Administração Indireta), mas apenas da União (Administração Direta). O § 3º² do artigo refere-se à Advocacia-Geral da União (AGU) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Segundo a evolução legislativa da matéria, até o advento da Medida Provisória 2.229-43/2001, não havia a carreira de procurador federal, e sim cargos diversos cujos titulares eram responsáveis pela representação judicial, consultoria e assessoria jurídica das autarquias e fundações públicas federais. A esses cargos se referiam o art. 1º da Lei 2.123/1953 e o art. 17, parágrafo único, da Lei 4.069/1962. A Procuradoria-Geral Federal foi criada posteriormente, com a Lei 10.480/2002.

Assim, à representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais não se aplica o art. 131 da CF, pelo que a Lei Complementar 73/1993 (Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União) limita-se a dispor, em seu art. 17, que os órgãos jurídicos das autarquias e das fundações públicas são vinculados à AGU.

Portanto, é juridicamente inadequado manter a equiparação dos procuradores autárquicos (hoje procuradores federais) aos membros do Ministério Público Federal.

Aqueles perderam, desde a vigente Constituição, a função de representantes jurídicos da União, transferida para a AGU, nos termos do art. 131 da CF.

- 1 CF/1988: “Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.”
- 2 CF/1988: “Art. 131. (...) § 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.”

- » Agentes públicos
- » Servidores públicos
- » Jornada de trabalho

A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos públicos do Poder Judiciário Federal das áreas de medicina e odontologia é, respectivamente, de quatro (vinte horas semanais) e seis (trinta horas semanais) horas diárias.

A Lei 11.416/2006 é silente a respeito da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário. Porém, existindo legislação específica que discipline a jornada de médicos e odontólogos ocupantes de cargos públicos, aplica-se a norma de caráter especial em detrimento da regra geral inserta no *caput* do art. 19 da Lei 8.112/1990¹.

Nos termos da Lei 12.702/2012 e do Decreto-Lei 2.140/1984, a jornada de trabalho dos servidores das áreas de medicina e odontologia é, respectivamente, de vinte horas semanais (no caso dos médicos) e trinta horas semanais (para os odontólogos).

As leis acima mencionadas não contemplam servidores analistas judiciários – especialidades medicina ou odontologia – ocupantes de cargo em comissão e função comissionada. Nesse caso, terão que cumprir a jornada integral de trabalho.

¹ Lei 8.112/1990: “Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.”

- » Agentes públicos
 - » Servidores públicos
 - » Jornada de trabalho

A Lei 10.356/2001 – que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira do Tribunal de Contas da União (TCU), bem como determina aos ocupantes do cargo de analista de controle externo da área de apoio técnico e administrativo, especialidade Medicina, que optem por uma das jornadas de trabalho estabelecidas na mencionada lei e, conseqüentemente, por remuneração equitativa ao número de horas laboradas¹ – é aplicável somente aos profissionais de Medicina que ingressaram no quadro do TCU a partir da vigência da nova regra, ou seja, dezembro de 2001.

A lei questionada – ao impor a jornada de trabalho de quarenta horas semanais para percepção do mesmo padrão remuneratório e permitir a manutenção da jornada de vinte horas semanais com redução proporcional de vencimentos aos servidores médicos que àquela época já atuavam no TCU – implicou decesso relativamente aos servidores que já se encontravam no quadro funcional do TCU, o que afronta o art. 37, XV, da Constituição Federal.

¹ V. Informativos 592 e 648.

- » Agentes públicos
- » Servidores públicos
- » Licença para acompanhamento de cônjuge

A licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o § 2º do art. 84 da Lei 8.112/1990¹ não se aplica em casos de provimento originário de cargo público.

Os institutos da remoção e do exercício provisório, ambos para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, estão intimamente ligados à quebra da unidade familiar gerada pela própria Administração Pública. Assim, quando o servidor for deslocado no interesse da Administração, a lei trata de compensar o transtorno causado na vida desse servidor, recompondo a unidade familiar.

Nos casos de provimento originário de cargo público ou de remoção a pedido do servidor, o fracionamento da família é voluntário, pelo que não se pode obrigar a Administração Pública a suportar eventuais ônus decorrentes da ausência da mão de obra no local de lotação do servidor.

Nada obstante, esse entendimento não tem efeito sobre as nomeações para exercício de cargos em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, observada a vedação à prática de nepotismo.

¹ Lei 8.112/1990: “Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo. (...) § 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.”

- » Agentes públicos
- » Sistema remuneratório
- » Acumulação de proventos e pensões

É legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal (CF) de 1967, e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional (EC) 20/1998¹.

A EC 20/1998 assegura aos inativos que tiverem reingressado ao serviço público antes da vigência da referida emenda constitucional a acumulação de vencimentos do novo cargo exercido com os proventos da aposentadoria já recebida.

O art. 11 da referida emenda, por sua vez, em sua segunda parte, vedou expressamente a concessão de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência dos servidores civis previsto no art. 40 da CF². No entanto, não há qualquer referência à concessão de proventos militares, estes previstos nos arts. 42³ e 142⁴ da CF.

Segundo o texto constitucional, a percepção de dois proventos públicos, um civil e um militar, ambos concedidos antes da EC 20/1998, é situação não alcançada pela proibição da referida emenda. Portanto, é legítima sua cumulação.⁵

¹ EC 20/1998: “Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.”

² CF/1988: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.”

³ CF/1988: “Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes

dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.”

- 4 CF/1988: “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. § 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.”
- 5 MS 25.192, rel. min. Eros Grau, P; MS 24.958, rel. min. Marco Aurélio, P; e AI 801.096 AgR-EDv, rel. min. Teori Zavascki, P.

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Agentes políticos

Há indício de inconstitucionalidade em dispositivo de Constituição estadual que estabeleça pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governador, a título de representação, igual à remuneração do cargo de desembargador do tribunal de justiça do Estado.

No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados em caráter permanente, por serem os mandatos temporários, e seus ocupantes, transitórios.

Ex-governador não é mais agente público. Logo, não se pode cogitar que a Administração Pública lhe pague subsídio mensal e vitalício igual à remuneração do desembargador do tribunal de justiça do Estado.

Tal situação estenderia o subsídio a quem não mais trabalha no Estado e, por isso, não teria razão para ser remunerado, menos ainda em idêntica situação ao governador em exercício.

Além disso, a carência de parâmetro constitucional nacional e a inauguração de padrão normativo estadual em desacordo com os princípios da Constituição da República, especialmente aqueles referentes às regras orçamentárias e aos princípios constitucionais da Administração Pública, evidenciam a relevância jurídica da questão e os gravames jurídicos e sociais que a preservação dos efeitos da norma poderia acarretar.

Em decorrência disso, foi deferida medida cautelar para determinar a suspensão da eficácia do art. 305 da Constituição do Estado do Pará¹ e, por arrastamento, de seu § 1º², até a conclusão do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

1 Constituição do Estado do Pará: “Art. 305. Cessada a investidura no cargo de Governador, quem o tiver exercido em caráter permanente fará jus, a título de representação, a um subsídio mensal e vitalício igual à remuneração do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.”

2 Constituição do Estado do Pará: “Art. 305. (...) § 1º O pagamento de subsídio estabelecido neste artigo será suspenso durante o período em que o beneficiário estiver no exercício de mandato eletivo ou cargo em comissão, salvo direito de opção.”

Limitada a discussão à eficácia temporal da sentença, não há falar em imutabilidade da própria decisão.

Ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação.¹

Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula *rebus sic stantibus*²).

Assim, inexistente ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que determina a exclusão de parcela incorporada aos proventos por decisão judicial, se, após o provimento, houver alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte.

Não há que se falar em ação rescisória, porque não se debate a imutabilidade ou a validade da sentença.

Também não é o caso de se cogitar ação revisional, pois as modificações das razões de fato ou de direito que serviram de suporte para a sentença operam efeitos imediatos e automaticamente, dispensando-se novo pronunciamento judicial.

Diante disso, tendo havido modificação da estrutura remuneratória³, a decisão deve produzir efeitos somente durante a vigência do regime jurídico anterior. Com a mudança de regime, não é possível manter o pagamento de vantagem econômica sem qualquer limitação temporal.

Contudo, a alteração do regime jurídico garante à impetrante o direito à irredutibilidade dos vencimentos.⁴

Assim, tendo a impetração se limitado a suscitar ofensa à coisa julgada, afasta-se a alegação de ocorrência de direito líquido e certo, porque o ato atacado apenas interpretou o alcance da eficácia temporal da coisa julgada.

- 1 RE 596.663, rel. orig. min. Marco Aurélio, rel. p/ o ac. min. Teori Zavascki, P.
- 2 “Sobre esse tema, há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua *rebus sic stantibus*. Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula *rebus sic stantibus*).” (Trecho do voto do red. p/ o ac. min. Teori Zavascki no RE 596.663, P.)
- 3 Na espécie, o Plenário, por maioria, denegou mandado de segurança impetrado contra ato do TCU, que determinara a suspensão do pagamento da incorporação do reajuste de 26,05% e 26,06% – referentes aos vencimentos de fevereiro de 1989 e julho de 1987, respectivamente – aos proventos de servidora pública aposentada – v. *Informativo* 454. A impetrante teria requerido o pagamento do índice de 26,05% fixado para Unidade de Referência de Preço (URP) relativa ao mês de fevereiro de 1989 e consequente incorporação deste percentual a partir de março de 1989.
- 4 RE 563.965, rel. min. Cármen Lúcia, P.

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Auxílio-alimentação

O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

Com esse teor, o Plenário aprovou a edição do Enunciado 55 da Súmula Vinculante. Tornou, assim, vinculante o Verbete 680 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, de mesma redação.

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Contribuição facultativa

Somente a partir de 14 de março de 2010, data da conclusão do julgamento da ADI 3.106¹, tornou-se possível a repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais para custeio compulsório da assistência à saúde. Trata-se de benefício fomentado pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores daquele Estado.

Nos termos da declaração de inconstitucionalidade proferida naquela data, os Estados-membros não têm competência para incluir os serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica no rol de benefícios de custeio obrigatório pelos servidores públicos estaduais. Eles devem ser financiados pelos servidores interessados mediante o pagamento de contribuição facultativa.

A concessão de efeitos retroativos à decisão do Supremo Tribunal Federal implicaria o dever de devolução, por parte do Estado de Minas Gerais, de contribuições recolhidas por duradouro período de tempo. Além disso, desconsideraria que serviços médicos, hospitalares, odontológicos, sociais e farmacêuticos foram colocados à disposição dos servidores estaduais para utilização imediata quando necessária. Afinal, ainda que não tenham sido utilizados, os serviços foram disponibilizados, e os custos gerados são hoje irrecuperáveis.

¹ “Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 79 e 85 da Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002, do Estado de Minas Gerais. Impugnação da redação original e da redação conferida pela Lei Complementar 70, de 30 de julho de 2003, aos preceitos. IPSEMG. Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Benefícios previdenciários e aposentadoria assegurados a servidores não titulares de cargo efetivo. Alegação de violação do disposto no § 13 do art. 40 e no § 1º do art. 149 da Constituição do Brasil. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Art. 85, *caput*, da Lei Complementar 64 estabelece que ‘o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes’. A Constituição de 1988 – art. 149, § 1º – define que ‘os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social’. O preceito viola o texto da Constituição de

1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão ‘definidos no art. 79’ contida no art. 85, *caput*, da Lei Complementar 64/2002. 2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir. 3. O art. 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde – ‘plano de saúde complementar’. Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo ‘compulsoriamente’ contido no § 4º e no § 5º do art. 85 da Lei Complementar 64/2002, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. 4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao art. 79 da Lei Complementar 64/2002, na redação conferida pela Lei Complementar 70/2003, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais – ‘Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar n. 64, de 2002’. 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão ‘definidos no art. 79’ – art. 85, *caput*, da Lei Complementar 64/2002 (tanto na redação original quanto na redação conferida pela Lei Complementar 70/2003), ambas do Estado de Minas Gerais; [ii] do vocábulo ‘compulsoriamente’ – §§ 4º e 5º do art. 85 (tanto na redação original quanto na redação conferida pela Lei Complementar 70/2003), ambas do Estado de Minas Gerais.” (ADI 3.106, rel. min. Eros Grau, P.)

O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, de modo que a Administração não pode retroagir os efeitos financeiros a data anterior.

É ilegítima, nesse ponto, a Portaria/Mapa 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária (GDATFA) ao início do ciclo avaliativo.

A questão em debate é análoga à decidida no julgamento do RE 476.279 (DJE de 15-6-2007) e do RE 476.390 (DJE de 29-6-2007), quando o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou a extensão de outra gratificação – Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA) – aos inativos e cujo entendimento encontra-se sedimentado no Enunciado 20 da Súmula Vinculante¹. A GDATFA e a GDATA são gratificações de mesma natureza e com idênticas características. Originalmente, ambas foram concedidas a todos os servidores de forma geral e irrestrita, apesar de criadas com o propósito de serem pagas de modo diferenciado, segundo a produção ou o desempenho profissional, individual ou institucional.

A distinção entre ambas se refere à realização, em relação à GDATFA, das avaliações que justificam o uso do critério diferenciador no pagamento – desempenho individual do servidor e institucional do órgão de lotação –, circunstância imprescindível para legitimar a ausência de paridade entre os servidores ativos e os servidores inativos e pensionistas. Portanto, no caso, a meritocracia pretendida com a criação das gratificações de desempenho foi efetivada, o que permite a diferenciação no seu pagamento entre os servidores na ativa – de acordo com a produtividade e o desempenho profissional de cada um –, e entre estes e os aposentados e pensionistas.

Embora o requisito necessário à legitimação do pagamento diferenciado da GDATFA tenha sido implementado durante a vigência da norma instituidora, ficou pendente o debate sobre o termo final do direito à paridade. O STF, quando do julgamento do

RE 631.389 (DJE de 3-6-2014) – que trata da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDGPGE) –, assentou que o marco temporal para o início do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho para ativos e inativos é o dia de conclusão da avaliação do primeiro ciclo, que corresponde à data igual ou posterior ao final do ciclo, não podendo retroagir ao seu início.

Na situação dos autos, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho dos servidores públicos que recebem a GDATA iniciou-se em 25-10-2010, dia da publicação da Portaria/Mapa 1.031/2010, a qual retroagiu a essa data o início dos efeitos financeiros. Essa retroação, portanto, contrariou a jurisprudência do STF. Na prática, deve ser observado o dia 23-12-2010, data da conclusão do ciclo e da homologação dos resultados das avaliações.

- 1 Enunciado 20 da Súmula Vinculante: “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-administrativa – GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.”

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Gratificações de desempenho

“A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).”

Com esse teor, o Plenário aprovou a edição do Enunciado 34 da Súmula Vinculante.

Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede incorporação de quintos pelo exercício de função ou cargo comissionado no período compreendido entre 8-4-1998 e 4-9-2001 – datas de edição da Lei 9.624/1998 e da Medida Provisória (MP) 2.225-45/2001, respectivamente –, devido à carência de fundamento legal.^{1 e 2}

Inicialmente, deve-se considerar: (i) que o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória, seja quintos, seja décimos, foi extinto pela Lei 9.527/1997³; e (ii) que a MP 2.225-45/2001⁴ transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11-7-1994⁵, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2-4-1998.

Assim, diversamente do afirmado na decisão recorrida, nem o direito à incorporação foi revogado pela Lei 9.624/1998 (DOU de 8-4-1998), nem a MP 2.225/2001 (DOU de 4-9-2001) foi editada para extinguir definitivamente esse direito.^{6 e 7}

Definido o alcance das normas em debate, é sabido que não se pode revogar o direito à incorporação, extinto pela Lei 9.527/1997, salvo mediante outra lei e de forma expressa, o que, conforme visto, não ocorreu, por ocasião da edição da Lei 9.624/1998.

Posto isso, é princípio mezinho a determinação de que a concessão de vantagens a servidores públicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, inexistindo lei, a incorporação de quintos e décimos não é devida.

Nesse sentido, não há no ordenamento jurídico norma que permita a pretendida reinstituição dos quintos/décimos levada a efeito pela decisão recorrida, razão suficiente para atestar a violação ao princípio da legalidade.

Por fim, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a Corte obistou a repetição do indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese.

- 1 Entendimento aplicado também no MS 25.763, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P.
- 2 A Corte, embora tenha julgado prejudicado o MS 25.845, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P, adentrou na análise da questão constitucional e reiterou o entendimento firmado no MS 25.763, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P. Trechos do voto do min. Gilmar Mendes: “A conjuntura dos fatos processuais leva a uma decisão de prejudicialidade do *writ*, na linha do que proposto pelos ministros que adiantaram voto: Pertence, Peluso e Britto. Não me oponho a essa tese. Sem embargo, quero ressaltar que existe uma questão de inconstitucionalidade posta à apreciação do Tribunal. A União fundamenta seu pedido em argumentos de inconstitucionalidade do Acórdão TCU 2.248/2005, o qual, conforme decidido acertadamente pelo Ministro Eros Grau no MS 25.763/DF, possui caráter normativo abstrato e genérico, análogo ao de uma lei em tese. Assim, tanto naquele caso (MS 25.763) como no presente *writ*, existe, de forma convergente, uma questão de inconstitucionalidade posta à apreciação do Tribunal, independentemente da solução processual a ser tomada, a qual deve ser analisada. Corroborar esse entendimento o fato de que o MS 25.763/DF, impetrado especificamente contra o Acórdão TCU 2.248/2005, ainda não transitou em julgado e também está em julgamento nesta Corte. É certo, portanto, que a questão da inconstitucionalidade do Acórdão TCU 2.248/2005 também poderá ser apreciada naquele *writ*, mas as duas decisões deverão ser congruentes e harmônicas. A jurisprudência do Tribunal firmou-se no sentido de que, posta uma questão de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo da qual dependa o julgamento da causa, a Corte não pode se furtar ao seu exame (RE 102.553, 21-8-1986, rel. Rezek, DJ de 13-2-1987; MS 20.505/DF, rel. Néri da Silveira, DJ de 8-11-1991; SE 5.206 AgR, 8-5-1997, rel. Sepúlveda Pertence, RTJ 190/908; Inq 1.915, 5-8-2004, rel. Sepúlveda Pertence, DJ de 5-8-2004; MS 24.875/DF, rel. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 6-10-2006; RE 420.816/PR, rel. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 10-11-2006; RE 309.452/RJ, Gilmar Mendes, DJ de 25-8-2004). Ainda que se declare prejudicado o julgamento da ação, deve o Tribunal se pronunciar sobre a questão de inconstitucionalidade suscitada *incidenter tantum*. Não fosse assim, ter-se-ia um excessivo formalismo do processo constitucional, com sérios prejuízos para a eficácia de decisões desta Suprema Corte, e, por que não dizer, para o próprio sistema jurídico, com a possibilidade de se produzirem decisões incongruentes e uma inaceitável dúvida sobre tema já resolvido por esta Corte. Esse entendimento concretiza a atividade precípua do Supremo Tribunal Federal de guarda da Constituição, como já afirmado no julgamento do MS 24.875/DF, rel. min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ de 6-10-2006. (...) Ora, se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, é certo que a interpretação do texto constitucional por ele fixada deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, em decorrência do efeito definitivo outorgado à sua decisão. Não se pode diminuir a eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal com a manutenção de decisões divergentes. Contrariamente, a manutenção de soluções divergentes, em instâncias inferiores, sobre o mesmo tema, provocaria, além da desconsideração do próprio conteúdo da decisão desta Corte, última intérprete do texto constitucional, o enfraquecimento da força normativa da Constituição. De toda forma, tenho como certo que, posta a questão constitucional, não pode esta Corte deixar de apreciá-la, ainda que tenha de julgar prejudicada a ação. Essa é a proposta que faço ao Tribunal, no sentido de enfrentarmos a questão constitucional suscitada neste processo, ainda que depois tenhamos de extinguir o mandado de segurança.”
- 3 Lei 9.527/1997: “Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994.”

- 4 MP 2.225-45/2001: “Art. 3º Fica acrescido à Lei n. 8.112, de 1990, o art. 62-A, com a seguinte redação: Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei n. 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei n. 9.624, de 2 de abril de 1998. Parágrafo único. A VPNI de que trata o *caput* deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.”
- 5 Lei 8.911/1994: “Art. 3º Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor investido em função de direção, chefia e assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos. (Revogado pela Lei n. 9.527, de 10-12-1997) § 1º Entende-se como gratificação a ser incorporada à remuneração do servidor a parcela referente à representação e a gratificação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar de cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento dos Grupos: Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Cargo de Direção – CD. (Revogado pela Lei n. 9.527, de 10-12-1997) § 2º Quando se tratar de gratificação correspondente às funções de direção, chefia e assessoramento do Grupo – FG e GR, a parcela a ser incorporada incidirá sobre o total desta remuneração. (Revogado pela Lei n. 9.527, de 10-12-1997) § 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento houver sido exercidos no período de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cálculo a exercida por maior tempo. § 4º Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento de nível mais elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. (Revogado pela Lei n. 9.527, de 10-12-1997).”
- 6 Lei 9.624/1998: “Art. 3º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro de 1995 e a data de publicação desta Lei, mas não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes, observados os critérios: I – estabelecidos na Lei n. 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles servidores que completaram o interstício entre 19 de janeiro de 1995 e 28 de fevereiro de 1995; II – estabelecidos pela Lei n. 8.911, de 1994, com a redação dada por esta Lei, para o cálculo dos décimos, para os servidores que completaram o interstício entre 1º de março e 26 de outubro de 1995. Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir de 27 de outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei n. 8.911, de 1994, com a redação dada por esta Lei, com efeitos financeiros a partir da data em que completou o interstício.”
- 7 Esse entendimento, equivocadamente adotado por alguns órgãos públicos, teria lastreado a concessão das parcelas em exame.

- » Agentes públicos
- » Sistema remuneratório
- » Irredutibilidade de vencimentos

É vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito de ato administrativo.

O mérito do ato administrativo trata de “matéria submetida a critérios de conveniência e oportunidade”¹.

Aumento de vencimento legalmente concedido, com data predeterminada para início de eficácia, caracteriza aquisição de direito.

Posta a norma que conferiu aumentos dos valores remuneratórios, não se há cogitar de expectativa, mas de direito que não mais poderia vir a ser reduzido pelo legislador. A diminuição dos valores legalmente estatuídos configura redução de vencimentos, em sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser obedecida.²

Assim, aumento salarial legalmente concedido – e já incorporado ao patrimônio dos servidores, tendo prazo inicial definido para sua eficácia financeira – recai no termo pré-fixo a que se refere o § 2º do art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, que caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República.

¹ RMS 23.543, rel. min. Ilmar Galvão, 1ª T.

² RE 298.694, rel. min. Sepúlveda Pertence, P.

Ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, art. 37, XV).

Embora inexistir direito adquirido em relação à mudança de regime jurídico – razão pela qual não há ilicitude no decreto que eleva a jornada de trabalho –, é impositivo respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, o citado decreto não é aplicável aos servidores que, antes de sua edição, estavam legitimamente subordinados a carga horária inferior a 40 horas semanais, cabendo a utilização da técnica de declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do dispositivo impugnado.

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Isonomia

“O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.”

Com esse teor, o Plenário aprovou o Enunciado 51 da Súmula Vinculante. Assim, o conteúdo do Verbete 672 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, de mesma redação, tornou-se vinculante.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia¹, tampouco proceder à equiparação salarial entre servidores de mesmo cargo, quando o paradigma decorrer de decisão judicial transitada em julgado.

O aumento de vencimentos de servidores depende de lei² e não pode ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia. Nesse sentido, igualmente, não compete ao Judiciário estender gratificação de gestão especificamente destinada a servidores em exercício em determinada secretaria quando cedidos a outro órgão.

- 1** Enunciado 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
- 2** Constituição Federal/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Isonomia

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Com esse teor, o Plenário aprovou a edição do Enunciado 37 da Súmula Vinculante, tornando, assim, vinculante o Verbete 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, de mesma redação.

As vantagens remuneratórias de caráter geral conferidas a servidores públicos, por serem genéricas, são extensíveis a inativos e pensionistas, quando o servidor tiver preenchido os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito antes da Emenda Constitucional (EC) 41/2003.

A EC 20/1998, ao incluir no art. 40 da Constituição o § 8º, entre outras disposições, assegurou que os proventos de aposentadoria e as pensões seriam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade. Ademais, também previu que seriam estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

Entretanto, a EC 41/2003 deu nova redação ao dispositivo para apenas assegurar o reajustamento dos benefícios e preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Assim, ante a diversidade de situações formadas pelo advento desses regimes jurídicos, foram fixadas as teses do julgado, para que gerem efeitos *erga omnes* e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos:

I – as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas;

II – nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das EC 20/1998 e EC 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes do advento da EC 41/2003;

III – com relação àqueles servidores que se aposentaram após a edição da EC 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos

e inativos contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda;

IV – por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003, conforme decidido nos autos do RE 590.260/SP (Plenário, rel. min. Ricardo Lewandowski, *DJE* de 23-10-2014).

Os servidores aposentados e os pensionistas do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)¹ fazem jus, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (CF) – com a redação dada pela Emenda Constitucional (EC) 20/1998² –, à paridade remuneratória em relação aos servidores ativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), uma vez que a criação deste órgão decorreu da extinção daquele.

O art. 40, § 8º, da CF, com a redação dada pela EC 20/1998, ao estatuir a regra de paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos que tenham exercido cargos correspondentes, dispensa a edição de lei que promova a extensão das vantagens³, haja vista que o próprio texto constitucional, à luz do princípio da isonomia, estabelece essa extensão.

Nesse sentido, tendo em conta a autoaplicabilidade do preceito constitucional em comento, aos aposentados e pensionistas do DNER é assegurado o direito à paridade, desde que se verifique que eles gozariam dos benefícios caso estivessem em atividade no DNIT.

1 DNER: órgão extinto por ocasião da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001.

2 A EC 20/1998 incluiu no art. 40 da Constituição o § 8º, segundo o qual, entre outras disposições, foram estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se tenha dado a aposentadoria ou que tenha servido de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

3 RE 214.724, rel. min. Sepúlveda Pertence, 1ª T; AI 802.545 AgR, rel. min. Ayres Britto, 2ª T; RE 601.225 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T.

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e das vantagens pecuniárias.

O servidor público, em face do princípio da publicidade administrativa, não detém a mesma proteção destinada à intimidade e à vida privada de que goza o cidadão comum.

A Corte reiterou entendimento no sentido de que a “remuneração bruta, cargos e funções por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, à divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade.

(...) Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo ‘nessa qualidade’ (§ 6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano.

(...) A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicaneamente administrado. O ‘como’ se administra a coisa pública

a preponderar sobre o ‘quem’ administra (...) e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da nossa República.

(...) A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de grave lesão à ordem pública.”¹

Desse modo, não gera indenização por danos morais a publicação de nome de servidor em sítio eletrônico de entidade da Administração Pública, no qual são divulgadas informações sobre a remuneração paga a seus servidores.

¹ Trecho da ementa da SS 3.902 AgR-segundo, rel. min. Ayres Britto, P.

- » Agentes públicos
- » Sistema remuneratório
- » Publicidade administrativa

As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública. Não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem o sigilo, o Senado Federal deve disponibilizar acesso a informações e documentos referentes à concessão de verbas a senadores da República.¹

A total transparência no acesso a documentos públicos é a regra geral do Estado Republicano, sendo o sigilo a exceção.² Nesse sentido, os órgãos estatais têm o dever de esclarecer ao seu mandante, titular do poder político, como são usadas as verbas arrecadadas da sociedade para o exercício de suas atividades.³

O ônus argumentativo de demonstrar a caracterização das hipóteses que permitem afastar a regra geral da publicidade⁴ incumbe a quem pretenda afastá-la, uma vez que se trata de situações excepcionais.

Eventual necessidade de sigilo não pode ser invocada de forma genérica; deve, com efeito, ser concretamente justificada.

No caso do Senado Federal, as atividades ordinárias de seus membros estão longe de demandar um caráter predominantemente sigiloso, visto que é um órgão de representação popular por excelência. É de se exigir, portanto, a devida publicidade.

Ademais, não é pertinente invocar a intimidade, de forma genérica, para restringir a transparência acerca do emprego de verbas públicas exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar. Afinal, não há divulgação, pelo poder público, da forma como os senadores gastam o subsídio recebido a título de remuneração ou do emprego de outras rendas privadas auferidas a título diverso.

¹ Em preliminar, reconheceu-se a legitimidade ativa de veículo de imprensa, por considerar haver direito líquido e certo à obtenção desses elementos, com base no princípio da publicidade [Constituição Federal (CF), art. 37, *caput*] e em outras disposições constitucionais correlatas, notadamente a liberdade de informação jornalística (CF, art. 220, § 1º).

- 2 CF/1988, arts. 1º, *caput* e parágrafo único; 5º, XXXIII; 37, *caput* e § 3º, II; e 216, § 2º; bem como Lei 12.527/2011, art. 3º, I.
- 3 No caso, as referidas verbas destinam-se a indenizar despesas direta e exclusivamente relacionadas ao exercício da função parlamentar.
- 4 Segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5º, XXXIII, parte final) e inviolabilidade conferida à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (CF, art. 5º, X, c/ c art. 37, § 3º, II).

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Reajuste

A decisão judicial que considera procedente o pedido de incorporação de reajuste de 13,23%, indistintamente, a servidor público federal afronta o Enunciado 37 da Súmula Vinculante¹.

As Leis 10.697/2003 e 10.698/2003 tratam de diferentes aspectos da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais. A Lei 10.697/2003 concedeu reajuste de 1% nas remunerações e subsídios. A Lei 10.698/2003, por sua vez, instituiu Vantagem Pecuniária Individual (VPI), devida aos servidores públicos federais ocupantes de cargos efetivos ou empregos públicos, fixada em valor absoluto. São parcelas distintas.

A instituição de VPI em valor absoluto supostamente representaria aumento linear que beneficiaria em maior proporção os servidores públicos federais com remunerações mais baixas. Com o objetivo de corrigir essa alegada distorção, esse valor fixo pode ser interpretado judicialmente como um percentual relativo à menor remuneração de servidor público federal na data de promulgação da lei (13,23%). Assim, o reajuste de 1% (Lei 10.697/2003), somado à VPI (Lei 10.698/2003), é transformado, por decisão judicial, em um reajuste de 13,23% e aplicado em benefício de parte interessada, desde que receba remuneração mais elevada.

Esse reajuste de 13,23%, todavia, não tem fundamento na Lei 10.698/2003, de modo que o Judiciário, ao concedê-lo, com base no princípio da isonomia, atua como legislador positivo.

A superveniência da Lei 13.317/2016, que incorporou a VPI à remuneração dos servidores federais, não altera essa conclusão. A norma limitou-se a determinar que a VPI e outras parcelas remuneratórias dela originadas, deferidas por decisão administrativa ou judicial, fossem absorvidas por aumentos de vencimento então concedidos.²

¹ Enunciado 37 da Súmula Vinculante: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

² Fundamentos extraídos do voto do min. Roberto Barroso no presente julgamento.

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Reajuste

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

Com esse teor, o Plenário aprovou a edição do Enunciado 42 da Súmula Vinculante. Tornou, assim, vinculante o Verbete 681 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, de mesma redação.

- » Agentes públicos
- » Sistema remuneratório
- » Revisão geral anual

As vantagens instituídas pelas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003 não têm natureza de revisão geral anual, destinada a revisar, de forma ampla e irrestrita, a remuneração dos servidores públicos federais civis.

O art. 37, X, da Constituição Federal (CF)¹ exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos.

Nesse sentido, a decisão de órgão fracionário que, a pretexto de compreender ter havido a concessão de revisão geral e anual, deixou de observar o comando normativo do art. 1º da Lei 10.698/2003², incide na proibição do Enunciado 37 da Súmula Vinculante³, configurando caso clássico de inconstitucionalidade por omissão parcial.^{4 e 5}

¹ CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

² Lei 10.698/2003: “Art. 1º Fica instituída, a partir de 1º de maio de 2003, vantagem pecuniária individual devida aos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, ocupantes de cargos efetivos ou empregos públicos, no valor de R\$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).”

³ Enunciado 37 da Súmula Vinculante: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

⁴ “Abstraídos os casos de omissão absoluta do legislador, que devem tornar-se cada vez mais raros, trata-se, na maioria das hipóteses, de omissão parcial do legislador, isto é, de uma lacuna da lei ou, especialmente, de uma exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360.)

⁵ “Embora na doutrina os casos de exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade sejam considerados exemplos típicos de lacuna da lei [Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 5. ed., Berlin–Heidelberg–New York, 1983, p. 359; Claus-Wilhelm Canaris, *Die Feststellung*

von Lucken im Gesetz, Berlin, 1964, p. 81; Friedrich Julicher, *Die Verfassungsbeschwerde gegen Urteile bei gesetzgeberischem Unterlassen*, Berlin, 1972, p. 29; Hartmut Maurer, Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen, in *Festschrift für Werner Weber*, Berlin, 1974, p. 345 (352)], vem-se ressaltando, há algum tempo, que, nessas hipóteses, tem-se uma relação normativa inconstitucional (*Verfassungswidrige Normrelation*) (Jörn Ipsen, *Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt*, Baden-Baden, 1980, p. 214). Entre nós, ver ação direta de inconstitucionalidade por omissão proposta pelo Procurador-Geral da República relativa à Lei n. 7.719, de 6-1-1989 (ADI 799, rel. min. Néri da Silveira), na qual se afirma possível afronta ao art. 39, § 1º, da Constituição.” (Idem, ibidem, p. 1360.)

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Teto remuneratório – **Repercussão Geral**

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal (CF)¹ pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.

A regra do teto constitucional expressa duplo objetivo. De um lado, há nítido intuito ético, de modo a impedir a consolidação de “supersalários”, incompatíveis com o princípio republicano, indissociável do regime remuneratório dos cargos públicos, no que veda a apropriação ilimitada e individualizada de recursos escassos. De outro, é evidente a finalidade protetiva do erário, visando estancar o dispêndio indevido de verbas públicas. Nessa medida, o teto remuneratório previsto no texto constitucional, quando devidamente observado, bem como aliado aos limites globais com despesas de pessoal, assume a relevante função de obstar gastos inconciliáveis com a prudência no emprego dos recursos da coletividade.

Entretanto, a percepção somada de remunerações relativas a cargos acumuláveis, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional.

Por um lado, isso ocorre porque as situações alcançadas pelo art. 37, XI, da Carta Federal são aquelas nas quais o servidor obtém ganhos desproporcionais, observadas as atribuições dos cargos públicos ocupados. Admitida a incidência do limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração.

Por outro lado, há que se observar uma necessária interação entre os incisos XI e XVI do art. 37 do texto constitucional², em observância ao princípio da unidade da Constituição, a demandar esforço interpretativo que não esvazie o sentido da regra que autoriza a acumulação.

Outrossim, a incidência do limitador, tendo em vista o somatório dos ganhos, mesmo que acumuláveis os cargos públicos ocupados, viabiliza retribuição pecuniária inferior

ao que se tem como razoável, consideradas as atribuições específicas dos vínculos e as respectivas remunerações, a ensejar enriquecimento sem causa do poder público.

Não se deve extrair do texto constitucional conclusão a possibilitar tratamento desigual entre servidores públicos que exerçam idênticas funções. O preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o art. 1º da CF, no que evidencia, como fundamento da República, a proteção dos valores sociais do trabalho.

1 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”

2 CF/1988: “Art. 37. (...) XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”

Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal (CF), os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional (EC) 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição de valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

A Constituição, desde sua redação original, já indicava a precedência do limite disposto no art. 37, XI¹, ao delimitar-lhe o âmbito de incidência.

Seguindo a mesma linha², a EC 41/2003³ não violou a garantia da irredutibilidade de vencimentos, modalidade qualificada de direito adquirido, pois o âmbito de incidência da referida garantia (CF, art. 37, XV) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República⁴. Ou seja, ultrapassado o teto, cessa a garantia oferecida pelo art. 37, XV, da CF, que tem sua aplicabilidade vinculada ao montante correspondente.

Nesse sentido, devem ser incluídas nos limites impostos pelo art. 37, XI, da CF, para efeito de observância do teto, quaisquer verbas remuneratórias pagas com recursos públicos. Em outras palavras, deve-se considerar que:

I – se, por um lado, a Constituição assegura a irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos dos exercentes de cargos e empregos públicos;

II – por outro, essa garantia não pode ser estendida aos valores excedentes do teto remuneratório, incluídas as vantagens pessoais.

Assim, a limitação ao teto da despesa efetiva da Administração com a remuneração de uma única pessoa não se confunde com a supressão do respectivo patrimônio jurídico.

Está preservado o direito à percepção progressiva sempre que, majorado o teto, ainda não alcançada a integralidade da verba. Logo, a incorporação de vantagens permanece hígida, e apenas não oponível ao corte exigido pelo imperativo da adequação ao teto.

Dessa forma, é possível afirmar que traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da CF a exclusão da base de incidência do teto remuneratório de valores percebidos a título de vantagens pessoais, ainda que antes do advento da EC 41/2003.

Além de ser necessária a imediata adequação dos vencimentos pagos aos servidores públicos, desde a promulgação da EC 41/2003, ao teto nela previsto para cada esfera do funcionalismo, é igualmente imperioso que o cômputo para cálculo do teto remuneratório alcance as vantagens pessoais para fins de incidência do teto.

O teto estabelecido pela EC 41/2003 tem eficácia imediata, abrange todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Não há falar que a nova redação do art. 37, XI, da CF afronta as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, está dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até 18 de novembro de 2015.

- 1 CF/1988: “Art. 37. (...) XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;” (Redação original.)
- 2 Cabe destacar que a EC 19/1998 apenas tornou mais explícita a opção pelo teto remuneratório como verdadeiro limite de aplicação da garantia da irredutibilidade. Confira-se: “Art. 37. (...) XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela EC 19/1998).”
- 3 CF/1988: “Art. 37. (...) XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;” (Redação atual, dada pela EC 41/2003.)

4 RE 609.381, rel. min. Teori Zavascki, P.

Subtraído o montante que exceder o teto ou o subteto previstos no art. 37, XI, da Constituição Federal (CF)¹, tem-se o valor que serve como base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária.

O termo “remuneração” contido no art. 37, XI, da CF é a designação genérica dada à totalidade de valores pecuniários recebidos pelo servidor, ativo ou inativo, como retribuição pelo exercício de cargo público. Em outras palavras, compreende o valor total previsto para o cargo.

Subsídio, por sua vez, é pago aos agentes políticos e aos membros de Poder em parcela única, valor bruto fixado em lei e sobre o qual ocorre a tributação.

A CF adotou como teto máximo para todos os servidores públicos o subsídio mensal pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesse sentido, o teto constitucional deve incidir sobre o montante integral pago ao servidor, ou seja, sobre sua remuneração bruta. Somente após a aplicação do redutor da remuneração/proventos (conhecido como abate-teto), é que se deduzem o imposto de renda e as contribuições previdenciárias.

Entendimento contrário importaria afronta aos princípios da igualdade – visto que os ministros do STF² pagam imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o valor integral de seus subsídios, no limite estipulado em lei como teto geral constitucional – e da razoabilidade – pela desobediência aos fundamentos do sistema tributário, previdenciário e administrativo na definição e oneração da renda dos que seriam remunerados pelos cofres públicos.

Ademais, a limitação constitucional do valor pago a título de remuneração (CF, art. 37, XI), proventos ou subsídio é também limitação ao poder de tributar, pois o Estado não pode exigir tributo sobre valor que não pode pagar ao servidor público em razão da vedação constitucional.

O mesmo raciocínio se aplicaria à cobrança de contribuição previdenciária, a qual não poderia incidir sobre valor superior ao teto, portanto indevido.

- 1 CF/1988: “Art. 37. (...) XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”
- 2 O art. 37, XI, da CF é taxativo ao determinar que a remuneração e o subsídio de ocupantes de cargos, funções e empregos públicos não podem exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do STF.

- » Agentes públicos
 - » Sistema remuneratório
 - » Teto remuneratório

É inconstitucional lei estadual que estabeleça subteto aplicável aos servidores da Justiça desvinculado do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça.

Em relação ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabelece a seguinte sistemática: (i) possibilidade de definição de um subteto por Poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça [Constituição Federal (CF), art. 37, XI, na redação da Emenda Constitucional (EC) 41/2003¹]; ou (ii) faculdade de definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, para os servidores de qualquer Poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio de deputados e vereadores (CF, art. 37, § 12, conforme redação da EC 47/2005²).

A lei ordinária estadual, tanto por alterar o subteto, que deixaria de corresponder ao valor do subsídio dos desembargadores, quanto por estabelecer um subteto por norma diversa de emenda constitucional, desrespeitou os parâmetros estabelecidos pelo § 12 do art. 37 da CF.

Como a lei impugnada estabelece um subteto inferior e diferenciado apenas para os servidores do Judiciário, há, do ponto de vista material, evidente afronta ao princípio da isonomia.

Dessa forma, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei 11.905/2010 do Estado da Bahia³, que determinam a desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos desembargadores.

1 CF/1988: “Art. 37. (...) XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio

mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”

- 2 CF/1988: “Art. 37. (...) § 12. Para os fins do disposto no inciso XI do *caput* deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.”
- 3 Lei 11.905/2010: “Art. 2º A remuneração dos servidores ocupantes de cargos, funções e empregos públicos no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Art. 3º O subsídio fixado no art. 1º e o valor estabelecido no art. 2º desta Lei somente poderão ser alterados por Lei específica, de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.”

Os valores de remuneração dos servidores públicos que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal (CF) constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

A cláusula da irredutibilidade possui âmbito de incidência vinculado ao próprio conceito de teto de retribuição e opera somente dentro do intervalo remuneratório por ele definido.

Assim, o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional (EC) 41/2003 possui eficácia imediata e submete às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.¹

Nesse sentido, a Constituição condiciona a fruição da garantia de irredutibilidade de vencimentos à observância do teto de retribuição (CF, art. 37, XI), sem deixar dúvida de que o respeito ao teto representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Nem mesmo concepções de estabilidade fundamentadas na cláusula do art. 5º, XXXVI, da CF² justificam excepcionar a imposição do teto de retribuição.

Tendo isso em conta, a irredutibilidade de vencimentos constitui modalidade qualificada de direito adquirido. Todavia, o seu âmbito de incidência exige a presença de pelo menos dois requisitos cumulativos:

- a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira juridicamente ilegítima, ainda que por equívoco da Administração Pública; e
- b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo predefinido pela Constituição. Nesse contexto, a garantia da irredutibilidade, que hoje assiste igualmente a todos os servidores, constitui salvaguarda a

proteger a remuneração de retrações nominais que venham a ser determinadas por meio de lei. Entretanto, o mesmo não ocorre quando a alteração do limite remuneratório for determinada pela reformulação da própria norma constitucional de teto de retribuição.

- 1 Na espécie, servidores estaduais aposentados e pensionistas vinculados ao Poder Executivo local tiveram os rendimentos submetidos a cortes, após a vigência da EC 41/2003, promovidos com o propósito de adequar as remunerações aos subsídios do governador.
- 2 CF/1988: "Art. 5º (...) XXXVI – A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

- » Agentes públicos
- » Sistema remuneratório
- » Verba indenizatória

A vedação à concessão de verbas adicionais ou vantagens pecuniárias contidas na Lei Complementar (LC) 35/1979 não impede o recebimento de verbas de natureza indenizatória previstas em legislação estadual.¹

A proibição do § 2º do art. 65 da LC 35/1979 (Loman)² diz respeito a vantagens pecuniárias e não indenizatórias. Nesse sentido, é válida a previsão de lei estadual que concede aos magistrados o direito de serem ressarcidos pelos cofres públicos em relação a despesas médicas, cirúrgicas e odontológicas realizadas que excedam o custeio coberto pelo Instituto de Previdência do Estado.

1 No caso, o Estado de Mato Grosso insurgiu-se contra ato do Conselho Nacional de Justiça que havia determinado ao Tribunal de Justiça local o fim do ressarcimento de despesas médicas, cirúrgicas e odontológicas de magistrados e pensionistas, benefícios previstos na Lei estadual 4.964/1985.

2 LC 35/1979: “Art. 65. (...) § 2º É vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente Lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados.”

Não é devido aos membros do Ministério Público da União (MPU) o pagamento de auxílio-moradia em razão de promoção com deslocamento.

É juridicamente impossível a criação de nova hipótese de concessão de benefício não prevista em lei.

Os atos administrativos normativos não podem ultrapassar os limites da lei que regulamentam, dispondo acerca de situações não previstas na norma primária de que retiram seu fundamento de validade.

O auxílio-moradia¹ assegura aos membros do MPU o pagamento do benefício apenas quando lotados “em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República [PGR]”.

Consequentemente, a definição – por meio de portaria do procurador-geral da República (PGR) – de que o auxílio em comento seria concedido aos membros do MPU promovidos com deslocamento extrapola os limites do art. 227, VIII, da Lei Complementar (LC) 75/1993.

O dispositivo legal não prevê a possibilidade de que ato do chefe do MPU estabeleça outros casos de concessão do auxílio. Cabe ao PGR apenas a atribuição para definir os locais em que a lotação ensejaria o pagamento do benefício.

¹ LC 75/1993: “Art. 227. Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às seguintes vantagens: (...) VIII – auxílio-moradia, em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República;”

BENS PÚBLICOS

O imóvel residencial administrado pelas Forças Armadas e destinado à ocupação por militares não pode ser alienado.

Incide o óbice do art. 1º, § 2º, I, da Lei 8.025/1990¹. Essa disposição normativa deve ser interpretada no sentido de que todos os imóveis residenciais administrados pelas Forças Armadas, ontologicamente, têm os militares como destinatários.

Mostra-se equivocado entender que os imóveis “destinados à ocupação por militares” devem ser interpretados como “efetivamente ocupados por militares”. Nesse sentido, se eventualmente foram ou estão sendo ocupados por civis, tal circunstância é excepcional e, uma vez desocupados, nada impede sejam utilizados para residência de militares. Ademais, quando a lei obsta a alienação de imóveis residenciais “destinados à ocupação de militares”, impõe a restrição sobre a coisa e não sobre a pessoa. Ou seja, a limitação recai sobre o imóvel e não sobre o militar.

A permissão de compra pelo civil constitui interpretação deturpada da legislação, que culminou no equivocado Enunciado 103 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, o Decreto 99.664/1990 cinge-se a proibir a venda do imóvel a quem quer que seja, porque a restrição não é pessoal. O decreto é silente no que diz respeito à compra por civis e sequer aventa esta possibilidade.

Nesse contexto, a circunstância de um imóvel residencial ser administrado pelas Forças Armadas evidencia função precípua de ser destinado à ocupação de militar, de forma que sua excepcional ocupação por civil não o desafeta ou desnatura.

Ressalte-se ainda que, mesmo estando o bem ocupado por civil, sua destinação legal, qual seja servir de residência a militar, permanece inalterada.

¹ Lei 8.025/1990: “Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a alienar, mediante concorrência pública e com observância do Decreto-Lei n. 2.300, de 21 de novembro de 1986, os imóveis residenciais de propriedade da União situados no Distrito Federal, inclusive os vinculados ou incorporados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB). (...) § 2º Não se incluem na autorização a que se refere este artigo, os seguintes imóveis: I – os residenciais administrados pelas Forças Armadas, destinados à ocupação por militares;”

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- » Contratos administrativos
 - » Execução de contratos
 - » Cláusula exorbitante

A Administração Pública, ao contratar com particulares, pode, unilateralmente, modificar cláusula contratual.

O contrato administrativo possui peculiaridades, e os poderes atribuídos à Administração Pública devem satisfazer as necessidades coletivas, como forma de promoção dos direitos fundamentais.

A possibilidade de alteração unilateral decorre do zelo pelo interesse público, pressuposto essencial do contrato administrativo. Nada obstante, a Administração deve observar os termos da lei e o objeto do procedimento licitatório, bem como a essência do contrato dele proveniente e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993¹.

A responsabilização do poder público não pode ocorrer de maneira genérica ou automática. A imputação da culpa *in vigilando* ou *in elegendo* à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.

A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da contratada a partir de mera presunção. Só é admissível que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.

A Lei 9.032/1995, ao reformar o art. 71 da Lei 8.666/1993, criou um § 2º², dizendo, no § 1º, que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. A Administração Pública já cumpre, no momento da licitação, a observância da aptidão orçamentária e financeira da empresa contratada. A constitucionalidade desse § 1º, declarada na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16³, veda a transferência automática à Administração Pública dos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato de prestação dos serviços.

Com relação à responsabilidade fiscal, inserida no § 2º, há responsabilidade solidária da Administração. Ademais, com o advento da Lei 9.032/1995, o legislador buscou excluir a responsabilidade subsidiária da Administração, no sentido de evitar o descumprimento do disposto no art. 71 da Lei 8.666/1993.

- 1 Lei 8.666/1993: “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela Lei 9.032, de 1995)”
- 2 Lei 8.666/1993: “Art. 71. (...) § 2º A Administração responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei 9.032, de 1995)”
- 3 ADC 16, rel. min. Cezar Peluso, P.

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O TCU tem competência para declarar a inidoneidade de empresa privada para participar de licitações promovidas pela Administração Pública.

O art. 46 da Lei 8.443/1992¹ encontra fundamento de validade nas previsões constitucionais [Constituição Federal (CF), art. 70, parágrafo único², e art. 71, II e VIII³] que autorizam a lei a prever penalidades aplicáveis pelo TCU a pessoas físicas e jurídicas que recebam recursos públicos, independentemente de a natureza ser pública ou privada.⁴

Por outro lado, o âmbito de incidência do citado preceito não se confunde com o art. 87 da Lei das Licitações⁵. Esse dispositivo, que trata de hipótese de inidoneidade por inexecução contratual, dirige-se apenas aos altos cargos do Poder Executivo dos entes federativos (§ 3º) e é restrito ao controle interno da Administração Pública e de aplicação mais abrangente.

Assim, reafirmou-se a jurisprudência da Corte, assentada no julgamento da Pet 3.606 Agr⁶, no sentido da constitucionalidade do art. 46 da Lei 8.443/1992. Tal preceito institui sanção de inidoneidade a particulares por fraude a licitação, aplicável pelo TCU.

1 Lei 8.443/1992: “Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal.”

2 CF/1988: “Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”

3 CF/1988: “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...) II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as

fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (...) VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;”

- 4 No caso, a Corte de Contas aplicou a referida penalidade porque a impetrante fraudou documentos que permitiram a sua habilitação em procedimentos licitatórios.
- 5 Lei 8.666/1993: “Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (...) § 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.”
- 6 Pet 3.606 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, P.

INTERVENÇÃO
DO ESTADO
NA PROPRIEDADE

- » Intervenção do Estado na propriedade
 - » Desapropriação
 - » Interesse social para fins de reforma agrária

Em mandado de segurança, não é possível dilação probatória para dirimir controvérsia fática sobre suposta invasão de área objeto de decreto expropriatório para fins de reforma agrária e o impacto dessa ocupação na produtividade do imóvel rural.

A lide envolve razoável complexidade no plano fático acerca da hipótese de ter ou não ocorrido esbulho possessório ou invasão pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ademais, a discussão sobre a incidência do § 6º do art. 2º da Lei 8.629/1993¹ no caso pressupõe ampla produção de provas, incabível na via eleita.

¹ Lei 8.629/1993: “Art. 2º (...) § 6º O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será visitado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o descumprimento dessas vedações. (Incluído pela Medida Provisória 2.183-56, de 2001)”

- » Intervenção do Estado na propriedade
 - » Desapropriação
 - » Interesse social para fins de reforma agrária

Caracterizada divergência entre as alegações da impetrante e as informações prestadas pela autoridade coatora acerca do quadro fático, cuja superação dependa necessariamente de dilação probatória, é inadmissível a ação de mandado de segurança.

O mandado de segurança, caracterizado pela celeridade e pela impossibilidade de dilação probatória, é via imprópria para a discussão de questões que demandem o revolvimento de fatos e provas.

Nesse sentido, a controvérsia acerca da titularidade da área supostamente ocupada pelo Movimento dos Sem Terra (MST)¹ bem como a ausência de certeza de que o terreno em que foi instalado o acampamento corresponde àquele pertencente ao imóvel desapropriado impedem a utilização do mandado de segurança, tendo em vista a ausência de comprovação do direito líquido e certo.

1 A norma contida no art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/1993 impede que o imóvel particular objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo seja vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação para desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária.

- » Intervenção do Estado na propriedade
 - » Expropriação
 - » Excludentes da culpa – **Repercussão Geral**

A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal (CF)¹ pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que *in vigilando* ou *in eligendo*.

O instituto previsto no art. 243 da CF não se traduz em verdadeira espécie de desapropriação, mas em penalidade ou confisco imposto ao proprietário que praticou a atividade ilícita de cultivar plantas psicotrópicas sem autorização prévia do órgão sanitário do Ministério da Saúde.²

A nova redação, dada pela Emenda Constitucional 81/2014, além de incluir a exploração de trabalho escravo como nova hipótese de cabimento do confisco, suprimiu a previsão de que a expropriação seria imediata e inseriu a observância dos direitos fundamentais previstos no art. 5º da CF, no que couber.

Ademais, a CF em nenhum momento menciona a participação do proprietário no cultivo ilícito para ensejar a sanção. Porém, não se pode negar que a medida é sancionatória, exigindo-se algum grau de culpa para sua caracterização.

A nova redação do art. 243 da CF aclarou a necessidade de observância de nexos mínimo de imputação da atividade ilícita ao atingido pela sanção. A responsabilidade do proprietário, embora subjetiva, é bastante próxima da objetiva.

Se o proprietário agiu com culpa, mesmo não tendo participado diretamente, deverá ser expropriado. A função social da propriedade gera para o proprietário o dever de zelar pelo uso lícito do seu imóvel, ainda que não esteja na posse direta.

Porém esse dever não é ilimitado. Somente se pode exigir do proprietário que evite o ilícito quando isso estiver razoavelmente ao seu alcance. O proprietário pode, portanto, afastar sua responsabilidade, demonstrando que não incorreu em culpa. Pode provar que foi esbulhado, ou até enganado por possuidor ou detentor.

Por fim, em caso de condomínio, havendo boa-fé de apenas alguns dos proprietários, a sanção deve ser aplicada. Restará ao proprietário inocente buscar reparação dos demais.

- 1 CF/1988: “Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”
- 2 GASPARINI, Diógenes. *Direito Administrativo*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 202.

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatórios.

O art. 100 da Constituição Federal (CF)¹, que cuida do sistema de precatórios, diz respeito a pagamentos a serem feitos não pelos conselhos, mas pelas Fazendas Públicas.

Os conselhos de fiscalização profissionais são autarquias especiais, possuem personalidade jurídica de direito público e estão submetidos às regras constitucionais, tais como a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União e a submissão ao sistema de concurso público para arregimentação de pessoal.

Entretanto, esses conselhos não estão submetidos ao Capítulo II do Título VI da CF – que versa sobre finanças públicas (arts. 163 a 169) –, não são órgãos dotados de orçamentos e tampouco recebem aportes do Poder Central, que é a União.

Nesse sentido, se não é possível incluir os conselhos no grande todo representado pela Fazenda Pública, não é possível aplicar a eles o art. 100 da CF. Por conseguinte, o débito de conselho fiscalizador profissional não é executável como débito da Fazenda.

1 CF/1988: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”

É incabível aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução prevista no art. 100 da Constituição Federal (CF)¹.

Mostra-se incongruente considerar bens integrantes do patrimônio de empresas públicas, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, como bens públicos, gozando das vantagens decorrentes. Tal óptica subverte a organicidade do Direito ao implementar ao acessório e ao principal regimes jurídicos diversos.

A par desse aspecto, há de ser observada a determinação do art. 173, § 1º, II, da CF², o qual submete a empresa pública ao regime jurídico próprio das empresas privadas, no que incluídos os direitos e as obrigações civis, comerciais, tributárias e trabalhistas.

Ademais, descabe a fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC)³, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.

1 CF/1988: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”

2 CF/1988: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...) II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;”

3 CPC: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

- » Organização da Administração Pública
 - » Administração Indireta
 - » Organizações sociais

O marco legal das organizações sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública.

A finalidade de fomento é posta em prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão. Tal avença viabilizará o direcionamento, pelo poder público, da atuação do particular em consonância com o interesse público, por meio da inserção de metas e de resultados a serem alcançados, sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação.

Tendo em vista essas considerações, a Lei 9.637/1998¹ e o art. 24, XXIV, da Lei 8.666/1993² receberam interpretação conforme à Constituição, ficando assentado que:

O procedimento de qualificação das organizações sociais deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da Constituição Federal (CF)³, e de acordo com os parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei 9.637/1998⁴.

O procedimento de qualificação de entidades consiste em etapa inicial e embrionária para que o título jurídico de “organização social” seja deferido, de modo a permitir que o poder público e o particular colaborem na realização de interesse comum.

A atribuição desse título jurídico configura hipótese de credenciamento, em que não há a contraposição de interesses entre os celebrantes.

Entretanto, em relação à qualificação, a previsão de competência discricionária no art. 2º, II, da Lei 9.637/1998 deve ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, *caput*). Veda-se, assim, qualquer forma de arbitrariedade.

O indeferimento do pedido de qualificação deve ser pautado pela publicidade, transparência e motivação, além de observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei 9.637/1998, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos incisos I a III do dispositivo.

A celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da CF.

O contrato de gestão configura convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam negócio verdadeiramente associativo para o atingimento de objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia.

Assim, ante a falta de feição comutativa e de intuito lucrativo, características do núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, não incide o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI) pela própria natureza jurídica do ato.

Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada exclua, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o poder público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público, impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, *caput*).

As hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) devem ser conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da CF.

As dispensas de licitação instituídas no art. 24, XXIV, da Lei 8.666/1993 e no art. 12, § 3º, da Lei 9.637/1998 têm a finalidade que a doutrina contemporânea denomina de função regulatória da licitação. Assim, a licitação passa a ser vista como mecanismo de indução de determinadas práticas sociais benéficas, fomentando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e

que por isso sejam reconhecidamente colaboradoras do poder público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais.

O afastamento do certame licitatório, no entanto, não exime o administrador público da observância dos princípios constitucionais. Em consequência, a contratação direta deve se pautar por critérios objetivos e impessoais, com respeito à publicidade, de forma a permitir o acesso de todos os interessados.

Os contratos a serem celebrados pela organização social com terceiros, envolvendo recursos públicos, devem ser conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal. É necessário observar os princípios do *caput* do art. 37 da CF e os termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade.

As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública. Por essa razão, não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar. Isso consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela lei.

No entanto, o regime jurídico de tais entidades deve ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, *caput*), em especial, o princípio da impessoalidade, haja vista o recebimento de recursos, de bens e de servidores públicos. Dessa forma, as contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei 9.637/1998, art. 4º, VIII), no qual fixadas regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.

A seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da CF e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade.

Os empregados das organizações sociais não são servidores públicos. Trata-se de empregados privados e, por isso, sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente.

Também não se aplica às organizações sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II). Contudo, a seleção de pessoal, tal como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática por meio de procedimento objetivo e impessoal.

Além disso, não há violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem. É desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo.

Afastam-se quaisquer interpretações que restrinjam o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), da aplicação de verbas públicas.

O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo TCU (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts. 127 e seguintes) não é restringido pelo art. 4º, *caput*, da Lei 9.637/1998, porque relativo à estruturação interna da organização social, nem pelo art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos responsáveis pela fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos constitucionais.

A previsão de percentual de representantes do poder público no conselho de administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII e XVIII, da CF, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor.

A intervenção na estrutura da entidade é condicionada e instituída no benefício da própria organização, que apenas se submeterá a ela se assim o desejar. Se não for do interesse de associações e fundações receber os benefícios decorrentes do contrato de gestão, não há qualquer obrigatoriedade de submissão às exigências formais da lei.

- 1 Lei 9.637/1998: “Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências.”
- 2 Lei 8.666/1993: “Art. 24. É dispensável a licitação: (...) XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.”
- 3 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoal-

lidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)”

- 4 Lei 9.637/1998: “Art. 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização – PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas atividades referidas no art. 1º, por organizações sociais, qualificadas na forma desta Lei, observadas as seguintes diretrizes: I – ênfase no atendimento do cidadão-cliente; II – ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados; III – controle social das ações de forma transparente.”

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.¹

Ao atuar nessas condições, a sociedade de economia mista “presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do Estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal”².

Permitir ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do Estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, poderia significar retardo ou descontinuidade de políticas públicas ou, ainda, desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos.³

Por consequência, o uso indiscriminado desses procedimentos, além de desvirtuar a vontade do legislador estadual e violar os princípios constitucionais da atividade financeira estatal, em especial o da legalidade orçamentária [Constituição Federal (CF), art. 167, IV⁴], constituiria interferência indevida, em ofensa aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (CF, art. 2º⁵).

¹ RE 225.011, red. p/ o ac. min. Maurício Corrêa, P; RE 393.032 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T; e RE 852.527 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T.

² RE 852.302 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T.

³ ADPF 114 MC, rel. min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática.

⁴ CF/1988: “Art. 167. São vedados: (...) IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;”

⁵ CF/1988: “Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”

As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório.¹

Ao agir nessas condições, a pessoa jurídica estatal presta serviço público primário e em regime de exclusividade. Além disso, não visa à obtenção de lucro e detém capital social majoritariamente estatal.^{2 a 4}

Assim, pelo fato de a realização de suas atividades corresponderem à própria atuação do Estado, faz jus ao processamento da execução por meio de precatório.

1 “Financeiro. Sociedade de economia mista. Pagamento de valores por força de decisão judicial. Inaplicabilidade do regime de precatório. Art. 100 da Constituição. Constitucional e processual civil. Matéria constitucional cuja repercussão geral foi reconhecida. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 599.628, red. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, P.)

2 “Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial: aplicabilidade do regime de precatório. Julgado recorrido divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal. Agravo e recurso extraordinário providos. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 698.357 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T.)

3 “Agravos regimentais. Financeiro. Execução de sentenças transitadas em julgado. Entidade controlada pelo poder público que executa serviços públicos primários e essenciais. Falta de comprovação do acúmulo ou da distribuição de lucros. Regime de precatório. Aplicabilidade. Art. 100 da Constituição. O Pleno assentou que as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros submetem-se ao regime de execução comum às empresas controladas pelo setor privado (RE 599.628, rel. orig. min. Carlos Britto, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 25-5-2011). Porém, trata-se de entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo

primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 592.004 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T.)

- 4 “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Exercício de atividade pública essencial. Submissão ao regime de precatórios. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 848.867 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T.)

PODERES ADMINISTRATIVOS

É constitucional atribuir o exercício do poder de polícia de trânsito às guardas municipais, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa ocorrer de modo ostensivo, constitui mero exercício de poder de polícia.

Essa atividade não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais. Não se confunde, portanto, com a promoção da segurança pública, que é outorgada pela Constituição exclusivamente às entidades policiais.¹

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), observando os parâmetros constitucionais, estabeleceu a competência comum dos entes da Federação para o exercício da fiscalização de trânsito. Assim, dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal.

Ademais, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal (CF) não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. Afinal, até mesmo instituições policiais podem acumular funções típicas de segurança pública com o exercício de poder de polícia. Destaca-se que esse entendimento não foi alterado pela Emenda Constitucional 82/2014².

¹ CF/1988: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I – polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis; V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.”

² CF/1988: “Art. 144. (...) § 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: I – compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e II – compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.”

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- » Princípios da Administração Pública
- » Devido processo legal
- » Cadastros federais de inadimplência

Comprovado que o lançamento do Estado no Cadastro Único de Convênios (Cauc) e no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) ocorreu sem se viabilizar, à exaustão, o direito de defesa, é cabível a suspensão do procedimento.¹

É necessário observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no tocante à inscrição de entes públicos em cadastros federais de inadimplência.²

Com isso, não se mostra apropriado registrar o ente federado na condição de inadimplente se a inscrição nos cadastros federais (de inadimplência) tiver sido feita sem que o autor tenha pleno conhecimento dos elementos necessários à apresentação de defesa.

Por outro lado, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a ação advém tanto por estarem presentes, em polos distintos, Estado-membro e União quanto por estar em jogo a inscrição do ente local em cadastro federal de inadimplência, a impedir a contratação de operações de crédito, a celebração de convênios e o recebimento de transferências de recursos. Dessa forma, a situação revela possível abalo ao pacto federativo, o que enseja a incidência do art. 102, I, f, da Constituição Federal (CF).³

Ademais, embora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) possua personalidade jurídica própria, cabe à União, na qualidade de gestora, proceder à inscrição no Cauc e no Siafi.

¹ No caso, sustentava-se que a União teria feito a inscrição do Estado da Bahia no Cauc e no Siafi por reprovação na prestação de contas alusiva a convênios em que figuravam como partes a Secretaria Estadual de Educação e a União, todos relativos a verbas do FNDE. Alegava-se que, por motivo de força maior, o Estado-membro não tivera possibilidade de encaminhar a documentação necessária à manutenção dos convênios, e que, em virtude dessa pendência, a Secretaria de Educação fora inserida no Cauc, o que supostamente violaria o devido processo legal. Em razão disso, estariam paralisadas as operações de crédito necessárias à continuidade dos programas de educação estaduais.

² Sobre incidência dos direitos fundamentais (processuais) a pessoas jurídicas de direito público: AC 2.032 QO, rel. min. Celso de Mello, P.

- 3 CF/1988: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (...) f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;”

Direito Administrativo

- » Princípios da Administração Pública
 - » Princípio da intranscendência subjetiva das sanções
 - » Gestão pública

AC 2.614 AgR

DJE de 18-11-2015

AC 781 AgR

DJE de 17-8-2015

AC 2.946 AgR

DJE de 13-8-2015

rel. min. **Luiz Fux**

1ª Turma

Informativo STF 791

O princípio da intranscendência subjetiva¹ das sanções inibe a aplicação de sanções severas às administrações por ato de gestão anterior.^{2 e 3}

Não se pode inviabilizar a administração de quem, tendo sido eleito democraticamente, não foi responsável direto pelas dificuldades financeiras que acarretaram a inscrição de Estado-membro no sistema de restrição ao crédito utilizado pela União e está tomando providências para sanar as irregularidades verificadas.

Nesse sentido, o propósito é neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.

Viola o princípio do devido processo legal a inscrição de unidade federativa em cadastro de inadimplentes antes de iniciada e julgada eventual tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União.⁴

A tomada de contas especial é medida de rigor que possibilita o reconhecimento definitivo de irregularidades. Somente após esse procedimento, permite-se a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União.

A imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo poder público, da garantia indisponível do *due process of law*.

Assegurada pela Constituição da República (art. 5º, LIV) à generalidade das pessoas, essa garantia estende-se inclusive às pessoas jurídicas de direito público. Afinal, o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária.⁵

- 1 “O postulado da intranscendência impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator.” (ACO 1.848 AgR, rel. min. Celso de Mello, P.)
- 2 Na espécie, buscava-se a suspensão da condição de inadimplente de Estado-membro, bem como das limitações dela decorrentes, com relação a convênios com a União.
- 3 ACO 1.848 AgR, rel. min. Celso de Mello, P; e ACO 1.612 AgR, rel. min. Celso de Mello, P.
- 4 ACO 2.159 MC-REF, rel. min. Marco Aurélio, 1ª T.
- 5 ACO 2.032 AgR, rel. min. Celso de Mello, P.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

- » Processo administrativo
 - » Anulação, revogação e convalidação
 - » Decadência

A instauração de processo específico de anulação de anistia caracteriza ato impugnável capaz de, por si só, viabilizar impugnação pela via mandamental.

O tema relacionado à revisão das anistias deferidas a militares afastados por motivos políticos pode ser delimitado em, pelo menos, duas fases: **a)** publicação de portaria¹, por meio da qual se determina a realização de amplo procedimento de revisão das portarias declaratórias da condição de anistiado político²; **b)** instauração de processos individuais de reanálise dos atos de anistia, etapa inaugurada por despacho do ministro da Justiça, no sentido da revisão, de ofício, das concessões de anistia, autorizada a abertura de processo de anulação de portaria declaratória da condição de anistiado político.

A mera instauração de processo geral de revisão de anistias, estágio inicial do procedimento de autotutela administrativa, não caracteriza ato lesivo a direito capaz de, por si só, viabilizar a impugnação pela via mandamental.³ No entanto, as balizas são outras quando, ultrapassada a primeira fase procedimental, estrita a estudos preliminares sobre os atos concessivos de anistia, a Administração instaura processo tendente à anulação de portaria de anistia individualizada.

Nessa hipótese, a atuação estatal mostra-se ameaça real, objetiva e iminente à situação jurídica do anistiado. Assim, a cláusula constitucional de acesso ao Judiciário, porquanto assegura ao cidadão tutela contra lesão ou ameaça de lesão a direito, direciona à adequação do mandado de segurança, a fim de assegurar direito líquido e certo do impetrante.

Por fim, em ambas as fases, a ótica central sustentada pelos anistiados é a configuração da decadência da possibilidade de o poder público rever e anular os atos anistiadores. Nesse ponto, caberá à Administração demonstrar, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a não ocorrência, presente o fato de a norma veiculada na parte final do art. 54 da Lei 9.784/1999⁴ constituir exceção à regra que favorece o beneficiário do ato administrativo.

¹ Portaria Interministerial 134/2011 do ministro de Estado da Justiça e do advogado-geral da União.

- 2 Editadas em decorrência dos afastamentos motivados pela Portaria 1.104-GM3/1964, da Força Aérea Brasileira.
- 3 RMS 30.973, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T; e RMS 30.993, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática.
- 4 Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

- » Processo administrativo
 - » Anulação, revogação e convalidação
 - » Decadência

Decorrido o prazo quinquenal, a Administração Pública não pode anular anistia política concedida mesmo que, nesse ínterim, a Advocacia-Geral da União (AGU) tenha emitido nota questionando os critérios adotados na concessão.

O prazo decadencial para a anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999¹, e comporta apenas duas hipóteses de afastamento da decadência administrativa: a) a má-fé do beneficiário; e b) a existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato.

Não se qualificam as notas e os pareceres emanados por membros da AGU como “medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”, nos termos do § 2º do art. 54 da Lei 9.784/1999, em razão da generalidade de suas considerações, bem como do caráter meramente opinativo que têm no caso em tela.

Ademais, em se tratando de competência exclusiva para a concessão, revisão ou revogação de anistia política, somente ato do ministro de Estado da Justiça, na qualidade de autoridade administrativa, tem o condão de, uma vez destinado à impugnação específica de ato anterior, obstaculizar o transcurso do prazo decadencial para sua anulação.

Facultar à União a consideração de pareceres administrativos internos, genéricos, como medidas obstativas do transcurso do prazo decadencial para anulação de atos administrativos, transfere o controle da decadência – cuja aferição tem natureza eminentemente objetiva – ao alvedrio da Administração Pública. Tais pareceres não são prolatados por autoridade com competência para a revisão ou revogação do ato, além de não permitirem interferência da parte interessada em defender o direito questionado. Como resultado, é imposta ao administrado uma posição de insegurança e sujeição contrária ao Estado Democrático de Direito que se pretendeu instaurar a partir da Carta Cidadã.

¹ Lei 9.784/1999: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.”

- » Processo administrativo
 - » Anulação, revogação e convalidação
 - » Decadência

A anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que viabilize a audição daquele que terá a situação jurídica modificada.

A autotutela administrativa não pode afastar o próprio direito de defesa¹, sob pena de nulidade.^{2 e 3}

1 Enunciado 3 da Súmula Vinculante: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assecuram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”

2 MS 24.781, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P.

3 RE 594.296, rel. min. Dias Toffoli, P.

O termo inicial para a formalização de mandado de segurança pressupõe a ciência do impetrante, quando o ato impugnado surgir no âmbito de processo administrativo do qual seja parte.

No tocante aos parâmetros do ato de notificação, a Administração deve seguir o disposto nos arts. 3º¹ e 26² da Lei 9.784/1999. Tais dispositivos asseguram ao interessado tomar ciência da tramitação dos processos administrativos, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, incumbindo ao órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinar a intimação do interessado para o conhecimento da decisão ou a efetivação de diligências.

Ante o quadro normativo, mostra-se despcienda a circunstância de o ato impugnado ter sido publicado no Diário Oficial. Para que haja o curso do prazo de decadência, é indispensável não apenas o que se poderia tomar como intimação ficta, mas contar-se com a ciência inequívoca do titular do direito substancial em jogo.

Instruído o processo com documentos suficientes ao exame da pretensão veiculada na petição inicial, descabe suscitar a inadequação da via mandamental.

Inexiste óbice ao processamento do mandado de segurança quando o exame da pretensão não pressupõe produção de provas, a impetração não é utilizada como substitutiva de ação específica e os documentos trazidos ao processo revelam a existência de ato impugnável passível de análise.

¹ Lei 9.784/1999: “Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: I – ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; II – ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; III – formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente; IV – fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.”

- 2 Lei 9.784/1999: “Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. § 1º A intimação deverá conter: I – identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; II – finalidade da intimação; III – data, hora e local em que deve comparecer; IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; V – informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. § 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. § 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. § 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. § 5º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.”

Direito Administrativo

- » Processo administrativo
 - » Instrução
 - » Providências acauteladoras

RMS 31.973

rel. min. **Cármem Lúcia**

2ª Turma

DJE de 18-6-2014

Informativo STF 737

O pagamento dos denominados “quintos” incorporados aos vencimentos de servidor pode ser suspenso no curso de processo administrativo.

O poder cautelar da Administração, inscrito no art. 45 da Lei 9.784/1999, prevê que, “em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado”.

- » Processo administrativo
- » Recurso administrativo e revisão
- » Nulidades

Em recurso administrativo, é nula decisão proferida por ministro de Estado que, anteriormente, ao ocupar cargo hierarquicamente inferior na mesma estrutura administrativa, tenha indeferido pedido de reconsideração sobre o mesmo objeto.

O recurso administrativo deve ser apreciado por autoridade superior e diferente daquela que decidiu a questão no mesmo processo administrativo, em momento anterior, sob pena de nulidade por afronta aos princípios da impessoalidade, da imparcialidade e do duplo grau de instância administrativa.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Inexiste direito líquido e certo à prorrogação contratual do contrato de concessão de usina hidrelétrica.

É da essência da cláusula de prorrogação contratual a voluntariedade, delineada no âmbito da Administração Pública sob os parâmetros de atendimento ao interesse público, o que se perfaz sob margem de discricionariedade administrativa. Essa natural discricionariedade na realização ou não da prorrogação contratual cede apenas ao interesse público, bem como encontra razão de ser na própria finalidade da licitação.¹

A regra é a contratação ter um termo predefinido – prazo contratual –, cabendo à Administração avaliar, ao final do termo e sempre de acordo com os parâmetros legais de atendimento ao interesse público que lhe foram traçados (e em especial a “promoção do desenvolvimento nacional sustentável”), o interesse e a possibilidade de renovação desse prazo.

Um contrato de concessão de serviços públicos, a teor do art. 175 da Constituição Federal (CF)², firmado a partir de certame licitatório, tem a temporariedade como uma de suas marcas fundamentais. Desse modo, o encerramento do contrato ocorre no prazo nele definido, salvo a realização de ajuste, ao final do termo, pela prorrogação contratual, se atendidas as exigências legais para tanto e se presente o interesse público na permanência do ajuste.

É incongruente com a natureza da prorrogação contratual, portanto, a ideia de sua formalização em momento antecedente ao término do contrato, como também é incoerente com sua natureza a garantia indissolúvel de sua realização já no instrumento contratual.

Prorrogação é instrumento autorizado pela lei, nunca imposto. Sua realização não poderia, em nenhuma hipótese, ser antecipada, máxime ao ato inicial de formalização do contrato. Ela pressupõe atendimento ao interesse público.

Essa regra é ainda mais pertinente quando se trata de contrato de concessão de energia elétrica, em que a prorrogação se estabelece por décadas, a exigir da Administração ainda maior atenção na análise de seu interesse na renovação.

Admitir o raciocínio contrário implicaria imposição de renovação contratual sem margem alguma de discricionariedade administrativa. Seria o mesmo que conceder ao concessionário posição de supremacia sobre a Administração, o que é um contrassenso com os princípios e postulados administrativos. No mesmo passo, seria conferir à cláusula de prorrogação contratual a natureza de verdadeira cláusula exorbitante em favor do concessionário, o que não se coaduna com a natureza desse instituto.

Embora todo contrato administrativo tenha um prazo definido sobre o qual se perfaz o equilíbrio da relação contratual, não há que cogitar de sua incidência na prorrogação contratual, que pode se dar sob novos termos se assim definido em lei.

O princípio do equilíbrio financeiro do contrato, que assegura a equivalência entre as vantagens e os custos tal como calculados no momento da celebração do contrato, se aplica pelo período de vigência do ajuste.

Com efeito, a novel legislação, surgida no curso do contrato, deve respeitar as disposições desse contrato de caráter econômico até seu termo final.³ Entretanto, esse mandamento não é afrontado caso a Administração Pública faça incidir as novas regras apenas para fins de prorrogação do contrato.

Nessa hipótese, o concessionário está livre para aceitar ou não os novos termos contratuais, sem haver, entretanto, violação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato por alteração legal prevista para incidir após o término do prazo de ajuste.

1 “Quando a lei se refere à licitação como forma de garantir a isonomia, encontra-se pressuposta a igualdade de oportunidades e, portanto, a ocorrência periódica de certames, o que define a delimitação temporal dos ajustes firmados com o Estado. De igual modo, ao se referir à vantajosidade, quer a lei ressaltar que o caráter competitivo que é estabelecido pela licitação é salutar ao interesse público, o que, novamente, traduz a intenção da legislação de criar mecanismos de renovação periódica da contratação. Por fim, ao dispor que a licitação tem por finalidade a ‘promoção do desenvolvimento nacional sustentável’, traçou a lei o ideal a ser alcançado com a contratação e, de igual modo, com sua renovação. Trata-se, ressalte-se, de critério volátil, que pode sofrer modificação entre a data de formalização do ajuste e a data de sua eventual prorrogação, o que pode, desse modo, também justificar a opção pela não prorrogação do contrato.” (Trecho do voto do rel. min. Dias Toffoli no presente julgamento.)

2 CF/1988: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II – os direitos dos usuários; III – política tarifária; IV – a obrigação de manter serviço adequado.”

3 ADI 1.746, rel. min. Marco Aurélio, P.

A cobrança de “taxa de alimentação” por instituição federal de ensino profissionalizante é inconstitucional.

A cobrança de anuidade relativa à alimentação – ainda que instituída por lei – afronta o princípio constitucional da gratuidade do ensino público, o qual abarca as garantias de efetivação do dever do Estado com a educação, previsto na Constituição. Nessas garantias, está englobado o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, incluído o nível médio profissionalizante, além do fornecimento de alimentação.

A interpretação conjunta dos arts. 206, IV, e 208, VI, da Constituição Federal revela que programa de alimentação que se apresente oneroso consiste na negativa de adoção do programa.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

- » Responsabilidade civil do Estado
 - » Responsabilidade objetiva
 - » Anistia política – **Repercussão Geral**¹

Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, *caput* e parágrafo único, da Lei 10.559/2002², caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo.

Ao tratar do regime do anistiado político, a Lei 10.559/2002, além de reconhecer a condição de anistiado político, também reconheceu ao beneficiado o direito à reparação econômica de caráter indenizatório, que pode ser paga em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada.

A existência de dotação legal é suficiente para que haja o cumprimento integral da portaria que reconheceu a condição de anistiado político, conforme o art. 12, § 4º, da Lei 10.559/2002.

Demonstrada, portanto, a existência de dotação orçamentária, decorrente de presunção legítima programação financeira pela União, não se visualiza afronta ao princípio da legalidade da despesa pública ou às regras constitucionais que impõem limitações às despesas de pessoal e concessões de vantagens e benefícios pessoais.

Dessa forma, o descumprimento da obrigação de pagamento, “de valor certo e determinado, caracteriza ato omissivo da Administração Pública”³.

Além disso, ao Poder Judiciário não compete a análise de forma detalhada da execução orçamentária para concluir pela suficiência ou insuficiência de recursos para o pagamento das indenizações aos anistiados políticos. Esse exame cabe ao administrador, em momento anterior à publicação da portaria que declara a condição de anistiado político e assegura as reparações econômicas correspondentes.

Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de sessenta dias.

Havendo ação específica para pagamento das reparações econômicas a anistiados políticos civis, bem como destinação da verba em montante expressivo em lei, não se pode acolher a alegação de ausência de previsão orçamentária para atendimento da pretensão.

Ademais, não há que se aplicar o regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a Administração Pública reconhece, administrativamente, que o anistiado possui direito ao valor decorrente da concessão da anistia. A dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de decisão do Poder Judiciário. A discussão cinge-se ao momento do pagamento. O direito líquido e certo do impetrante já foi reconhecido pela portaria específica que declarou sua condição de anistiado, sendo, então, fixado o valor que lhe era devido, de cunho indenizatório. O que se tem, na espécie, é uma obrigação de fazer por parte da União que está sendo descumprida.

Por fim, não se admite o argumento de que o pagamento dos valores levará a uma situação de exaustão orçamentária, pois a inexistência de recursos deve ser real, demonstrada de forma esclarecedora. A exaustão já deve estar presente, ou seja, a indisponibilidade de caixa deve ser situação atual e não mera possibilidade futura.

1 Fixada a seguinte tese de repercussão geral dividida em três pontos: “1) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, *caput* e parágrafo único, da Lei 10.559/2002, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”

2 Lei 10.559/2002: “Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas decisões. (...) § 4º As requisições e decisões proferidas pelo Ministro de Estado da Justiça nos processos de anistia política serão obrigatoriamente cumpridas no prazo de sessenta dias, por todos os órgãos da Administração Pública e quaisquer outras entidades a que estejam dirigidas, ressalvada a disponibilidade orçamentária. (...) Art. 18. Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão efetuar, com referência às anistias concedidas a civis, mediante comunicação do Ministério da Justiça, no prazo de sessenta dias a contar dessa comunicação, o pagamento das reparações econômicas, desde que atendida a ressalva do § 4º do art. 12 desta Lei.”

3 RMS 26.899, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T.

- » Responsabilidade civil do Estado
 - » Responsabilidade objetiva
 - » Ato omissivo – **Repercussão Geral**

O Estado é responsável pela morte de detento em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal (CF)¹.

A execução da pena de forma humanizada é dever do Estado e direito subjetivo do preso. Além disso, devem ser garantidos os direitos fundamentais e a preservação da incolumidade física e moral.

A responsabilidade civil estatal, segundo o art. 37, § 6º, da CF², insere-se na teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, uma vez rejeitada a teoria do risco integral.

É fundamental ressaltar que, embora o Estado também responda de forma objetiva por suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só estará caracterizado quando o poder público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso e não se desincumbir dessa obrigação legal.

No caso, o dever constitucional de proteção ao detento será considerado violado apenas quando for possível atuação estatal que garanta os direitos fundamentais do preso. Esse pressuposto é inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal.

Por essa razão, nas situações em que o Estado não poderia agir para evitar a morte de detento, como é o caso de homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, rompe-se o nexo de causalidade. Afasta-se, assim, a responsabilidade do poder público, sob pena de adoção da teoria do risco integral.

Portanto, a responsabilidade civil estatal fica excluída nas hipóteses em que o poder público comprova causa impeditiva de atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da omissão com o resultado danoso. Ocorre, por exemplo, nos casos em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal. Dessa forma, não se pode exigir que o Estado seja responsabilizado por morte que fatalmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade.

- 1 CF/1988: “Art. 5º (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”
- 2 CF/1988: “Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

- » Responsabilidade civil do Estado
- » Responsabilidade objetiva
- » Dever de indenizar

É inconstitucional lei estadual que imponha ao ente estatal o pagamento de pensão especial a cônjuge de vítima de determinados crimes hediondos praticados por terceiros na respectiva unidade federativa, independentemente de o autor do crime ser ou não agente público.

Os dispositivos legais impugnados impuseram ao Governo do Distrito Federal responsabilidade superior à prevista pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF)¹. O ente seria obrigado a reparar danos causados por terceiros, uma vez que o autor do delito não precisaria ser, necessariamente, agente público.

Além disso, não se pode atribuir caráter assistencial à referida pensão especial, ante à não observância das disposições contidas nos arts. 203 e 204 da CF².

Foi declarada, portanto, a inconstitucionalidade da Lei 842/1994, com redação dada pela Lei 913/1995, e a do art. 2º da Lei 913/1995³, ambas do Distrito Federal. Tais normas dispunham sobre o pagamento de pensão especial a ser concedida pelo Governo do Distrito Federal em benefício dos cônjuges de pessoas vítimas de determinados crimes hediondos, independentemente de o autor do delito ser ou não agente do Estado.

1 CF/1988: “Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

2 CF/1988: “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”; e “Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e

as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.”

- 3 Lei 913/1995 do Distrito Federal: “Art. 2º Para os efeitos desta Lei serão considerados os óbitos ocorridos a partir de 21 de abril de 1960, desde que os pedidos de habilitação da pensão especial observem as condições legais preestabelecidas.”

- » Responsabilidade civil do Estado
 - » Responsabilidade objetiva
 - » Estabelecimentos penitenciários –
Repercussão Geral

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF)¹, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica dos detentos constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional – CF², Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), Lei 9.455/1997 (Lei de Tortura), Lei 12.847/2013 (Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura) – mas também em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil – Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas; Convenção Americana de Direitos Humanos; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas (Resolução 1/2008 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos); Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros.

O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ações e omissões dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da CF. Tal norma é autoaplicável, não sujeita a intermediação legislativa ou administrativa para assegurar o correspondente direito subjetivo à indenização.

Ocorrendo o dano e estabelecido o seu nexos causal com a atuação da Administração ou dos seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. Nesse caso, os recursos financeiros para a satisfação do dever de indenizar, objeto da condenação, serão providos, se for o caso, na forma do art. 100 da Constituição.

O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, sendo seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir os danos que

daí decorrerem. A responsabilidade estatal será objetiva, no que concerne à integridade física e psíquica daqueles que estão sob sua custódia.³

As violações a direitos fundamentais causadoras de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não podem ser relevadas ao argumento de que a indenização não tem o alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências essas de atribuição legislativa e administrativa. Também não é possível invocar subterfúgios teóricos – tais como a separação dos Poderes, a reserva do possível e a natureza coletiva dos danos sofridos – para se afastar a responsabilidade estatal pelas calamitosas condições de carceragem no Brasil.

- 1 CF/1988: “Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
- 2 CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XLVII – não haverá penas: (...) e) cruéis; XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;”
- 3 ARE 662.563 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T; RE 466.322 AgR, 2ª T, rel. min. Eros Grau; e RE 272.839, 2ª T, rel. min. Gilmar Mendes.

- » Responsabilidade civil do Estado
 - » Responsabilidade objetiva
 - » Planos econômicos

A União, na qualidade de contratante, deve observar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e indenizar os prejuízos suportados por companhia aérea em virtude de suposta diminuição do seu patrimônio decorrente de planos econômicos em vigor no período objeto da ação em consequência da política de congelamento tarifário vigente no País.

Os atos administrativos, mesmo os legislativos, se submetem, em um Estado de Direito, aos ditames constitucionais, de forma que o Estado deve ser responsabilizado pela prática de atos lícitos quando deles decorram prejuízos específicos, expressos e demonstrados para os particulares em condições de desigualdade com os demais.

Apesar de toda a sociedade ter sido submetida aos planos econômicos, impuseram-se à recorrente prejuízos especiais, pela sua condição de concessionária de serviço, vinculada às inovações contratuais ditadas pelo poder concedente, sem que pudesse atuar para evitar o colapso econômico-financeiro.

Dessa forma, não é juridicamente aceitável sujeitar determinado grupo de pessoas – funcionários, aposentados, pensionistas e a própria concessionária – às específicas condições com ônus insuportáveis e desigualados dos demais, decorrentes das políticas adotadas, sem contrapartida indenizatória objetiva, para minimizar os prejuízos sofridos, segundo determina a Constituição.¹

¹ RE 422.941, rel. min. Carlos Velloso, 2ª T.

- » Responsabilidade civil do Estado
- » Responsabilidade objetiva
- » Posse em cargo público – **Repercussão Geral**

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

Em regra, não há direito à reparação financeira pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público. O pagamento de indenização referente a período em que não houve prestação de serviços configura, nos termos de precedentes da Corte¹, enriquecimento sem causa.²

Não se pode deixar de reconhecer, no entanto, a possibilidade de que determinadas condutas praticadas pelo Estado na aplicação de concursos públicos possam vir a ocasionar danos materiais passíveis de indenização, notadamente nos casos em que haja inequívoca e manifesta ilegitimidade do comportamento da Administração.³

Dessa forma, nos casos de patente arbitrariedade, de descumprimento de ordens judiciais, de litigância meramente procrastinatória, de má-fé e de outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, será devida a reparação adequada [Constituição Federal (CF), art. 37, § 6º].

1 Nesse sentido: AI 839.459 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T; RE 593.373 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T; AI 840.597 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T; e AI 814.164 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T.

2 Ao proferir voto-vista, o ministro Teori Zavascki, no que concerne ao dever de indenizar, ponderou: “O dever de reparação eventualmente surgido na condução de concursos públicos não pode alcançar todas as hipóteses possíveis de judicialização. Fosse isso verdadeiro, a responsabilidade estatal assumiria elástico desproporcional, tornando os procedimentos seletivos praticamente inadmissíveis, já que a impugnação de qualquer aspecto pode provocar, em tese, o adiamento do seu desfecho e, conseqüentemente, das nomeações. Admitir essa premissa resultaria em considerar possível o nascimento do dever de reparação civil em decorrência de atrasos causados, por exemplo, pela impugnação de cláusulas editalícias de alcance genérico, bem como pelo questionamento de etapas intermediárias da avaliação, como a correção do gabarito de uma determinada questão de prova objetiva.” (Trecho do voto-vista do min. Teori Zavascki no presente julgamento.)

- 3 Casos citados pelo relator em que se reconhece o direito à indenização, em razão de patente arbitrariedade da Administração: RE 188.093, rel. min. Maurício Corrêa, 2ª T; RE 247.349, red. p/ o ac. min. Octavio Gallotti, 2ª T; e RE 194.657, rel. min. Sepúlveda Pertence, P.

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

- » Ressarcimento ao erário
 - » Ação de reparação de danos à Fazenda Pública
 - » Prescrição e decadência – **Repercussão Geral**

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil.¹

A prescritibilidade é fator importante para a segurança e a estabilidade das relações jurídicas e da convivência social. Assim, no direito brasileiro, a prescritibilidade das ações e pretensões é a regra – pode-se até dizer o princípio –, e a imprescritibilidade é a exceção.² Nessa linha de entendimento, merece interpretação restritiva a excepcional hipótese de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição Federal (CF)³. Entendimento diverso levaria a resultados incompatíveis com o sistema.

Se o conceito de ilícito anunciado no § 5º do art. 37 da CF fosse adotado em amplo sentido, toda e qualquer ação ressarcitória movida pelo erário, mesmo as fundadas em ilícitos civis que não decorrem sequer de dolo ou culpa, estaria sob a proteção da imprescritibilidade. A própria execução fiscal seria imprescritível, pois a não satisfação de tributos ou de outras obrigações fiscais, principais ou acessórias, representa comportamento contrário ao direito (ilícito⁴, portanto) e causador de dano. Essa visão tão estremada mostra-se incompatível com uma interpretação sistemática do ordenamento constitucional.

Em síntese, é inadequado embutir na norma de imprescritibilidade (CF, art. 37, § 5º) alcance ilimitado, ou limitado apenas pelo (a) conteúdo material da pretensão a ser exercida, o ressarcimento, ou pela (b) causa remota que deu origem ao desfalque no erário, ato ilícito em sentido amplo.

Por fim, é necessário aplicar o prazo prescricional comum para as ações de indenização por responsabilidade civil em que a Fazenda figure como autora, ao tempo do fato, seja o prazo do art. 177⁵ do Código Civil (CC) de 1916, seja o do art. 206, § 3º, V, do CC/2002⁶, com a possibilidade de aplicação imediata, em razão da regra de transição do art. 2.028⁷.

1 “(...) 3. Nos debates travados na oportunidade do julgamento, ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícitos civis os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio. Por isso mesmo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário: (a) Tema 897 – ‘Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa’; e (b) Tema 899 – ‘Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. Desse modo, se dúvidas ainda houvesse, é evidente que as pretensões de ressarcimento decorrentes de atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa, assim como aquelas fundadas em decisões das Cortes de Contas, não foram abrangidas pela tese fixada no julgado embargado. 4. Por outro lado, o embargante alega ser necessária a fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil. No entanto, a questão constitucional julgada pelo acórdão embargado limitou-se ao debate acerca da abrangência da pretensão ressarcitória decorrente de ilícito de natureza civil pela regra da imprescritibilidade do art. 37, § 5º, da Carta Magna. O que cabia ao STF definir era a prescritibilidade ou não das pretensões de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos civis. Firmado o entendimento de que tal pretensão é prescritível, as controvérsias atinentes ao transcurso do prazo prescricional, inclusive a seu termo inicial, são adstritas à seara infraconstitucional, solucionáveis tão somente à luz da interpretação da legislação ordinária pertinente. Nesse sentido, relativamente a discussões análogas, vejamos: ARE 761.345 ED, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T; ARE 761.293 AgR, rel. min. Marco Aurélio, 1ª T; ARE 686.724 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T; ARE 749.479 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, 2ª T; ARE 725.496 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, 2ª T. 5. No que toca ao pedido de modulação dos efeitos da tese firmada, deve-se reconhecer que, de fato, o Supremo Tribunal Federal havia firmado, no julgamento do MS 26.210 (rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário), que o § 5º do art. 37 da CF/1988 dispunha serem imprescritíveis as pretensões de ressarcimento ao erário. Contudo, esse precedente tratava de processo de tomada de contas especial que tramitava perante o TCU, controvérsia pendente de apreciação no RE 636.886 (de minha relatoria, Tema 899) e não alcançada pela tese fixada pelo acórdão impugnado. De outra monta, a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no julgado embargado, que, conforme já esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado. Com relação a ilícitos civis, portanto, não havia jurisprudência consolidada do STF que afirmasse a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário. Inexistia, assim, expectativa legítima da Administração Pública de exercer a pretensão ressarcitória decorrente de ilícitos civis a qualquer tempo. Por isso, não se constata motivos relevantes de segurança jurídica ou de interesse social hábeis a ensejar a modulação dos efeitos da orientação assentada no aresto embargado.” (Trecho do voto do rel. min. Teori Zavascki no RE 669.069 ED, P.)

- 2 “A prescrição, em princípio, atinge a todas as pretensões e ações, quer se trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou públicos. A imprescritibilidade é excepcional.” (MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado*. 4. ed. São Paulo: RT, 1974. Tomo VI, § 667, p. 127.)
- 3 CF/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”
- 4 “Tudo quanto a lei não permite que se faça, ou é praticado contra o direito, a justiça, os bons costumes, a moral social ou a ordem pública e suscetível de sanção.” (NUNES, Pedro. *Dicionário de tecnologia jurídica*. 12. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1990. p. 478.)
- 5 CC/1916: “Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, as reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”
- 6 CC/2002: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três anos: (...) V – a pretensão de reparação civil;”
- 7 CC/2002: “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

ÍNDICE DE TESES

DIREITO ADMINISTRATIVO

Agentes públicos

Cargos públicos

Anistia

O reingresso, em casos de anistia, aos quadros do Poder Executivo deve observar a situação jurídica originária e não implica necessária submissão ao estatuto dos servidores públicos federais..... 14

Agentes públicos

Cargos públicos

Cargo em comissão – Repercussão Geral

Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal (CF), a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão..... 15

Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, inexistente óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração..... 16

Agentes públicos

Cargos públicos

Cargo em comissão

O cargo em comissão de diretor do Departamento de Gestão da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não privativo de bacharel em Direito, pode ser ocupado por pessoa estranha a esse órgão. 18

Agentes públicos

Cargos públicos

Nepotismo

A incompatibilidade da prática referida no Enunciado 13 da Súmula Vinculante não decorre exclusivamente da existência de relação de parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público. Deriva da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa cuja relação de parentesco possa interferir no processo de seleção. 19

Agentes públicos

Cargos públicos

Nepotismo

Não há vedação para que o servidor público – admitido mediante prévia aprovação em concurso público e ocupante de cargo de provimento efetivo – sirva sob a direção imediata de cônjuge ou parente até segundo grau civil. 21

Agentes públicos

Cargos públicos

Transformação

O concurso público é requisito inafastável de acesso aos cargos públicos. 22

Há situações excepcionais em que a Corte admite a transfiguração de cargos públicos e o consequente aproveitamento dos seus antigos titulares na nova classificação funcional. 22

Agentes públicos

Concurso público

Cláusula de barreira – Repercussão Geral

É constitucional a “cláusula de barreira”, regra que limita o número de candidatos participantes de fase subsequente de concurso, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. 24

Agentes públicos

Concurso público

Cotas

É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.25

Agentes públicos

Concurso público

Criação de novos cargos

A criação de novos cargos, ainda que no prazo de validade do concurso público, não gera direito líquido e certo de nomeação para aqueles aprovados fora do número de vagas do edital, por se tratar de ato discricionário e, portanto, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.28

Agentes públicos

Concurso público

Exame psicotécnico

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”29

Agentes públicos

Concurso público

Ingresso na carreira – Repercussão Geral

Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.30

Agentes públicos

Concurso público

Ingresso na carreira – Repercussão Geral

A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da Constituição Federal (CF), deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público.33

Agentes públicos

Concurso público

Ingresso na carreira

O servidor investido na função de defensor público até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte pode optar pela carreira, independentemente da forma da investidura originária. 35

Agentes públicos

Concurso público

Ingresso na carreira

A expressão “três anos de atividade jurídica” contida no art. 129, § 3º, da Constituição Federal (CF) não se limita a atividade privativa de bacharel em Direito. ... 37

Agentes públicos

Concurso público

Ingresso na carreira

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” .38

Agentes públicos

Concurso público

Ingresso na carreira – Repercussão Geral

Os serviços sociais autônomos não estão sujeitos à observância da regra de concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal (CF), para contratação de seu pessoal. 39

Agentes públicos

Concurso público

Limite etário

O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e em edital de concurso público, deve ser comprovado no momento da inscrição no certame. 41

Agentes públicos

Concurso público

Nomeação – Repercussão Geral

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.42

Agentes públicos

Concurso público

Nomeação

A simples consulta feita ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional às inicialmente previstas em concurso público, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame.43

Agentes públicos

Concurso público

Nomeação – Repercussão Geral

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Ressalvam-se as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.....44

Agentes públicos

Concurso público

Nulidades

Os contratos de emprego firmados pela Administração Pública sem prévio concurso público, embora nulos, geram direitos em relação ao recolhimento e levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).46

Agentes públicos

Concurso público

Nulidades – Repercussão Geral

É nula e sem efeitos jurídicos válidos a contratação de pessoal pela Administração Pública sem observância de prévia aprovação em concurso público, além das hipóteses excepcionadas pela própria Constituição, ressalvados os direitos à percepção dos salários e depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).48

Agentes públicos

Concurso público

Prova de títulos

Em concurso público, reconhece-se violado o princípio da isonomia [Constituição Federal (CF), art. 5º, *caput*] quando é considerado título o mero exercício de cargo ou função pública ou é valorizado excessivamente o desempenho de atividades relacionadas àquelas inerentes aos cargos em disputa no certame. 49

Agentes públicos

Concurso público

Prova de títulos

As provas de títulos em concurso para provimento de cargos públicos efetivos na Administração Pública, em qualquer um dos Poderes e em qualquer nível federativo, não podem ostentar natureza eliminatória, uma vez que sua finalidade é, unicamente, classificar os candidatos, sem jamais justificar a eliminação do certame.50

Agentes públicos

Concurso público

Regramento jurídico

Não compete ao Conselho Nacional de Justiça examinar o conteúdo de questões formuladas em provas de concursos públicos nem avaliar seus critérios de correção. 51

A ausência de oportunidade de manifestação dos interessados na apuração de supostas irregularidades de concurso público, em sede de controle administrativo, viola o devido processo legal.51

Não é possível anular concurso público com base em mera presunção de favorcimento a candidatos por parte da banca examinadora.52

Agentes públicos

Concurso público

Regramento jurídico

As novas resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não se aplicam a concursos em andamento.53

Agentes públicos

Concurso público

Regramento jurídico

A estabilidade excepcional, prevista pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não dá direito à efetividade ou a qualquer tipo de transposição, tampouco permite que o servidor integre a carreira sem a prévia aprovação em concurso público.54

Agentes públicos

Concurso público

Regramento jurídico

Eventual desrespeito ao que disciplinado pelo edital consubstancia violação ao princípio da legalidade e autoriza o prejudicado a buscar a correção.56

Agentes públicos

Concurso público

Regramento jurídico

Não é obrigatória a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no âmbito da atuação revisional do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça no tocante à legalidade do resultado da prova preambular de concurso público para ingresso na carreira de promotor de justiça.57

Agentes públicos

Concurso público

Revisão judicial das provas – Repercussão Geral

Os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.58

Agentes públicos

Concurso público

Revisão judicial das provas

Questões de prova objetiva que apresentem sequência de proposições a serem analisadas individualmente quanto à correção, para posterior marcação no gabarito de uma única alternativa, indicando a somatória correta das que seriam verdadeiras ou falsas, não violam as normas regentes do concurso público. Segundo tais regras, a prova preambular seria de múltipla escolha, constando de questões objetivas, de pronta resposta e apuração padronizada, com a finalidade de selecionar os candidatos a serem admitidos para as provas subsequentes. 59

É cabível mandado de segurança quando deduzida pretensão relativa ao estrito controle de legalidade acerca da forma redacional de questões de concurso, sob o parâmetro das normas regulamentares incidentes.59

Agentes públicos

Concurso público

Serventias extrajudiciais

É ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta.....61

Agentes públicos

Concurso público

Serventias extrajudiciais

As serventias extrajudiciais vagas, embora *sub judice*, devem ser incluídas no edital de concurso para ingresso/remoção referente à atividade notarial e de registro.63

A administração do Tribunal de Justiça deve incluir no edital do concurso público a advertência acerca da condição *sub judice* da delegação ofertada no certame.63

A entrega da serventia ao aprovado no certame depende do encerramento de todos os processos alusivos à referida delegação.63

Agentes públicos

Concurso público

Serventias extrajudiciais

A partir da promulgação da Constituição Federal (CF) (5-10-1988), o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em caso de remoção, observado, nessa última hipótese, o disposto no art. 16 da Lei 8.935/1994, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002.....65

Agentes públicos

Concurso público

Serventias extrajudiciais

Não se aplica o Estatuto do Idoso como critério de desempate em concurso público de remoção para outorga de delegação notarial e de registro, quando a lei estadual específica reguladora do certame fixa as regras em caso de empate.67

Agentes públicos

Concurso público

Serventias extrajudiciais

Incumbe ao presidente do Tribunal de Justiça da respectiva unidade da Federação declarar a vacância de serventia extrajudicial.69

É nula de pleno direito a investidura para o exercício dos serviços notariais e de registro que viola a regra do concurso público [Constituição Federal (CF), art. 37, II], após o advento da Constituição vigente.69

Agentes públicos

Concurso público

Serventias extrajudiciais

Tendo em vista que os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas, inexistente direito adquirido à efetivação na titularidade de cartório quando a vacância do cargo ocorrer na vigência da Constituição Federal (CF) de 1988.71

O provimento de serventia extrajudicial sem a observância de concurso público não enseja o transcurso do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999.71

Agentes públicos

Concurso público

Teoria do fato consumado

É possível a aplicação excepcional da teoria do fato consumado, pela consolidação de uma situação fática em face do decurso do tempo, quando há a concessão de aposentadoria voluntária pela Administração Pública ao servidor que tomou posse e entrou em exercício em cargo público em decorrência de decisão judicial tomada à base de cognição não exauriente.72

Agentes públicos

Concurso público

Teoria do fato consumado

Não se aplica a teoria do fato consumado ao candidato que toma posse em cargo público por força de decisão judicial precária.74

Agentes públicos

Concurso público

Teoria do fato consumado – Repercussão Geral

É incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tenha tomado posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.75

Agentes públicos

Contratação temporária

Competência judicial

A Justiça comum é competente para processar e julgar causas em que se discuta a validade de vínculo entre o poder público e servidores temporários.....76

Agentes públicos

Contratação temporária

Regramento jurídico

São inconstitucionais a autorização legislativa genérica para contratação temporária e a permissão de prorrogação indefinida do prazo de contratações temporárias.78

Agentes públicos

Contratação temporária

Regramento jurídico – Repercussão Geral

É compatível com a Constituição Federal (CF) a previsão legal que exija o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.79

Agentes públicos

Contratação temporária

Regramento jurídico

São inconstitucionais dispositivos de lei estadual de iniciativa parlamentar que asseguraram a permanência dos servidores públicos admitidos em caráter temporário sem a prévia aprovação em concurso público.....81

Agentes públicos

Contratação temporária

Regramento jurídico

As hipóteses genéricas de contratação temporária de profissionais de magistério previstas em lei complementar estadual são inconstitucionais.....84

Agentes públicos

Contratação temporária

Regramento jurídico

É inconstitucional lei que, a pretexto de valer-se do permissivo do art. 37, IX, da Constituição Federal (CF), efetive contratação temporária para atividade previsível, permanente e ordinária ou, ainda, que não estabeleça prazo determinado e não especifique a contingência fática que evidencie a situação emergencial.86

Agentes públicos

Contratação temporária

Regramento jurídico – Repercussão Geral

É inconstitucional lei que institua hipóteses abrangentes e genéricas de contratações de pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e não especifique a contingência fática que evidencie situação de emergência.88

Agentes públicos

Direitos e deveres

Direito de greve – Repercussão Geral

A Justiça comum federal ou estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração Direta, das autarquias e das fundações de direito público.....89

Agentes públicos

Direitos e deveres

Direito de greve – Repercussão Geral

A Administração Pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público.91

Agentes públicos

Empregados públicos

Demissão

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.93

Agentes públicos

Processo administrativo disciplinar (PAD)

Devido processo legal

Não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório ato administrativo de comandante militar que determine a remessa obrigatória ao Superior Tribunal Militar (STM) do resultado do julgamento realizado pelo Conselho de Justificação.94

Agentes públicos

Processo administrativo disciplinar (PAD)

Impedimentos e suspeição

Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em PAD seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada.95

Não é obrigatória a intimação do interessado para apresentar alegações finais após o relatório final de PAD.95

O acusado em PAD não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos.95

Admite-se o uso de prova emprestada em PAD, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. 95

A ausência de transcrição integral de dados obtidos por meio de interceptação telefônica não gera a nulidade da portaria de demissão do servidor.96

Agentes públicos

Processo administrativo disciplinar (PAD)

Inquérito

Não há nulidade – por suposto cerceamento de defesa e afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório – em PAD do qual resulte demissão de servidor público que, apesar de ter sido defendido por defensor dativo, tenha deixado de praticar os atos de sua defesa, embora regularmente intimado, em razão de suposta enfermidade, não comprovada.98

Agentes públicos

Processo administrativo disciplinar (PAD)

Julgamento

Não há vício na instalação de segunda comissão disciplinar, após a primeira ter concluído pela insuficiência de provas, quando houver dúvida razoável a amparar a continuidade das diligências investigativas.99

Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente nulo per se o PAD pelo decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão.99

A desproporcionalidade da evolução patrimonial implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito.99

Não cabe mandado de segurança para a discussão da proporcionalidade da pena nos casos de demissão por ato doloso de improbidade administrativa. ... 100

Agentes públicos

Processo administrativo disciplinar (PAD)

Julgamento

É inconstitucional o art. 170 da Lei 8.112/1990, o qual determina o registro do fato investigado em procedimento administrativo disciplinar nos assentamentos individuais do servidor mesmo quando extinta a punibilidade pela prescrição. ... 101

Agentes públicos

Processo administrativo disciplinar (PAD)

Julgamento

Suspensão por sessenta dias aplicada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal a servidora dos quadros da respectiva Corte padece de vício de nulidade. 102

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Abono de permanência

A ocupação de novo cargo da magistratura dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício. .103

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Acumulação de proventos

A coisa julgada não está a salvo da incidência do disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 105

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Acumulação de proventos

É legítima a acumulação de proventos civis e militares na hipótese de a reforma do militar ter ocorrido sob a égide da Constituição Federal (CF) de 1967 e o reingresso no serviço público civil ter se dado antes da vigência da Emenda Constitucional (EC) 20/1998, sendo irrelevante o fato de a aposentadoria civil ter acontecido em momento posterior. 108

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Adicional por tempo de serviço

São devidos adicionais por tempo de serviço que, em obediência à Lei 4.047/1961, tenham sido incorporados aos proventos de inativo por decisão transitada em julgado após a Constituição de 1988, de modo que o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não incide na espécie. 109

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria – Repercussão Geral

Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal (CF) aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. 111

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria

O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros. 112

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria

A exposição meramente eventual a situações de risco – a que podem estar sujeitas diversas categorias de servidores públicos – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (CF). 113

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria

Não há omissão inconstitucional relativa à elaboração de lei complementar estadual sobre os critérios diferenciados para aposentadoria de policiais civis do sexo feminino. 115

Não há omissão inconstitucional relativa à elaboração de lei complementar estadual sobre os critérios diferenciados para aposentadoria de policiais militares do sexo feminino. 115

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria

Não se exigem, quanto à tramitação do processo de aposentadoria, a bilateralidade, o contraditório e a audição do servidor envolvido. 117

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria

Apesar de não possuírem direito adquirido a regime de remuneração, os servidores públicos detêm direito líquido e certo de não receber a menor, a despeito do advento de nova forma de composição de seus proventos, uma vez que a irredutibilidade de vencimentos é garantia fundamental e, portanto, inelidível por emenda à Constituição. 118

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” ..119

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Aposentadoria – Repercussão Geral

Possui natureza taxativa o rol de doenças incapacitantes que autorizam – nos termos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal (CF) – a concessão de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, aos servidores públicos acometidos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 120

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Custeio

É inconstitucional o parágrafo único do art. 110 da Lei 915/2005 do Estado do Amapá, que – acrescido ao art. 110 do texto original por meio de emenda parlamentar – estabelece que a Amapá Previdência assumirá o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão que tenham sido concedidos pelos Poderes do Estado, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas durante o período de vigência do Decreto 87/1991. 121

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Paridade remuneratória dos proventos – Repercussão Geral

Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional (EC) 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade [Constituição Federal (CF), art. 40, § 7º, I]. 123

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Pensão por morte

O reconhecimento judicial de união estável não constitui requisito legal para concessão de pensão por morte à companheira, mesmo que o casamento anterior ainda esteja formalmente vigente. 125

Agentes públicos

Regime próprio de previdência social

Pensão por morte

Menor sob a guarda de servidor público tem, nos termos do art. 217, b, da Lei 8.112/1990, direito à pensão por morte até completar 21 anos de idade..... 126

Agentes públicos

Servidores públicos

Acumulação de cargo público

O cargo de agente administrativo – com exigência de escolaridade de nível médio – não se enquadra no conceito constitucional de cargo de natureza técnica, de sorte que não se subsume à excepcional hipótese de permissão de acúmulo de cargo público, contida no art. 37, XVI, *b*, da Constituição Federal (CF). 128

Agentes públicos

Servidores públicos

Cessão

O ônus remuneratório decorrente da cessão de servidor público para exercício de cargo em comissão ou função de confiança deve ser suportado pelo órgão cessionário, seja quando a cessão ocorrer do âmbito federal para o estadual, distrital ou municipal, seja quando seguir a situação inversa, tal qual disposto no art. 93, I e § 1º, da Lei 8.112/1990. 129

Agentes públicos

Servidores públicos

Curso de formação

O pedido de desligamento, uma vez completado o período de Escola Naval, gera para o Estado o direito à indenização, nos termos da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares). 131

Agentes públicos

Servidores públicos

Férias

É inconstitucional a concessão de sessenta dias de férias aos servidores da Justiça estadual como decorrência da associação entre esse direito e o período de férias coletivas concedidas nos tribunais. 132

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) possui competência constitucional para anular a fixação de férias em sessenta dias para servidores de segunda instância da Justiça estadual. 132

Agentes públicos

Servidores públicos

Férias – Repercussão Geral

Os procuradores federais têm direito a férias de trinta dias (Lei 9.527/1997, art. 5º) e não de sessenta dias. 134

Agentes públicos

Servidores públicos

Jornada de trabalho

A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos públicos do Poder Judiciário Federal das áreas de medicina e odontologia é, respectivamente, de quatro (vinte horas semanais) e seis (trinta horas semanais) horas diárias. 136

Agentes públicos

Servidores públicos

Jornada de trabalho

A Lei 10.356/2001 – que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira do Tribunal de Contas da União (TCU), bem como determina aos ocupantes do cargo de analista de controle externo da área de apoio técnico e administrativo, especialidade Medicina, que optem por uma das jornadas de trabalho estabelecidas na mencionada lei e, conseqüentemente, por remuneração equitativa ao número de horas laboradas – é aplicável somente aos profissionais de Medicina que ingressaram no quadro do TCU a partir da vigência da nova regra, ou seja, dezembro de 2001. 137

Agentes públicos

Servidores públicos

Licença para acompanhamento de cônjuge

A licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro de que trata o § 2º do art. 84 da Lei 8.112/1990 não se aplica em casos de provimento originário de cargo público. 138

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Acumulação de proventos e pensões

É legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal (CF) de 1967, e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional (EC) 20/1998. 139

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Agentes políticos

Há indício de inconstitucionalidade em dispositivo de Constituição estadual que estabeleça pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governador, a título de representação, igual à remuneração do cargo de desembargador do tribunal de justiça do Estado. 141

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Alteração da estrutura remuneratória

Limitada a discussão à eficácia temporal da sentença, não há falar em imutabilidade da própria decisão. 142

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Auxílio-alimentação

O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. 144

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Contribuição facultativa

Somente a partir de 14 de março de 2010, data da conclusão do julgamento da ADI 3.106, tornou-se possível a repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais para custeio compulsório da assistência à saúde. Trata-se de benefício fomentado pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores daquele Estado. 145

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Gratificações de desempenho – Repercussão Geral

O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, de modo que a Administração não pode retroagir os efeitos financeiros a data anterior. 147

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Gratificações de desempenho

“A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).” 149

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Incorporação de parcelas remuneratórias – Repercussão Geral

Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede incorporação de quintos pelo exercício de função ou cargo comissionado no período compreendido entre 8-4-1998 e 4-9-2001 – datas de edição da Lei 9.624/1998 e da Medida Provisória (MP) 2.225-45/2001, respectivamente –, devido à carência de fundamento legal. 150

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Irredutibilidade de vencimentos

É vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito de ato administrativo. 153

Aumento de vencimento legalmente concedido, com data predeterminada para início de eficácia, caracteriza aquisição de direito. 153

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Irredutibilidade de vencimentos – Repercussão Geral

Ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, art. 37, XV). 154

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Isonomia

“O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.” 155

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Isonomia – Repercussão Geral

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, tampouco proceder à equiparação salarial entre servidores de mesmo cargo, quando o paradigma decorrer de decisão judicial transitada em julgado. 156

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Isonomia

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 157

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Isonomia – Repercussão Geral

As vantagens remuneratórias de caráter geral conferidas a servidores públicos, por serem genéricas, são extensíveis a inativos e pensionistas, quando o servi-

dor tiver preenchido os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito antes da Emenda Constitucional (EC) 41/2003. 158

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Isonomia – Repercussão Geral

Os servidores aposentados e os pensionistas do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) fazem *jus*, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (CF) – com a redação dada pela Emenda Constitucional (EC) 20/1998 –, à paridade remuneratória em relação aos servidores ativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), uma vez que a criação deste órgão decorreu da extinção daquele. 160

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Publicidade administrativa – Repercussão Geral

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e das vantagens pecuniárias. 161

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Publicidade administrativa

As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública. Não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem o sigilo, o Senado Federal deve disponibilizar acesso a informações e documentos referentes à concessão de verbas a senadores da República. 163

O ônus argumentativo de demonstrar a caracterização das hipóteses que permitem afastar a regra geral da publicidade incumbe a quem pretenda afastá-la, uma vez que se trata de situações excepcionais. 163

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Reajuste

A decisão judicial que considera procedente o pedido de incorporação de reajuste de 13,23%, indistintamente, a servidor público federal afronta o Enunciado 37 da Súmula Vinculante. 165

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Reajuste

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 166

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Revisão geral anual

As vantagens instituídas pelas Leis 10.697/2003 e 10.698/2003 não têm natureza de revisão geral anual, destinada a revisar, de forma ampla e irrestrita, a remuneração dos servidores públicos federais civis. 167

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Teto remuneratório – Repercussão Geral

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal (CF) pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público..... 169

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Teto remuneratório – Repercussão Geral

Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal (CF), os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional (EC) 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição de valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 171

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Teto remuneratório – Repercussão Geral

Subtraído o montante que exceder o teto ou o subteto previstos no art. 37, XI, da Constituição Federal (CF), tem-se o valor que serve como base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 174

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Teto remuneratório

É inconstitucional lei estadual que estabeleça subteto aplicável aos servidores da Justiça desvinculado do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça. 176

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Teto remuneratório – Repercussão Geral

Os valores de remuneração dos servidores públicos que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal (CF) constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 178

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Verba indenizatória

A vedação à concessão de verbas adicionais ou vantagens pecuniárias contidas na Lei Complementar (LC) 35/1979 não impede o recebimento de verbas de natureza indenizatória previstas em legislação estadual. 180

Agentes públicos

Sistema remuneratório

Verba indenizatória

Não é devido aos membros do Ministério Público da União (MPU) o pagamento de auxílio-moradia em razão de promoção com deslocamento. 181

Bens públicos

Alienação

Imóveis residenciais

O imóvel residencial administrado pelas Forças Armadas e destinado à ocupação por militares não pode ser alienado..... 183

Contratos administrativos

Execução de contratos

Cláusula exorbitante

A Administração Pública, ao contratar com particulares, pode, unilateralmente, modificar cláusula contratual. 185

Contratos administrativos

Execução de contratos

Responsabilidade subsidiária da Administração – Repercussão Geral

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 186

Controle da Administração Pública

Controle externo

Tribunal de Contas da União (TCU)

O TCU tem competência para declarar a inidoneidade de empresa privada para participar de licitações promovidas pela Administração Pública..... 189

Intervenção do Estado na propriedade

Desapropriação

Interesse social para fins de reforma agrária

Em mandado de segurança, não é possível dilação probatória para dirimir controvérsia fática sobre suposta invasão de área objeto de decreto expropriatório para fins de reforma agrária e o impacto dessa ocupação na produtividade do imóvel rural. 192

Intervenção do Estado na propriedade

Desapropriação

Interesse social para fins de reforma agrária

Caracterizada divergência entre as alegações da impetrante e as informações prestadas pela autoridade coatora acerca do quadro fático, cuja superação dependa necessariamente de dilação probatória, é inadmissível a ação de mandado de segurança..... 193

Intervenção do Estado na propriedade

Expropriação

Excludentes da culpa – Repercussão Geral

A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal (CF) pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que *in vigilando* ou *in eligendo*. 194

Organização da Administração Pública

Administração Indireta

Autarquias – Repercussão Geral

Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. 197

Organização da Administração Pública

Administração Indireta

Empresas públicas

É incabível aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução prevista no art. 100 da Constituição Federal (CF). 198

Organização da Administração Pública

Administração Indireta

Organizações sociais

O marco legal das organizações sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da participação na Administração Pública. 199

O procedimento de qualificação das organizações sociais deve ser conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da Constituição Federal (CF), e de acordo com os parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei 9.637/1998. 199

A celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da CF. 200

As hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 9.637/1998, art. 12, § 3º) devem ser conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da CF. 200

Os contratos a serem celebrados pela organização social com terceiros, envolvendo recursos públicos, devem ser conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal. É necessário observar os princípios do *caput* do art. 37 da CF e os termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade. 201

A seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da CF e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade. 201

Afastam-se quaisquer interpretações que restrinjam o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), da aplicação de verbas públicas. 202

A previsão de percentual de representantes do poder público no conselho de administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII e XVIII, da CF, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor. 202

Organização da Administração Pública

Administração Indireta

Sociedades de economia mista

É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial...204

Organização da Administração Pública

Administração Indireta

Sociedades de economia mista

As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial submetem-se ao regime de precatório.205

Poderes administrativos

Poder de polícia

Guardas municipais – Repercussão Geral

É constitucional atribuir o exercício do poder de polícia de trânsito às guardas municipais, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.208

Princípios da Administração Pública

Devido processo legal

Cadastros federais de inadimplência

Comprovado que o lançamento do Estado no Cadastro Único de Convênios (Cauc) e no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) ocorreu sem se viabilizar, à exaustão, o direito de defesa, é cabível a suspensão do procedimento.210

Princípios da Administração Pública

Princípio da intranscendência subjetiva das sanções

Gestão pública

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de sanções severas às administrações por ato de gestão anterior.212

Viola o princípio do devido processo legal a inscrição de unidade federativa em cadastro de inadimplentes antes de iniciada e julgada eventual tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União. 212

Processo administrativo

Anulação, revogação e convalidação

Decadência

A instauração de processo específico de anulação de anistia caracteriza ato impugnável capaz de, por si só, viabilizar impugnação pela via mandamental..... 215

Processo administrativo

Anulação, revogação e convalidação

Decadência

Decorrido o prazo quinquenal, a Administração Pública não pode anular anistia política concedida mesmo que, nesse ínterim, a Advocacia-Geral da União (AGU) tenha emitido nota questionando os critérios adotados na concessão. . 217

Processo administrativo

Anulação, revogação e convalidação

Decadência

A anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que viabilize a audição daquele que terá a situação jurídica modificada. 218

Processo administrativo

Instrução

Providências acauteladoras

O termo inicial para a formalização de mandado de segurança pressupõe a ciência do impetrante, quando o ato impugnado surgir no âmbito de processo administrativo do qual seja parte. 219

Instruído o processo com documentos suficientes ao exame da pretensão veiculada na petição inicial, descabe suscitar a inadequação da via mandamental..... 219

Processo administrativo

Instrução

Providências acauteladoras

O pagamento dos denominados “quintos” incorporados aos vencimentos de servidor pode ser suspenso no curso de processo administrativo.221

Processo administrativo

Recurso administrativo e revisão

Nulidades

Em recurso administrativo, é nula decisão proferida por ministro de Estado que, anteriormente, ao ocupar cargo hierarquicamente inferior na mesma estrutura administrativa, tenha indeferido pedido de reconsideração sobre o mesmo objeto.222

Serviços públicos

Concessões públicas

Prorrogação contratual

Inexiste direito líquido e certo à prorrogação contratual do contrato de concessão de usina hidrelétrica.224

Embora todo contrato administrativo tenha um prazo definido sobre o qual se perfaz o equilíbrio da relação contratual, não há que cogitar de sua incidência na prorrogação contratual, que pode se dar sob novos termos se assim definido em lei.225

Serviços públicos

Educação

Gratuidade do ensino público

A cobrança de “taxa de alimentação” por instituição federal de ensino profissionalizante é inconstitucional.227

Responsabilidade civil do Estado

Responsabilidade objetiva

Anistia política – Repercussão Geral

Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, *caput* e parágrafo único, da Lei 10.559/2002, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo..... 229

Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de sessenta dias. 229

Responsabilidade civil do Estado

Responsabilidade objetiva

Ato omissivo – Repercussão Geral

O Estado é responsável pela morte de detento em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal (CF). 231

Responsabilidade civil do Estado

Responsabilidade objetiva

Dever de indenizar

É inconstitucional lei estadual que imponha ao ente estatal o pagamento de pensão especial a cônjuge de vítima de determinados crimes hediondos praticados por terceiros na respectiva unidade federativa, independentemente de o autor do crime ser ou não agente público. 233

Responsabilidade civil do Estado

Responsabilidade objetiva

Estabelecimentos penitenciários – Repercussão Geral

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF), a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. 235

Responsabilidade civil do Estado

Responsabilidade objetiva

Planos econômicos

A União, na qualidade de contratante, deve observar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e indenizar os prejuízos suportados por companhia aérea em virtude de suposta diminuição do seu patrimônio decorrente de planos econômicos em vigor no período objeto da ação em consequência da política de congelamento tarifário vigente no País.....237

Responsabilidade civil do Estado

Responsabilidade objetiva

Posse em cargo público – Repercussão Geral

Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.238

Ressarcimento ao erário

Ação de reparação de danos à Fazenda Pública

Prescrição e decadência – Repercussão Geral

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil.241

Este livro foi produzido na Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência, vinculada à Secretaria de Documentação do Supremo Tribunal Federal. Foi projetado por Eduardo Franco Dias e composto por Camila Penha Soares e Neir dos Reis Lima e Silva. A capa foi criada por Patrícia Amador Medeiros.

A fonte é a Dante MT Std, projetada nos anos 1950 por Giovanni Mardersteig, influenciado pelos tipos cunhados por Francesco Griffo entre 1495 e 1516, e editada em versão eletrônica por Ron Carpenter em 1993.



ISBN

978-85-54223-18-2